

- §经济法是一门有趣的课程；
- §经济法是一门实用的课程；
- §经济法生机盎然，她就在我们身边，唾手可得，只要你曾经思考过那么一小会儿。

（本课件配套教材：《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年11月第1版 周黎明 著，2019年第二次印刷的新形态教材版，2021版在修订中）

目录

第一章 经济法基础理论

第二章 合同法

第三章 企业法

第四章 公司法

第五章 企业破产法

第六章 经济竞争法

第七章 知识产权法

第八章 金融法

第九章 税法

第十章 劳动法

第十一章 经济仲裁和经济诉讼

《经济法理论与实务》

主讲：周黎明 博士/副教授

浙江大学.法与经济研究所 副所长

(浙江楷立律师事务所兼职执业律师)

本课件受著作权法保护

提交作业E-mail:zjdxtskjjf@126.com

第一章 经济法基础知识

一、何为法？（一个争议的话题）

国外：Law法 Justicia正义

§ 德国学者**鲁道夫·冯·耶林**：
“正义女神”
一手提着天平，用它衡量法；另一
只手握着剑，用它维护法。



§ 东汉·许慎《说文》：“灋，刑也。平之如水。从水，廌所以触不直者去之，从去，会意。” 什么意思呢？

§ 灋是“法”的古字，这里说的法，就是刑法。因为执法需要公平如水，所以是“氵”旁；“廌zhì”（也叫獬豸(xiè zhì)）是传说中的独角兽，一种与鹿和牛类似的神兽，能辩是非曲直，传说古代法庭上用它来辨别罪犯，每当办案时出现多个嫌疑人的时候，人们通常把它放出来，它如果用它那锋利无比的犄角顶谁，谁就是罪犯。



我国，从两种角度加以理解。

一是从哲理意义上，“理”、“常”、指的是“道理”、“天理”。

二是从典章制度意义上，“律”。

实践：“以刑代民” 立法上：重刑轻民；

除了“律”以外，“令”也是法、“典”、“敕”、“格”、“式”、“科”、“比”、“例”等等，都是法。一直到了清末民初，由于受到日本的影响，国法意义上的法才逐渐被“法律”一词所取代。

目前教材上关于法的定义无非 三句话：反映统治阶级意志、由国家制订和认可，并由国家强制力保证实施的行为规则的总和。

二、法律关系（三要素）

1、主体：

（1）自然人（公民）

①民事权利能力：（见下页资料1）

②民事行为能力：（见下页资料1）

（2）法人

四要素：1、依法成立；2、名称、组织机构和场所；3、资金；4、独立承担民事责任。

（3）其他组织

（4）国家机关

2、客体：物、行为、无形财富

3、内容：（经济）权利、（经济）义务

你了解你的民事权利能力和民事行为能力吗？

（1）民事权利能力：

享有民事权利承担民事义务的资格。

（始于**出生**，终于**死亡**。注：宣告死亡）

（2）民事行为能力：

以自己的行为取得民事权利承担民事义务的资格。

具体分为三类人：

①完全民事行为能力人：18周岁以上（法律行为的效力）

②限制民事行为能力人：8—18周岁（法律行为的效力）

③无民事行为能力人：8周岁以下（法律行为的效力）

（回到上页）

三、所有权

1、定义：所有人对其财物所享有的占有、使用、收益、处分的权利。（四大权能）

占有权：对财物的实际控制的权利；

使用权：依据财物的性能和用途加以运用和利用，以满足一定的经济需要的权利；

收益权：从财物上获得经济利益的权利；

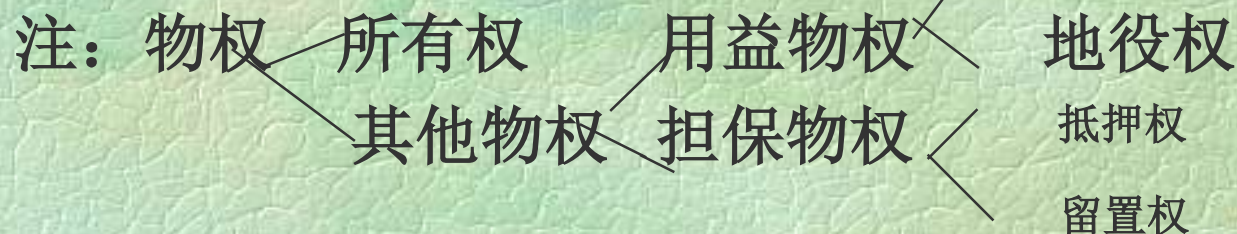
处分权：在法律规定的范围内处置其资产的权利。（核心权）

2、特征

a、绝对性

b、排他性

c、完整、充分的物权



3、共有

共有可以分为两种：

(1) 按份共有

(2) 共同共有

4、所有权的保护

(1) 请求确认所有权

(2) 请求恢复原状

(3) 请求返还原物

(4) 请求排除妨害

(5) 请求损害赔偿

§ 案例：A、B之间关于房屋买卖达成了合意，并签订了正式的商品房买卖合同。合同签订后，由于卖方A家中出现了纠纷，未能办理房屋的过户登记手续。问：双方的商品房买卖合同是否生效？买方B是否取得了该商品房的所有权？

§ （请见书本分析《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年11月第1版 周黎明著）

§ 案例：A将属于B的房屋以自己的名义进行了产权登记，并将该房屋转让给了C。C为不知情的善意受让人，支付了该房屋的市场价，受让了该房屋并办理了产权登记。B事后证明房子原本是自己的，A将B的房产以A名义进行登记属于侵权，并要求C返还该房产。问：C是否可以取得该房产的所有权？

§

§ 案例：甲乙丙对某套房屋享有共有权，甲占有60%的份额，乙占有30%的份额，丙占有10%的份额。三方约定，该房屋轮流分别由甲乙丙使用6个月、3个月和1个月。请回答下列问题：

§ (1)设甲现欲转让自己的份额，乙丙均主张优先购买权，应如何处理？

§ (2)设甲抛弃自己的份额，该份额归属如何？为什么？

§ (3)设甲在居住期间，其花盆掉落，砸伤行人，责任应如何承担？为什么？

§ (4)设乙在居住期间，房屋廊檐因年久失修掉落，砸伤行人，责任应如何承担？为什么？

§ （请见书本分析）

§ 案例：史强是一机关单位干部，徐莉原为工厂工人，二人结婚已有10年。后徐莉辞职经商，依法登记为个体户。史强起初反对妻子下海经商，但后来见收入不少，就不再反对，但一直没有参与徐莉的经营。徐莉的经营收入用于家庭消费和储蓄。一次因车祸导致徐莉损失货物价值13万元，债主找史强要账。史强有存款14万元，这14万元是史强多年的工资收入以及继承其父亲财产所得。对于徐莉所负债务，有这样几种观点：1) 徐莉的债务是个人债务，依婚姻法的规定，夫妻之间的个人债务，由债务人自己承担，不能由共同财产承担。故此史强没有还债义务；2) 史强的14万元存款虽然是其个人财产，但夫妻间有相互扶养的义务，故史强有义务偿还徐莉负债务；3) 应按照徐莉的经营收入所用于家庭消费而为徐莉所分享的比例，确定史强所应承担的该宗债务中的适当份额；4) 14万元存款是夫妻共同财产，徐莉所欠债务是共同债务，故史强有义务偿还债务

§ (请见书本分析)

三、债权

1、何为债？

所谓债是指按照法律规定或者按照合同规定，在特定当事人之间产生的权利义务关系，即债权债务关系。享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。

2、特点：相对法律关系

3、分类

(1) 按照债的发生依据不同，可分为：合同之债、侵权之债、不当得利之债和无因管理之债。

(2) 按照债的标的物的性质不同，可分为：特定物之债和种类物之债。

(3) 按照债的主体数量不同，可分为：单一之债和多人之债，多人之债又可以分为按份之债和连带之债。

§ 案例：养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。对于王某是否可以要回此牛，有以下几种意见：1) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得牛并据为己有，构成不当得利；2) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费；3) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权4) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿。

§ （请见书本分析）

四、代理

1、定义： 代理是指代理人以被代理人的名义，在代理授权范围内，与第三人从事民事活动，并由被代理人承担由此而产生的法律后果的法律行为。

2、代理的特征

- (1) 代理是一种法律行为；
- (2) 代理是代理人以被代理人的名义进行的；
- (3) 代理是代理人在授权范围内所作的独立意思表示；
- (4) 代理所产生的法律后果直接归属于被代理人。

3、代理的种类：

- (1) 委托代理：经济活动中用的比较多。
- (2) 法定代理：在民事活动用的比较多。
- (3) 指定代理：在诉讼活动中用的比较多。

4、法律责任

- (1) 无权代理：无代理权、超越代理权、代理权已终止
- (2) 代理人与第三人恶意串通：由代理人与第三人承担连带责任。
- (3) 违法代理：由代理人与被代理人承担连带责任。
- (4) 代理人不履行代理职责，给被代理人造成损失的，应承担赔偿责任；
- (5) 转委托：一般情况下，转委托必须取得被代理人的同意，否则无效。

但在紧急情况下，为了维护被代理人的利益的，不在此限。

§ 案例分析：

1、甲厂买通了乙门市部的采购员张某，由张某从甲厂买进了价值10万元的劣质货物，在仓库存放了一年半才被发现。而此时，张某已经另案被捕。门市部向甲厂提出退货或承担削价处理的损失，遭到了甲厂的拒绝。甲厂认为：第一，张某是门市部的合法代理人，其采购行为有效；第二，门市部在一年半后才提起此事，已经过了时效。问：甲厂的理由是否符合法律规定？

代理人与第三人恶意串通，由代理人与第三人承担连带责任；
（注意：时效）

注意：诉讼时效的问题
（见本章第五个问题）

2、甲全权委托朋友乙，将一批服装由A市运往B市销售。乙雇佣了丙的汽车负责运输。乙、丙出发后不久，乙突患急病被送往医院，由于当时情况紧急，无法联系上甲，只好将服装转委托给司机丙。丙继续运输。与此同时，乙从医院给甲打了个电话，告知此事，甲当即表示不同意，但此时丙已经上路。快到B市时，突遇罕见暴风雨，将服装淋湿。为了减少进一步的损失，丙将服装作了合理的降价处理，损失7万元。问：本案转委托是否有效？该损失应由谁来承担？

§ 请选择：（1）转委托有效；（2）转委托无效；（3）损失由甲承担；（4）损失由乙承担；（5）损失由丙承担；（6）损失由乙、丙共同承担；（7）损失由甲、乙合理分担；（8）损失由甲、丙合理分担；（9）损失由甲乙丙共同承担。

§ 再作一假设：假设在运输途中，丙去一酒店喝酒，喝醉了酒，忘了关车门，致使汽车和服装都被偷走，此损失应：（9）由甲承担；（10）由乙承担；（11）由丙承担；（12）汽车损失由丙承担，服装损失由甲承担；（13）汽车损失由丙承担，服装损失由乙承担。（14）汽车损失由丙承担，服装损失由甲、乙共同承担。

§ 一般情况下，转委托必须取得被代理人的同意，否则无效。但在紧急情况下，为了维护被代理人的利益的，不在此限。

§ 代理人不履行代理职责而给被代理人造成损害的，应由代理人承担赔偿责任。

§ 《民法典》第一百七十条：

§ 执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。

§ 法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

§

§ 《民法典》第三节规定了代理终止的法定情形：

§ 第一百七十三条 有下列情形之一的，委托代理终止：

§ （一）代理期限届满或者代理事务完成；

§ （二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

§ （三）代理人丧失民事行为能力；

§ （四）代理人或者被代理人死亡；

§ （五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

§ 第一百七十四条 被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（也即：被代理人死亡，代理行为不一定终止）

§ （一）代理人不知道且不应当知道被代理人死亡；

§ （二）被代理人的继承人予以承认；

§ （三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；

§ （四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。

§ 作为被代理人的法人、非法人组织终止的，参照适用前款规定。

§ 第一百七十五条 有下列情形之一的，法定代理终止：

§ （一）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；

§ （二）代理人丧失民事行为能力；

§ （三）代理人或者被代理人死亡；

§ （四）法律规定的其他情形。

五、诉讼时效（一个重要却常被忽视的问题！）

诉讼时效是指因权利人不行使权利的事实状态经过法定期间而使其丧失在诉讼中胜诉权的法律事实。（民事时效/刑事时效）具体包括：

1. 普通诉讼时效。《民法通则》规定普通诉讼时效为**两年**；《民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为**三年**。法律另有规定的，依照其规定。

《民法典》：诉讼时效期间**自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算**。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过**二十年**的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

另外，民法总则第一百九十一条 **未成年人**遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人**年满十八周岁之日**起计算。

2. 短期时效。《民法通则》有短期时效的规定。

民法总则取消了短期时效。

注意与刑法上的追诉时效的区别

§ “该不该还钱？”与“要不要还钱？”的问题

2009年8月12日，邻居张某从刘某处借了10万元钱。当时在借条上写好三年后连本带利一次还清。2012年8月1日，眼看快要到了约定的还款日期，刘某上门要钱，张某准备卖掉部分房子还钱，结果张某妻子不同意，还一气之下打开煤气罐要自杀，幸亏扑救及时，未酿大祸。刘某碍于邻居面子又害怕惹出人命，从那以后再也没提还款一事。直到2016年9月，刘某儿子准备买房，这才向张某提出还款，张某表示无力还款。刘某为此诉至法院。

诉讼中，张某的律师提出诉讼时效届满，请求法院驳回诉讼。

问：1、诉讼时效届满后，当事人是否有诉权？

2、被告若不以时效届满提出抗辩，法院能否主动以时效届满驳回起诉？

3、若张某在偿还了借款后，才得知本案诉讼时效已过，懊悔不已，遂起诉要求刘某予以返还，应否支持？

§ 三、诉讼时效的中止

(一)诉讼时效中止的概念

诉讼时效的中止，指在诉讼时效进行中，因一定的法定事由的发生使权利人无法行使请求权，暂时停止计算诉讼时效期间。在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间**继续**计算。

(二)诉讼时效中止的事由

一是不可抗力;二是其他障碍。此处的其他障碍包括(1)权利被侵害的无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力;(2)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;(3)权利人被义务人或者其他人控制无法主张权利;(4)其他导致权利人不能主张权利的客观情形。

§ (三)诉讼时效中止的时间

只有在诉讼时效的最后6个月内发生中止事由，才能中止诉讼时效的进行。如果在诉讼时效期间的最后6个月以前发生权利行使障碍，而到最后6个月时该障碍已经消除，则不能发生诉讼时效中止;如果该障碍在最后6个月时尚未消除，则应从最后6个月开始起中止时效期间，直至该障碍消除。

(四)诉讼时效中止的法律效力

在诉讼时效中止的情况下，中止事由发生前已经经过的时效期限仍然有效，等到时效中止的原因消除后，前后期间合并计算。在民法规定的最长诉讼时效期间内，诉讼时效中止的持续时间没有限制。

四、诉讼时效的中断

(一)诉讼时效中断的概念

诉讼时效的中断，指在诉讼时效进行中，因法定事由的发生致使已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，诉讼时效**重新**计算。

(二)诉讼时效中断的法定事由

1.提起诉讼。提起诉讼是指通过司法程序行使请求权。

下列事项均与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力：(1)申请仲裁；(2)申请支付令；(3)申请破产、申报破产债权；(4)为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡；(5)申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施；(6)申请强制执行；(7)申请追加当事人或者被通知参加诉讼；(8)在诉讼中主张抵销；(9)其他与提起诉讼具有同等诉讼时效中断效力的事项。

)

§ 2.当事人一方提出请求。 具有下列情形之一的，应当认定为“当事人一方提出要求”：

(1)当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书，对方当事人在文书上签字、盖章或者虽未签字、盖章但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的；

(2)当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人的；

(3)当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的；

(4)当事人一方下落不明，对方当事人在国家级或者下落不明的当事人一方住所地的省级有影响媒体上刊登具有主张权利内容的公告的，但法律和司法解释另有特别规定的，适用其规定。

(5)权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力及于剩余债权，但权利人明确表示放弃剩余债权的情形除外。其中第(1)项情形中，对方当事人为法人或者其他组织的，签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收发信件的部门或者被授权主体；对方当事人为自然人的，签收人可以是自然人本人、同住的具有完全行为能力的亲属或者被授权主体。(新增

3.义务人同意履行义务。

义务人通过一定的方式向权利人作出愿意履行义务的意思表示。

(三)诉讼时效中断的法律效力

对于连带债权人、连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带债权人、连带债务人也发生诉讼时效中断的效力。(新增)

债权人提起代位权诉讼的，应当认定对债权人的债权和债务人的债权均发生诉讼时效中断的效力。

债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断。债务承担情形下，构成原债务人对债务承认的，应当认定诉讼时效从债务承担意思表示到达债权人之日起中断。(新增)

诉讼时效的中断可以数次进行，当然不得超过20年最长诉讼时效的限制。

五、诉讼时效的延长

权利人在法定的诉讼时效期间内没有行使权利，原则上胜诉权消灭。人民法院可以斟酌具体情况，延长诉讼时效期间。所有的诉讼时效期间都可以适用诉讼时效的延长。

第二章 合同法

——《民法典》中的合同编

《民法典》合同编分为通则、典型合同、准合同三个分编，共计526个条文，几乎占据民法典条文的半壁江山。

从合同编整体来说，一是关注民生，回应社会热点，诸如限制“霸座”、禁止高利放贷等内容（这是我国首次在人大立法层面，明确对高利放贷行为予以禁止。

《民法典》第680条 禁止高利放贷（后文阐释）。

二是尊重意思自治，合同编中诸多条款遵循了合同主体“约定优先”，突出了意思自治；

三是承继与创新并重，在合同法的基础上进行了大的修订，吸纳了司法解释中的精华。



民法典合同编还有一个很大的亮点是确立了情势变更的适用。

民法典合同编533条规定：合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人,可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。



此外，为适应现实需要，合同编在现行合同法规定的买卖合同等15种典型合同的基础上，增加了保证合同、保理合同、物业服务合同、合伙合同四种新的典型合同，总共19种有名合同，使更多的合同能够在民法典中对号入座，有利于民事纠纷的有效预防和精准解决。

《民法典》合同编的几个亮点：

1、电子合同，顺应数字化时代

为了顺应数字化时代的飞速发展，《民法典》完善了电子合同订立规则，增加了预约合同的具体规定，数据电文也具有法律效力。

第469条 当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

订立合同的形式：1、书面形式；2、口头形式；3、其他形式。

其中书面形式包括：

a合同书；

b信件；

c数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换（EDI）、电子邮件（E-Mail）。

中国能否跟随世界潮流，积极发展EDI技术，关系到这个民族的兴衰和存亡.....



第512条 通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。电子合同的标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间；前述凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，以实际提供服务的时间为准。

电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间为交付时间。

电子合同当事人对交付商品或者提供服务的方式、时间另有约定的，按照其约定。

2、客运合同，对“霸座者”“抢方向盘”问题给予回应

针对近年来客运合同领域出现的旅客霸座、不配合承运人采取安全措施等严重干扰运输秩序和危害运输安全的问题，维护正常的运输秩序，

《民法典》细化了客运合同当事人的权利义务。《民法典》第815条第一款、第819条、第820条作出明确规定。

旅客应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号乘坐。旅客无票乘坐、超程乘坐、越级乘坐或者持不符合减价条件的优惠客票乘坐的，应当补交票款，承运人可以按照规定加收票款；旅客不支付票款的，承运人可以拒绝运输。

实名制客运合同的旅客丢失客票的，可以请求承运人挂失补办，承运人不得再次收取票款和其他不合理费用。

承运人应当严格履行安全运输义务，及时告知旅客安全运输应当注意的事项。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应当积极协助和配合。

承运人应当按照有效客票记载的时间、班次和座位号运输旅客。承运人迟延运输或者有其他不能正常运输情形的，应当及时告知和提醒旅客，采取必要的安置措施，并根据旅客的要求安排改乘其他班次或者退票；由此造成旅客损失的，承运人应当承担赔偿责任，但是不可归责于承运人的除外。

§ 目前，乘客“霸座”行为一般按照《治安管理处罚法》处理。其中第23条规定，扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的，处警告或者200元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

§ “霸座”、“抢方向盘”不全都是民法的问题，可能涉及到刑法、行政法的问题。但是从民法的角度，比如从承运人、乘客的权利义务角度、侵权责任的角度，民法典给予回应。

§ 《民法典》第823条 承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担赔偿责任；但是，伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。

3、格式条款，对商家的霸王条款说“不”

“禁止自带酒水” “特价、促销商品概不退换” 《民法典》完善了格式条款制度。

第496条 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

§ 店堂告示——我们身边的格式条款！

§ 由于格式条款在世界各国广泛被使用，因此，各国对其都有规定。我国对格式条款的规定，最早出现在保护消费者领域，1993年通过的消费者权益保护法第24条规定，经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，甚至减轻或者免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任。格式合同、通知、声明、店堂告示等方式所列内容无效。

§ 店堂告示——我们身边的格式条款！

相信我们在座的各位都遇到过格式条款，有的甚至签订过格式合同，那么这些格式条款/格式合同效力如何呢？比如：

商家：“本次活动的最终解释权归本商场。”

“本柜台东西一经售出，概不负责！”

宾馆：“如有贵重物品，请交寄存处寄存。若不交寄存处寄存，住客物品的遗失或者损坏，本宾馆概不负责！”

野生动物园：“本动物园猛兽区严禁下车。若在猛兽区随意下车，遭到猛兽攻击，本动物园概不负责！”

本人所住小区前段时间在洗衣店门口也贴出了一张告示：

“ 告示

若非因本洗衣店原因，导致衣物损坏，
本洗衣店概不负责！”

“生死状”问题

见书本

§ 消费者遭遇“霸王条款”，该怎么办？

§ 第一，先与经营者协商解决。指出“霸王条款”的不合理之处，相互沟通，争取双方达成合意。

§ 第二，若经营者拒不承认“霸王条款”，或者明确拒绝取消“霸王条款”，可以向当地消费者协会投诉，寻求消协出面调解。

§ 第三，因“霸王条款”给消费者造成严重损害的，消费者可以向工商行政部门举报投诉，依法对经营者处以行政处罚；

§ 第四，依法提起诉讼，通过司法途径，讨回公道，要求经营者赔偿损失，赔礼道歉等。

尤其注意第497、498条：

第四百九十七条 有下列情形之一的，该格式条款无效：

- （一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；
- （二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；
- （三）提供格式条款一方排除对方主要权利。

第四百九十八条 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

§ 民法典明确规定了 预约合同

§ 第495条 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。

§ 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。

§ 商品房预订/订购协议

4、物业服务合同，业主维权法律依据更明确

针对物业服务领域的突出问题，《民法典》增加规定物业服务合同，为业主解决物业纠纷提供了明确的法律依据。

第937条 物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。

第938条 物业服务合同的内容一般包括服务事项、服务质量、服务费用的标准和收取办法、维修资金的使用、服务用房的管理和使用、服务期限、服务交接等条款。

第939条 建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人订立的物业服务合同，对业主具有法律约束力。

第940条 建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同约定的服务期限届满前，业主委员会或者业主与新物业服务人订立的物业服务合同生效的，前期物业服务合同终止。

第941条 物业服务人将物业服务区域内的部分专项服务事项委托给专业性服务组织或者其他第三人的，应当就该部分专项服务事项向业主负责。

物业服务人不得将其应当提供的全部物业服务转委托给第三人，或者将全部物业服务支解后分别转委托给第三人。

第942条 物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。

对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。

第九百四十三条 物业服务人应当定期将服务的事项、负责人员、质量要求、收费项目、收费标准、履行情况，以及维修资金使用情况、业主共有部分的经营与收益情况等以合理方式向业主公开并向业主大会、业主委员会报告。

第九百四十四条 业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。

业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。

物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

第九百四十五条 业主装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务人，遵守物业服务人提示的合理注意事项，并配合其进行必要的现场检查。

业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的，应当及时将相关情况告知物业服务人。

第九百四十六条 业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。决定解聘的，应当提前六十日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。

依据前款规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。

第九百四十七条 物业服务期限届满前，业主依法共同决定续聘的，应当与原物业服务人在合同期限届满前续订物业服务合同。

物业服务期限届满前，物业服务人不同意续聘的，应当在合同期限届满前九十日书面通知业主或者业主委员会，但是合同对通知期限另有约定的除外。

第九百四十八条 物业服务期限届满后，业主没有依法作出续聘或者另聘物业服务人的决定，物业服务人继续提供物业服务的，原物业服务合同继续有效，但是服务期限为不定期。

当事人可以随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前六十日书面通知对方。

第九百四十九条 物业服务合同终止的，原物业服务人应当在约定期限或者合理期限内退出物业服务区域，将物业服务用房、相关设施、物业服务所必需的相关资料等交还给业主委员会、决定自行管理的业主或者其指定的人，配合新物业服务人做好交接工作，并如实告知物业的使用和管理状况。

原物业服务人违反前款规定的，不得请求业主支付物业服务合同终止后的物业费；造成业主损失的，应当赔偿损失。

第九百五十条 物业服务合同终止后，在业主或者业主大会选聘的新物业服务人或者决定自行管理的业主接管之前，原物业服务人应当继续处理物业服务事项，并可以请求业主支付该期间的物业费。

5、禁止高利放贷，不怕网贷被套路

针对近年来各界反映强烈的高利贷问题，《民法典》明确规定禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

第六百八十条第一款 禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。

[民间借贷的几点补充.ppt](#)

6、房子被拍卖，承租者优先承租

为落实党中央提出的建立租购同权住房制度的要求，保护承租人的利益，《民法典》增加规定房屋承租人的优先承租权。

第734条第二款 租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

7、非金钱债务违约方，有权解除合同

原《合同法》的合同解除权均只能由非违约方行使，《民法典》第580条作出了修改，在出现合同履行困境的情况下，**违约方也可以向法院提出解除合同的请求，但不影响违约责任的承担。**

第580条致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。

8、在不可撤销的赠与情形中增加“助残”

《民法典》第658条 赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不适用前款规定



一、合同的概念和分类

《合同法》：平等主体的自然人、法人、其他组织之间**设立、变更、终止民事权利义务关系**的协议。

《民法典》第四百六十四条：合同是民事主体之间**设立、变更、终止民事法律关系**的协议。

婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。

合同法资料2：你会订立合同吗？（合同简单样板）

××订购协议

甲方：××公司 法定代表人：×××

乙方：×××（身份证号码）

甲乙双方本着友好、诚信的原则，就××货物的订购事宜达成如下一致意向，双方共同遵守。

- 1、甲方向乙方订购××1000公斤，价格：××元/公斤
- 2、产品质量要求：与乙方提交的样品相符。
- 3、交货时间：2020年12月15日；
- 4、交货方式：买方自提。地点：卖方仓库。
- 5、违约责任：若甲方未能及时提货或者未能付款，每日按总货款的1%支付乙方违约金；若乙方未能及时交货，每日按总货款的1%支付甲方违约金。
- 6、争议解决方式：因本合同所生争议，提交杭州市仲裁委员会仲裁解决。
- 7、本合同一式两份，自甲乙双方签字（盖章）之日其生效。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

年 月 日

年 月 日



浙江大学

ZheJiang University

§ 合同条款：《民法典》第四百七十条

§ 合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

（一）当事人的名称或者姓名和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价款或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。



3、合同订立的程序：要约、承诺。

(1) 要约 (offer) 法条见下页

(可有多种名称：发价、发盘、报价、报盘)

①概念：希望和他人订立合同的意思表示，且该意思表示还符合：

a.内容具体确定；（且一般是向特定的人发出的）（注意：广告）

b.须有受要约人一旦接受、要约人即受该意思表示的约束。

（注意与要约邀请（Invitation for Offer）的区别。）第四百七十三条
要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。

（寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告是 offer？）



第四百七十一条 当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

第四百七十二条： 要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：

（一）内容具体确定；

（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

讨论：悬赏广告是要约吗？

案例1： 张某遗失了公文包一只，内有公司票据三张，票面金额达70万多元。包中另外还有手机、多张信用卡和个人珍贵资料若干。张某焦急万分，经友人提醒，在报纸上刊登悬赏广告，声称有谁捡到该包并将上述东西归还，愿支付赏金10万元。王某捡到了该公文包，看到广告后，将包和相关钱物归还，并要求张某支付10万元赏金。张某在拿到包后反悔，提出为感谢王某，愿支付5000元。王某不允，最终诉至法院。问：张某是否应该支付10万元赏金？为什么？（见书本分析）

§ 《民法典》第四百九十九条 悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

②要约何时生效

例2：中国A公司2月1日用航空挂号信向美国B公司发出一份要约，两地邮程为7天。美国B公司2月2号就知道了要约的内容，2月3日即回电，称接受。事后双方对合同是否成立发生争议。合同是否成立？

③要约的撤回和撤销

a要约撤回：到达之前（生效之前）将其收回；

b要约撤销：到达之后（生效之后）将其取消。

条件：**a**撤回通知应早于要约到达或者至少与要约同时到达；

b在受要约人接受之前可以撤销。

§ 注意：要约不得撤销的情形。

§ 民法典第四百七十六条：有两种情况，要约一旦生效就不能撤销：

§ 1，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不得撤销；

§ 2，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

例3: A在2月17日上午用航空挂号信的方式寄出一份实盘（要约）给B，A在发盘通知（要约）中注明“不可撤销”字样，规定受盘人（受要约人）B在2月25日前答复有效；但A又于2月17日下午用电报发出撤回通知，该撤回通知于2月18日上午送达B处。B于2月19日才收到A航空邮寄来的实盘（要约），收到后B随即于次日（2月20日）发出接受通知，该通知于2月24日到达A处。

事后，A、B双方对合同是否成立发生了纠纷。

问：本案合同是否成立？为什么？

§ **例4:** 我外贸公司于星期一上午10时以自动电传向英国伦敦商人发盘（发要约），公司原定价为每单位2000英镑CIF伦敦，经办人员在报价时发生了失误，将价格误报为每单位200美元CIF伦敦。问：

- 1) 若当天下午2时发现问题，我方该如何解决？
（注：该自动电传所发的要约于次日上午6时到达）；
- 2) 若第二天上午9时发现客户并未接受，如何处理？
- 3) 若第二天上午发现客户已经接受，如何处理？

④、要约的终止或失效

《民法典》第478条：四种情况1，拒绝要约的通知到达要约人；2，要约人依法撤销要约；3，承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4，受要约人对要约的内容作出实质性变更。

拒绝：有两种方式

a，直截了当地表示拒绝；

b，对发价人在发价中提出的交易条件进行讨价还价（eg:要求减价，增加或减少数量，变更交货期或交货的方式等等。即“还盘”，反要约（counter-offer）

§ 例6:

- § 甲公司7月5日向乙公司发价，截止日期（有效期）为8月1日。乙在7月12日收到该发价，7月14日电报拒绝。甲7月15日收到拒绝电报。若乙公司改变主意，于7月20日表示接受，该接受通知于7月31日到达甲公司处。
- § 问：合同是否成立？
- § 若乙公司于7月14日用挂号信表示拒绝，马上改变主意，于7月15日以电报的方式通知甲表示接受，合同是否成立？

§ 例7:

§ 我某出口企业于6月1日向英商发盘供应某商品，限6月7日复到有效。6月2日收到英商的电传表示接受，但提出必须降价5%。我公司正在研究如何答复时，由于该商品的国际市场发生了有利于英商的变化，该商又在6月5日来电，表示无条件接受我方6月1日的发盘。试问：我方应如何处理？为什么？

（2）承诺（Acceptance）

①含义

§ 承诺必须由受要约人作出

§ 承诺必须在合理期限内作出

§ 承诺的内容应和要约的内容相一致

②承诺方式：两种

A通知（声明）（**statement**）

B行为（**conduct**）

③承诺生效的时间

④对要约内容作了变更的承诺的效力

§ 第488条 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同**标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法**等的变更，是对要约内容的**实质性变更**。

§ 第489条 承诺对要约的内容作出**非实质性变更**的，除要约人及时表示反对或者要约表明**承诺不得对要约的内容作出任何变更外**，该**承诺有效**，合同的内容以承诺的内容为准。

⑤逾期的承诺

第486条 受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，**为新要约**；但是，要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。

第487条 受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，**除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺有效**。

⑥承诺的撤回

§ 2007年注册会计师考试单选题第9题:

2007年4月30日, 甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约, 乙于当日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙, 甲于5月3日才收到乙的短信, 并因个人原因于5月8日才阅读乙的短信, 后于9日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是()。

§ 缔约过失责任:

§ 民法典第500条

当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。

例9：被告崔某为一个体户，长期在外经商。2001年5月，被告返回家乡时，发现原告（某街道幼儿园）房屋年久失修，拥挤不堪，便主动提出愿意捐助100万元，为原告盖一幢小楼，但原告也必须同时为此投入一笔资金。原告当即表示同意。同年5月25日，原告又与被告协商资金到位的时间和开工时间，被告提出其捐款将在9月份到位，在此期间，原告务必做好开工的准备，包括准备必要的配套资金。同年7月，原告将原有的5间平房拆除，并于8月份向一家信用社贷款50万元，期限为1年。同年9月，原告找到被告，要求其资金尽快到位，但被告表示仅能捐出3万元。双方引发纠纷，诉至法院。

（详见书本）

§ 三、合同的效力

（一）附条件、附期限合同

请判断：“明年6月1日开始大选时合同生效”

“下次下雨时，本合同终止”

1、附条件合同

一个事实要成为条件须具备四个要件：

- a、须属于将来事实；
- b、须属于成就与否不能确定的事实；
- c、须属于合法事实；
- d、当事人意思表示无瑕疵。

2、附期限

见下页



- § 民法典第一百五十八条 民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。
- § 第一百六十条 民事法律行为可以附期限，但是根据其性质不得附期限的除外。附生效期限的民事法律行为，自期限届至时生效。附终止期限的民事法律行为，自期限届满时失效。
- § 附条件与附期限两者的根本区别：条件是将来不一定会发生的事，期限是将来肯定会发生的事。

具体来说，一个事实到底是条件还是期限，无非这样四种情况：

- (1) 时期确定，事情的发生也确定；
- (2) 时期确定，事情的发生不确定；
- (3) 时期不确定，事情的发生确定；
- (4) 时期不确定，事情的发生不确定。

例10：某地农民甲决定自己出资购买一套机器设备，办一个家庭塑料加工厂。因购买原料的资金不够，向他的朋友乙暂借2万元。甲对乙说，我付了钱就可以提货，预计两个月内安装调试完毕，2个月内开工没问题，到时候资金周转过来了，我保证把钱还给你。乙说，如果时间不长的话，我并不着急用钱，反正是好朋友嘛，利息我也不要了，不过你得先打一张借条。甲就写了一张借条给乙，注意借条（见书本）

设备运到后，甲发现眼下搞塑料制品生产还不如倒卖塑料加工原料钱来得快，所以甲就将自己购买的塑料加工机械租给了同村的塑料加工专业户丙，利用乙的这笔不要利息的借款，自己去倒卖塑料加工原料去了。

半年多了，乙看见甲有钱作买卖，却没钱还他，就上门索款。甲觉得赖帐更加有利，反正用多长时间也不用付利息。就说，原来在借条上写得很清楚嘛，设备安装调试好开了工的第二个月才还钱。现在我设备是有了，但是原料我还没有搞足，所以还开不了工，等几个月后，我把原料全部搞到了，开了工后，保证把钱还给你。乙看甲无诚意，就向人民法院提起了诉讼，要求法院强制某甲立即偿还2万元借款，并加收赖帐期间应付的利息。问：法院将如何处理？（见书本）

实例分析：签字盖章是否意味确认债务？

例11：甲公司与乙公司于2010年9月21日签订了一份购销合同，约定由甲向乙提供编码器，总价237000元。甲公司如期履约，但截止2011年1月26日，乙公司尚欠6万元未支付。

2014年4月11日，甲公司向乙公司发出了“付款通知”，本案表明乙公司尚欠款6万元，请乙公司确定还款日期。

乙公司在该“付款通知”中加盖公章，并附带注明，“因甲公司提供的设备存在质量问题，导致我方无法正常使用，请甲公司能尽快解决，若能在5月份通过验收，本公司一定结清余款。”此后，双方一直未联系。

2014年7月20日，甲公司因为迟迟拿不到货款，就诉乙公司还钱。诉讼中，乙公司律师坚持认为此案已过时效。

你认为本案该如何处理？

判决结果出乎很多人的意料：法院驳回了甲公司的诉讼请求。（本案例由杭州市西湖区人民法院提供）

法理分析：

在实践中，对于诉讼时效届满后的权利确认问题有两种做法：

一是债务人出具还款计划；

二是在催收函上加盖公章或者法定代表人签字。

这两种做法的法律性质是一样的，即：债务人放弃诉讼时效利益，愿意承担偿还责任。

本案中，乙公司在“付款通知”上签署的意见是一个附条件要约，是一个附条件的民事行为，并不是对原债务的重新确认，甲公司事后并未对设备进行维修，更不可能通过5月份的验收，所以重新确认原债务的条件没有成就。因此，本案诉讼时效已过，甲公司无法追回余款。

（二）无效合同

- 1、 定义。无效合同是指因违反法律、法规要求，国家不予承认和保护的，不发生法律效力力的合同。
- 2、 分类：部分无效；全部无效。 无效合同自始不发生法律效力。
- 3、 无效的法定情形：

注意《民法典》的变化：

§ 《民法典》减少了合同无效的法定事由

§ 《民法典》第144、146、153和154条明确了合同无效的五种法定事由，即：

§ 1.无民事行为能力人实施的民事法律行为无效；

§ 2.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效；

§ 3.违反法律和行政法规的强制性规定的民事法律行为无效；

§ 4.违背公序良俗的民事法律行为无效；

§ 5.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

§ 《民法典》生效后，《合同法》第52条第1-4款中“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益。”不再为合同无效的法定事由。该种立法上的变化，体现出了《民法典》鼓励交易的立法宗旨。

(三) 可撤销合同： 1、定义：指因合同当事人订立合同时意思表示不真实，有撤销权的当事人可行使撤销权，使已生效的合同变更或归于无效的合同。

§ 原合同法 第五十四条 注意 《民法典》规定的不同之处

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

(一) 因重大误解订立的；

(二) 在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

重大误解 显失公平 欺诈胁迫 乘人之危

《民法典》：第六章 民事法律行为 第三节 民事法律行为的效力

第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效：

§ (一) 行为人具有相应的民事行为能力；

§ (二) 意思表示真实；

§ (三) 不违反法律、行政法规的强制性规定，**不违背公序良俗**。

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。

第一百五十五条 无效的或者被撤销的民事法律行为**自始没有法律约束力**。

第一百五十六条 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

第一百五十七条 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，**行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。**

(三) 可撤销合同： 1、定义：指因合同当事人订立合同时意思表示不真实，有撤销权的当事人可行使撤销权，使已生效的合同变更或归于无效的合同。

§ 合同法规定：第五十四条 注意《民法典》的区别

下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

(一) 因重大误解订立的；

(二) 在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

重大误解 显失公平 欺诈 胁迫 乘人之危

§ 《民法典》对可撤销规则进行了变更

§ 《民法典》第147-151条明确了合同可撤销的五种法定事由，即：

§ 1.基于重大误解实施的民事法律行为；

§ 2.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为；

§ 3.第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的；

§ 4.一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为；

§ 5.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的。

§ 《民法典》对《合同法》中第54条的规定的可撤销事由拆分、细化并进行了相应修改，取消了当事人请求变更合同的权利，删除了“乘人之危”的可撤销情形、增加了第三方胁迫、欺诈的可撤销情形。

§ 同时，《民法典》第152条对《合同法》第55条的撤销权除斥期间也进行了相应修改（见下页）。相比于《合同法》中的规定，《民法典》对不同的撤销事由规定了不同的撤销权除斥期间，其中还明确了撤销权的最长除斥期间起算标准为客观标准，即自民事法律行为发生起5年。

§ 第一百五十二条 有下列情形之一的，撤销权消灭：

§ （一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权；

§ （二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；

§ （三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

§ 当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

《民法典》： 可撤销（合同）

第一百四十七条 基于**重大误解**实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十八条 **一方以欺诈**手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 **第三人实施欺诈行为**，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以**胁迫**手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十一条 一方**利用对方处于危困状态、缺乏判断能力**等情形，**致使民事法律行为成立时显失公平的**，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

（司考题） 甲公司在城市公园旁开发预售期房，乙、丙等近百人一次性支付了购房款，总额近8,000万元。但甲公司迟迟未开工，按期交房无望。乙、丙等购房人多次集体去甲公司交涉无果，险些引发群体性事件。面对疯涨房价，乙、丙等购房人为另行购房，无奈与甲公司签订《退款协议书》，承诺放弃数额巨大利息、违约金的支付要求，领回原购房款。经咨询，乙、丙等购房人起诉甲公司。下列哪一说法准确体现了公平正义的有关要求？（ ）（2011年卷三单选第1题）

- A.** 《退款协议书》虽是当事人真实意思表示，但为兼顾情理，法院应当依据购房人的要求变更该协议，由甲公司支付利息和违约金
- B.** 《退款协议书》是甲公司胁迫乙、丙等人订立的，为确保合法合理，法院应依据购房人的要求宣告该协议无效，由甲公司支付利息和违约金
- C.** 《退款协议书》的订立显失公平，为保护购房人的利益，法院应当依据购房人的要求撤销该协议，由甲公司支付利息和违约金
- D.** 《退款协议书》损害社会公共利益，为确保利益均衡，法院应当依据购房人的要求撤销该协议，由甲公司支付利息和违约金

【考点】 民法的基本原则、可变更、可撤销民事行为

§ 合同无效的法律后果： 被撤销的合同，同无效合同一样，自始不发生法律效力。

§ 自始无效

尚未履行的，
不得履行；已经履
行的，应当返还财
产或赔偿损失，使
当事人的财产关系
恢复到合同订立前
的状态。

§ 当然无效

不受法律保护
和承认，当事人不
能通过承认其效力
而使无效合同变为
有效合同，其无效
是绝对的。

（四）效力待定合同

一般情况下，一个有效合同，应具备三个条件：1、主体合法（具有民事权利能力和民事行为能力）；2、意思表示真实；3、不违反法律或社会公共利益。缺少其中的一个或几个，就可能导致合同无效或可撤销。但法律允许在几种情况下可以采取补救措施，使之成为有效合同：

（1）、限制行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效。（相对人也可以催告法定代理人在一个月内追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。见原《合同法》第47条）

§ 原合同法 第四十七条

限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

§ 《民法典》第一百四十五条规定，**限制民事行为能力人**实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；**实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。**

§ 相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。法定代理人**未作表示的，视为拒绝追认**。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

(2) 《民法典》第一百七十一条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。

相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。

相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

《民法典》第一百七十二条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。

(3)、无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

§ 原合同法 第五十一条 民法典有巨大变化

无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

(案例及相关讨论分析见书本)

§ 案例讨论六：二手房买卖的效力.ppt

§ 案例讨论七：经典的表见代理争议.ppt

例13: 2000年8月，张三（原告，现年11岁）去邻居家玩，发现床上放着一个精致的随身听，即在离开邻居家时随手拿走。张三因迷恋游戏机需要花钱，便将随身听以50元价格卖给了李四，卖时称随身听是捡的。次日，邻居找到张三的父亲索要随身听，张父方知张三卖给了李四。邻居当即表明，此随身听乃其好友从日本带回来送给他的礼物，价值人民币2700元。张父找到李四要求退款还物，李四承认50元买了张三的随身听，但他随即将此物以100元的价格卖给了一个不相识的人，已经无法退还。原告诉至法院，要求李四偿还该随身听的价款2700元。问：

- § 1) 张三订立的合同是否有效？为什么？
- § 2) 假如本案张三不是11岁而是19周岁，那么他与李四订立的合同应如何认定？
- § 3) 你认为本案应如何处理？

四、合同的履行

1、定义

2、合同履行的原则

- (1) 当事人就有关合同约定不明确时的履行
- (2) 执行政府定价或政府指导价的合同的履行

3、抗辩权的行使

- (1) 同时履行抗辩权
- (2) 后履行抗辩权
- (3) 不安抗辩权
(先期违约/预期违约)

原合同法第68条 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

- (1) 经营状况严重恶化；
- (2) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
- (3) 丧失商业信誉；
- (4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

原合同法 第69条 当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。

§ 《民法典》对不安抗辩权的规定：

§ 第五百二十七条 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

§ （一）经营状况严重恶化；

§ （二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

§ （三）丧失商业信誉；

§ （四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

§ 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

§ 第五百二十八条 当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

§ 应当先履行的当事人，发现对方有下列四种情形之一的（1、经营状况严重恶化、2、转移财产抽逃资金以逃避债务；3、丧失商业信誉；4、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形）→可以中止履行 →

中止履行后，若 →

a对方提供适当担保的→应当恢复履行；

b若无确切证据中止履行的→应承担违约责任；

c若对方在合理期限内未恢复履行能力且未能提供适当担保的→中止履行一方可以解除合同。

§ 例14：对方出了问题，我该不该履行合同？

浙江省杭州市龙井山茶实业有限公司与日本H株式会社签订了一份茶叶的购销合同，合同约定5月份从上海发货。合同签订后，4月底，杭州龙井公司得知了该日本公司被申请破产的消息，遂决定停止发货。问：

- 1、杭州龙井公司的做法有无法律依据？
- 2、若杭州龙井公司在消息不确切的情况下擅自停止发货，要承担什么责任？
- 3、若日本公司以其在杭州的分公司的一批机器设备作为抵押担保，如担保是充分的，杭州公司应该怎么做？
- 4、若日本公司确实被宣告破产，且也未能提供任何担保，杭州公司可以怎么做？

4、保全措施

- (1) 代位权：指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。 详见合同法第73条
- (补充：所谓专属于债务人自身的债权，是指基于抚养关系、扶养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权，以及请求给付劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利。
- (2) 撤销权：指因债务人放弃其到期债权或无偿转让其财产，对债权人造成损害的，或者债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销该债务人的行为。（注意撤销权行使的时间）

五、合同的担保

1、概述

（既可以是单独订立的合同，也可以是主合同中的担保条款） 参考法律：1995年6月30日颁布的《担保法》。民法典实施后，担保法废止！

方式：五种，分别是

保证、

抵押、

质押、

留置

定金。

2、担保的主要方式

(1) 保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的~~行为~~。

保证人

- § 具有~~代为清偿债务能力~~的法人、其他组织或公民，可以做保证人。
- § 国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的除外。
- § 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。
- § 企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人，但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
- § 任何单位和个人不得强令银行等金融机构或企业为他人提供保证。

§ 注意一般保证和连带责任保证；注意民法典实施后的巨大变化

§ 一般保证

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。

§ 连带责任保证

债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

保证期间：保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

§ 保证责任：

§ 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

§ 保证合同另有约定的，按照约定。

§ 当事人对保证担保的范围没有约定或约定不明确的，保证人应对全部债务承担责任。

§ 当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

担保须注意的问题

3、担保期间的约定注意陷阱

如：约定“担保期间截至主合同履行期届满之日”。

例：A公司向信用社贷款20万元，期限为一年，B公司提供保证担保，约定承担保证责任的期间和贷款期间相同。2011年1月5日，贷款到期，A公司无力归还。7月11日，信用社起诉保证人还款。怎么处理？（见书本解释）

§ **例：**某新区管委会副主任黄某，2010年3月向某信用社贷款60万元，贷款期限为一年，谢某为其签字提供连带责任保证。贷款到期后，黄某没有按期归还。信用社考虑到借款人的情况，对其60万元贷款采取消息转本。黄某专门为此打电话给谢某，要求谢某继续为其提供保证，谢某当即表示同意。后黄某再次违约，信用社起诉保证人谢某。谢某拒绝承担保证责任。问：如何处理？

§ **担保法第24条规定：**“债权人与债务人对主合同进行变更的，应当取得保证人的书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。”

(2) 抵押：抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，而将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。债务人或第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。

抵押合同与抵押物登记：

§ 抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同。

§ 当事人以法定须办理抵押登记的财产进行抵押的，应办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。

§ 当事人以其他财产抵押的，可以自愿向抵押人所在地的公证部门办理抵押物登记。抵押合同自签订之日起生效。

注意与质押的区别；

(3) 质押：

(质押合同是实践合同，自质物移交于质权人占有时生效。)

出质人代质权人占有质物的，质押合同不生效。质权人将质物返还于出质人后，其质权不得对抗第三人；出质人以间接占有的财产出质的，质押合同自书面通知送达占有人时视为移交；占有人收到出质通知后，仍接受出质人的指示处分出质财产的，该处分无效。

另外，权利质押中，票据、单据中载明的兑现或者提货日期先于债务履行期的，质权人可以在债务履行期届满前兑现或者提货，并与出质人协议将兑现的价款或者提取的货物用于提前清偿所担保的债权或者向与出质人约定的第三人提存。

动产质押（转移占有权）

权利质押（可转让的权利 如票据等 有价证券、

注意事项

股份\股票、知识产权）

形式	质权人	质押合同	出质人
	（债权人）		（债务人、第三人）

质押合同生效时间的具体规定（交付或登记时生效）

约定：债务人履行期届满质权人未受清偿，质物所有权转移给质权人所有。是否有效？

质物灭失所得的赔偿金应当作为出质财产

§ 权利质押包括：以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质；以依法可以转让的股份、股票出质；以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质；以依法可以质押的其他权利出质。

(4) 留置 (注：同一财产法定登记的抵押权与质权并存时，抵押权人优先于质权人受偿；同一财产抵押权与留置权并存时，留置权人优先于抵押权人受偿。)

§ 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该项财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该项财产的价款优先受偿。

§ 因保管合同、运输合同、加工承揽合同以及法律规定可以留置的其他合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置，但当事人可以在合同中约定不得留置的物。

§ 留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额。留置权人负有妥善保管留置物的义务。

(5) 定金 **定金**是当事人一方为了证明合同的成立和保证履行，先行给付对方一定数额的货币。债务人履行债务后，定金应抵作价款或收回。

§ 定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。

§ 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的**20%**。

(注：当事人一方不完全履行合同的，应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例，适用定金罚则。)



定金罚则（定金罚）：《民法典》第586条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。

§第587条 债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。**给付定金的一方**不履行债务或者履行债务不符合约定，**致使不能实现合同目的**的，**无权请求返还**定金；**收受定金的一方**不履行债务或者履行债务不符合约定，**致使不能实现合同目的**的，**应当双倍返还**定金。

§第586条 第二款：定金的数额由当事人约定；但是，**不得超过主合同标的额的20%**，**超过部分不产生定金的效力**。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

§第588条 当事人**既约定违约金，又约定定金**的，一方违约时，对方可以**选择适用**违约金或者定金条款。

§ 案例：涂佳向胡泉借款10万元，借款日期为2013年10月5日至2014年1月4日。并约定，如不按期还本付息，对逾期借款部分按借款利率每天加收20%的违约金，原利息照常计算。涂佳的姐夫王成钢在担保人处签名按手印，并随后手写“此担保自借款期限过期则作废”。

§ 借款到期后，涂佳无力归还，胡泉于次月25日起诉要求保证人王成钢承担还款责任。王成钢予以拒绝，并表明理由：借条上已经明确注明他的担保期限就是借款的期限，现在期限已过，他不应该承担保证责任。问：

§ （1）本案王成钢是否应该承担保证责任？

§ （2）若担保到期后，涂佳打算延期一年还款，胡泉也予以同意，并打电话要求王成钢继续为借款提供担保，王成钢当即表示同意。事后涂佳无法偿还借款，王成钢拒绝承担担保责任。请问王成钢是否应该承担担保责任？

§ （请见书本分析《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年版周黎明著）

§ 问题：民法典实施后，有何变化？请思考！

例：赵男与钱女、孙男、李女为某大学同事，其中钱女和孙男为夫妻。某年3月，钱女和孙男找到李女，期望李女出面帮助他们向赵男借钱。四人相约见面，经协商后，赵男借给钱女和孙男5万元，还款日期为同年9月份，并由李女在借据上签名作担保。一个星期后，钱女和孙男又找到赵男，向他再借了3万元，并以一辆9成新的奥拓轿车作抵押。双方约定，次年3月全部借款还清。但拖至次年底，赵男多次催要，钱女和孙男一直未予归还。于是赵男诉至法院，要求两人归还借款，并按银行同期贷款利率偿付逾期利息。据查，钱女和孙男确实无力还款。问：

- 1) 简述本案当事人之间所涉及的法律关系。
- 2) 李女对借款承担的保证是一般保证还是连带责任保证？是否对两次借款都承担责任？
- 3) 赵男可以通过什么方式实现抵押权？哪种方式更为简便？
- 4) 赵男的债权如何实现？

4、质押和抵押的区别，质押的生效时间；

例：俞某向徐某借款2万元，订立质押合同约定俞某以5只华为某型号手机作担保。质押合同签订后，2万元即交付，但5只手机一直未交付。徐某是否有权要求俞某交付5只手机？

必须办理登记手续的质押：股票、知识产权。

5、留置的适用及定金的限额；留置的范围由原来的合同约定扩大到“合法占有”。留置财产的处置期间现在可以约定，未约定的为至少两个月以上，现货易腐等不易保存的除外。

6、同时存在多个担保权时，清偿的先后顺序。

例：司法考试题：同升公司以一套价值100万元的设备作为抵押，向甲借款10万元，未办理抵押登记手续。同升公司又向乙借款80万元，以该套设备作为抵押，并办理了抵押登记手续。同升公司欠丙货款20万元，将该套设备出质给丙。丙不小心损坏了该套设备送丁修理，因欠丁5万元修理费，该套设备被丁留置。关于甲、乙、丙、丁对该套设备享有的担保物权的清偿顺序，下列哪一排列是正确的？（ ）（2011年卷三单选第7题）
A.甲乙丙丁
B.乙丙丁甲
C.丙丁甲乙
D.丁乙丙甲

【考点】担保物权的竞合 【解析】《物权法》第二百三十九条规定，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。据此可知，本题中丁享有的留置权最先得到受偿。
《担保法解释》第七十九条第一款规定，同一财产法定登记的抵押权与质权并存时，抵押权人优先于质权人受偿。据此可知，本题中乙享有的已登记的抵押权优先于丙享有的质权受偿，丙享有的质权优先于甲享有的未登记的抵押权受偿。综合上，甲、乙、丙、丁对该套设备享有的担保物权的清偿顺序是丁、乙、丙、甲。
注意民法典实施后的变化：登记的抵押权并非优先于质权了

六、合同的变更和转让

1、债权转让；2、债务转让；3、债权债务一并转让。

（补充：根据合同的性质不得转让的，主要是指基于当事人特定身份而订立的合同，如出版合同、赠与合同、委托合同、雇用合同等。）

七、合同的终止（六种情形。注意单方解除合同的5种情况）

§ 《民法典》第五百五十七条 有下列情形之一的，债权债务终止：

§ （一）债务已经履行；

§ （二）债务相互抵销；

§ （三）债务人依法将标的物提存；

§ （四）债权人免除债务；

§ （五）债权债务同归于一人；

§ （六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

§ 将原合同法的第九十一条 内容作了调整，删除了合同解除这一项。

§ 民法典第五百六十三条（原合同法第九十四条）

有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

- （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
- （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
- （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
- （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
- （五）法律规定的其他情形。

§ 债务人依法将标的物提存，就是债务人将无法清偿的标的物交有关部门保存以消灭合同关系的行为。

§ 《民法典》第五百七十条 有下列情形之一的，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：

§ （一）债权人无正当理由拒绝受领；

§ （二）债权人下落不明；

§ （三）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人；

§ （四）法律规定的其他情形。

标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。

§ 混同

§ 债权债务同归于一人，即债权债务的混同，债的关系须由债权人和债务人同时存在方能成立，当债权人和债务人合为一人时，债权债务就当然消灭。

八、违约责任

1、定义

违约责任，简单的说，是指违反合同的民事责任。

具体是指合同当事人一方不履行或不适当履行合同义务时，依照法律规定或合同约定应承担的责任。



3、承担违约责任的形式

- (1) 继续履行；
- (2) 采取补救措施；
- (3) 赔偿损失（支付赔偿金）；
- (4) 支付违约金
- (5) 适用定金罚则

（民法典第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：

（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；
（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。）



(1) 继续履行

- ◆ **继续履行**是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，经另一方当事人的请示，法律强制其按照合同的约定继续履行合同的义务。
- ◆ **《民法典》第五百八十条（原合同法110条）** 当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：
 - ◆ （一）法律上或者事实上不能履行；
 - ◆ （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；
 - ◆ （三）债权人在合理期限内未请求履行。
- ◆ 有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。
- ◆ 可见：继续履行须符合以下构成要件：
 - 1、合同的标的为非金钱债务。
 - 2、当事人一方违约。
 - 3、守约方在合理期限内请求。
 - 4、债务人的继续履行须为可能。



(2) 采取补救措施

- ◆ 第五百八十一条 当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。
- ◆ 第五百八十二条 履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。



(3) 赔偿损失

- ◆ 赔偿损失是各国法律普通确认的一种违约责任形式。是指合同当事人一方不履行合同或者不适当履行合同给对方造成损失的，应依法或依照合同约定承担赔偿责任。它以金钱赔偿为原则，以实物赔偿为例外。
- ◆ 但是要注意精神损害赔偿问题！



注意赔偿的额度（赔多少？）

- ◆ 原合同法113条规定：
- ◆ 《民法典》第五百八十四条：
- ◆ 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
- ◆ #案例讨论19：可得利益损失的计算问题.ppt



(4) 违约金

- ◆ **违约金**是指一方当事人违反合同，依照约定或者法律规定向对方支付一定数额的金钱的责任形式。
- ◆ 违约金的性质：
 - 1、补偿性
 - 2、惩罚性。

问题：违约金过高或者低于实际损失时，
如何处理？ # 案例讨论20：违约金过高.ppt



最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)

- ◆ 第二十七条 当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。
- ◆ 第二十八条 当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。
- ◆ 第二十九条 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
- ◆ 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。



(5) 定金

- ◆ 定金既是一种**债的担保形式**，又是一种**债不履行时的责任形式**。
- ◆ 定金一个最大的特点：**具有强烈的惩罚性！**
定金作为一种**违约责任形式**，其适用不以实际发生的损害为前提，即无论一方的违约是否造成对方损失，都可能导致定金责任。
- ◆ 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的**20%**。
- ◆ 注意：**订金\留置金\担保金\保证金\订约金\押金**，均不具有定金作用。



相关法律条文：《合同法》第一百一十六条：

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。

定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

第五百八十七条 债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

第五百八十八条 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

例21: 甲公司与乙公司签订了一份经济合同，合同约定违约金为5000元。现问：

- (1) 由于甲公司违约，未能履行合同，致使乙公司损失7000元，如何承担违约责任；
- (2) 若合同约定违约金为1.2万元，实际损失为1万元，如何承担违约责任？
- (3) 若（2）中的违约金为12万元呢？
- (4) 若合同中约定，由乙公司支付甲公司定金1万元，并约定违约金为7000元，实际损失为7000元，如何处理？

例22：某年，某市百货公司与该市的家用食品机械厂签订了一份购销合同，合同规定，由家用食品机械厂售给百货公司微型绞肉机1000台，每台100元，总价款为10万元。交货期为6月底以前。百货公司支付给家用食品机械厂定金1万元，并约定违约金为不能履约部分的5%。合同签订后，至合同规定的交货期6月底，家用食品机械厂只交付了500台。在百货公司的一再催促之下，一直拖到七月底，家用食品机械厂才将其余的500台交足。8月份，百货公司在支付货款时，扣除了定金2万元，扣除违约金5000元，支付了7.5万元。问：

- 1、百货公司的做法能否获得法律的支持？为什么？
- 2、若家用食品机械厂一直没有交付剩余的500台，怎么处理？

（请见书本分析）



4、不可抗力

- ◆ 定义：合同法117条第二款规定：
- ◆ 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
- ◆ 自然因素；社会因素。
- ◆ 注意法律的相关规定：
- ◆ 合同法第117条 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
- ◆ 民法典第180条 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
- ◆ 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

- 
- ◆ 合同法：第一百一十八条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
 - ◆ 民法典：第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
 - ◆ 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

4、不可抗力：不能预见、不能避免、不能克服（第117条、118条）

例23：原告：香港某贸易公司（买方）被告：上海某集团公司（卖方）

原、被告于某年9月4日签订了一份购买对虾的合同，总金额为15万美元，价格条件FOB上海，不可撤销信用证支付。

次年1月17日，原告起诉称：合同履行中，我公司按合同如期开出了不可撤销信用证，但被告在合同规定的期限内未能交货。与此同时，被告提出提高价格的要求，我公司未予同意。此后，我公司要求被告依合同约定支付违约金，被告不加理睬。被告在无货供应的情况下，一再拖延，未能及时把无货情况及其原因通知我方，给我方造成了经济损失。被告的行为已经构成违约。请求法院判令被告赔偿损失7.5万美元。

被告答辩称：我公司确与香港公司订立上述合同。但在合同履行中，因我公司的货源是辽宁省辽粤公司提供的，签约当年秋季，产地受洪水、气候影响，对虾大幅度减产，地方政府下达了严格控制对虾出口的通知。因此，辽粤公司无法向我公司供货，致使未能如期交货，确系遇到了“无法预见和防止的客观情况”，为不可抗力的影响，并非我公司的故意和过失。

请问：被告提出的抗辩理由是否成立？为什么？

例24: 某年10月12号，广西甲公司与香港乙公司签订了一购销合同，由甲公司向乙公司提供火鸡一批，交货地点在深圳某码头，交货时间为11月29日。合同签订后，甲公司于11月30日委托广西某运输公司将货物运往深圳。在运输途中，因某公路段出现泥石流，被迫耽误了两天。货物至12月3日才运到深圳，但已误了预定去美国的班轮。由于该火鸡是用于圣诞节前销售的，若等下一个航班则不可能将货物在圣诞节前运到。为此，乙公司要求解除合同，并要求甲公司赔偿损失。

- 现问：
- 1) 甲公司是否构成违约？为什么？
 - 2) 甲公司可否因泥石流而免责？为什么？
 - 3) 乙公司解除合同的要求能否成立，为什么？

§ 请参阅书本 一个关于买卖合同的经典案例

合同法分则： 赠与合同

请考虑两个问题：

1、 赠与能不能撤销？

例25：张晓春承诺资助一对经济拮据的母子，并随之与该母子签订了无偿资助协议。一年后，张晓春经营个人资产不善，陷入严重亏损中。问：张晓春可以不再履行该赠与合同吗？

2、 赠与物出现瑕疵怎么办？

例26：许艳用王谦赠送的照相机拍摄，因相机质量问题，冲洗的相片模糊不清，致使其一些珍贵的、精彩的瞬间无法保存下来。许艳要求王谦赔偿损失，该请求是否合法？

例27: 原告：朱某 被告：某市红十字会

原告朱某为某公司法定代表人，某年10月因公事出差，期间公司业务由公司副总裁黄某全权代理，并经公司正式发文公告。

10月15日，被告某市红十字会邀请该公司派员参加一个慈善晚会。晚会上黄某在现场气氛的感染下，拍板表示，该公司捐款10万元实物用于社会公益事业。10月25日，被告从原告仓库中提取棉被1000条，共计价值人民币9万8千元。11月下旬，朱某出差回来，得知此事后，大为不满，遂派秘书书面通知被告红十字会，要求撤销赠与，并返还捐赠的棉被，原因是黄某并非公司法定代表人，其行为不能代表公司。被告红十字会则认为，黄某在代行公司法定代表人权利期间以公司名义进行的活动是公司行为，不能撤销赠与。

问：1) 原告能否要求撤销赠与？

2) 若原告捐赠的棉被质量不合格，是否应承担瑕疵担保责任？

几个相关问题:

- 1、赠与合同是单务无偿合同
- 2、赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与，但具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或经公证的赠与合同，不可撤销；且赠与人不交付赠与财产的，受赠人可以要求交付。
- 3、因赠与人故意或重大过失致使赠与的财产毁损、灭失的，赠与人应承担损害赔偿责任。
- 4、赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。赠与人故意不告知瑕疵或保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应承担损害赔偿责任。

§ 借款合同：

§ **例28：** 张某与李某签订一份借款合同，合同约定由张某向李某提供5万元借款。双方对还款日期没有作出约定。另外，双方约定的利息为同期银行存款利息的3倍，但若同期银行利息有变化致使年利息低于6%，则按6%计算。在签订合同后，李某在交付借款时，先行扣除了一年的利息，交付张某4万7千元。问：

- § 1、借款合同中未明确约定还款期限的，如何确定还款期限？
- 2、对李某交付借款时，在本金中预先扣除利息的行为如何认定？
- 3、若双方未约定利息条款，如何处理？

租赁合同：

例29：2010年6月，周某与某房地产公司签订了一份车库租赁合同，合同约定租赁期限为50年，租金共计16万元。并约定，租赁期间，周某只有车库的使用权，而没有所有权。承租人周某在租赁期间，在没有征得出租人同意的情况将车库加以装修。半年后，又将车库转租给张某，期限为1年。

§ 2017年7月，房地产公司打算出卖车库。周某提出愿意以20万元购买，但房地产公司将车库以20万元卖给了李某。周某不服，双方发生争议。

保管合同：

例30：李某下班后，开车来到一家大型超市购物，将轿车停在超市的收费停车场。李某在作了登记并支付了停车费后，进入超市购物。半个多小时后，李某从超市出来，发现轿车的前门窗玻璃被砸碎，放在前座上的皮包被偷走，内有现金12000多元。李某要求超市赔偿汽车修理费2800元、现金被盗损失12500元。超市认为自己只是提供一个停车场所方便客户购物，对车子被砸和钱物被盗不承担责任。李某遂起诉至法院。问：

- 1、你认为此案该如何处理？
- 2、若超市是无偿提供保管呢？
- 3、在保管合同中，若有第三人对保管物主张权利时，保管人该怎么办？

（合同法分则的具体内容及案例分析请参阅 书本分析）

第三章 企业法

（配套教材《经济法理论与实务》 浙大出版社周黎明著2018年11月第一版）

第一节 企业法概述

企业法主要关注个人独资企业法、合伙企业法。

一、企业与企业法

（一）企业的概念

企业是依法成立，具有一定的组织形式，独立从事商品生产经营、服务活动的经济组织。

企业的特征

- 😊 企业是经济组织。应有自己的机构及工作场所，拥有相应的财产。
- 😊 以营利为目的的从事生产经营或服务活动的社会经济组织。
- 😊 企业是实行独立核算的经济组织。
- 😊 企业是依法设立的经济组织。

注意：企业与公司的区别

(二) 企业的分类

- ☁ 按企业的**所有制性质**不同分：
 - 全民所有制企业
 - 集体所有制企业
 - 私营企业
 - 混合所有制企业等
- ☁ 按企业的**所属行业**的不同分：
 - 工业企业
 - 商业企业
 - 农业企业等。
- ☁ 按企业**出资者**的不同分：
 - 内资企业
 - 外资企业等。
- ☁ 按企业的**组织形式**的不同分：
 - 独资企业
 - 合伙企业
 - 公司制企业等。
- ☁ 按企业的**法律地位**的不同分：
 - 法人企业
 - 非法人企业

（三）企业的权利与义务

- 😊企业的权利是指法律赋予企业能够为或不为一定行为，以及要求他人为或不为一定行为的资格。
- 😊企业的义务是指企业必须为或不得为一定行为的责任。
- 😊企业的法律地位不同，其权利和义务的具体内容也各有差异。

二、我国企业法律制度体系

- 指规范企业的设立、组织结构、明确企业权利义务关系的法律规范的总称。主要包括：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人独资企业法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》等法律、法规，以及与企业相关的规章和规范性文件。

第二节 个人独资企业法

一、个人独资企业法概述

(一) 概念：

个人独资企业是在中国境内依法设立的，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

（二）企业特征：

- 1、个人独资企业的投资主体是一个自然人。而且只能是一个自然人，不包括单一的法人或其他社会团体组织。
另，外商独资企业也不能作为个人独资企业。
- 2、个人独资企业由投资者（企业主）个人拥有和控制。
- 3、个人独资企业是营利性的经济实体，内部机构设置简单，经营管理方便灵活。
- 4、是非法人企业，个人独资企业以投资人的全部个人财产对企业的债务承担无限责任。

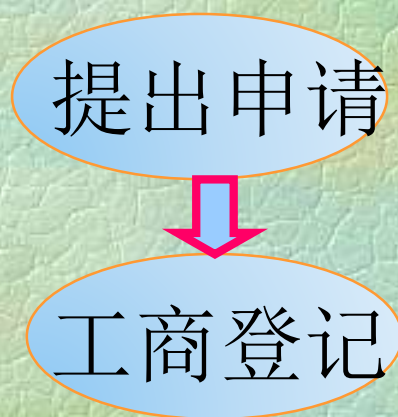
二、个人独资企业的设立

（一）设立条件

- ✿ 投资人是一个自然人，且只能是中国公民。
- ✿ 有合法的企业名称。不得使用“有限”、“有限责任”或“公司”字样。
- ✿ 有投资人申报的出资。出资方式：货币、实物、土地使用权、知识产权或其他财产权利等。
- ✿ 有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。
- ✿ 有必要的从业人员。



（二）个人独资企业的设立程序



个人独资企业的营业执照签发日期，为个人独资企业成立日期。

三、个人独资企业的经营管理

- 可以自行管理企业事务，也可委托其他具有民事行为能力的人负责企业事务的管理。委托时应当签订书面合同，明确委托内容和授权范围。投资人对受托人或被聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。
(关键是解决实际问题，可通过案例理解)
- 个人独资企业投资人在申请企业设立登记时明确以其家庭共有财产作为个人出资的，应当依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任。

四、个人独资企业的解散和清算

（一）个人独资企业的解散

指个人独资企业终止活动使其民事主体资格消灭的行为。

解散情形有四种：

- ❶ 投资人决定解散；
- ❷ 投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承；
- ❸ 被依法吊销营业执照；
- ❹ 法律、行政法规规定的其他情形。

（二）个人独资企业的清算

1、通知和公告债权人：

个人独资企业解散，应当由投资人自行或者申请人民法院指定清算人进行清算。

2、财产清偿顺序：

- （1）所欠职工工资和社会保险费用；
- （2）所欠税款；
- （3）其他债务。

个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。

3、清偿期间对投资人的要求：

清算期间，个人独资企业不得开展与清算目的无关的经营活动，在按法律规定的财产清偿顺序债务前，投资人不得转移、隐匿财产。

4、投资人的持续清偿责任：

个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在5年内未向债务人提出偿债请求的，原投资人对债权人的责任消灭。

5、注销登记

个人独资企业自清算结束之日起15日内，向原登记机关申请注销登记。

- 案例：原告：××星光公司（以下简称星光公司）
- 被告：××塑料厂（以下简称塑料厂）
- 被告：赵举人（塑料厂的投资人）
- 被告××塑料厂系个人独资企业，因经济往来欠原告货款**10万元**，被告投资人赵举人以塑料厂名义和原告于**2015年1月**达成还款协议，约定余款于**2015年3月**前还清。
- **2014年11月8日**，赵举人将塑料厂转让给李自成，协议约定转让之后所发生的债权债务由李自成承担。
- 协议签定的当日，塑料厂即在工商部门办理了企业投资人变更登记。
- 后原告依还款协议要求被告塑料厂偿还到期债务，但被告以投资人变更为由拒绝偿还。原告起诉两被告。
- 被告塑料厂辩称，塑料厂为个人独资企业，原厂负责人是赵举人，依据协议的约定，转让前的债务应由赵举人承担。
- 被告赵举人辩称塑料厂负责人的变更不能影响债务的承担方式，故应由企业承担清偿责任。本案该如何处理？
- （请见书本《经济法教程》浙江大学出版社**2015年8月**版 周黎明著 **P107**分析）

第三节 合伙企业法

一、合伙企业法律制度概述

（一）概念

指自然人、法人和其他组织依法（《合伙企业法》）在中国境内设立的由各合伙人订立合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对合伙企业债务承担无限连带责任的营利性组织。

(二) 合伙企业的类型

1、普通合伙企业

由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

一个合伙人或者数个合伙人在执行活动中**因故意或者重大过失**造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

合伙人**因非故意或重大过失**造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限责任。

2、有限合伙企业

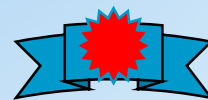
由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

法律对有限合伙人做了特殊的规定：

- ① 不得以劳务出资；
- ② 不执行合伙事务不得对外代表有限合伙企业；
- ③ 除合伙协议另有约定外，有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，可以自营或者同他人合作经营与本企业的竞争的业务，还可将其在有限合伙企业中的财产份额出质等等。

■ 二、合伙企业的法律特征

- ✿ 具有两个以上的投资人共同投资兴办
- ✿ 合伙人以书面合伙协议确定各方出资、分享利润和亏损负担等
- ✿ 普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，有限合伙对合伙债务承担有限责任
- ✿ 合伙属于人合型企业



三、合伙企业的成立

成立条件：

- 1、有两个以上合伙人，合伙人为自然人，应当具备完全行为能力，除法律另有规定外，有限合伙企业应当有两个以上五十人以下；
- 2、有书面合伙协议；
- 3、有合伙人认缴或实际缴付的出资；
- 4、有合伙企业的名称和经营场所；
- 5、法律法规规定的其他条件。

在合伙企业名称中应当注明“普通合伙”字样，有限
合伙企业名称中注明“有限合伙”字样。

四、合伙企业财产、债务

(一) 财产构成 

(二) 合伙企业财产的性质 

(三) 合伙企业财产的转让 

(四) 合伙企业的债务 

财产构成

1、合伙人的出资。

以合伙企业名义取得的收益。

3、依法取得的其他财产。

合伙企业财产的性质

合伙企业的财产只能由全体合伙人共同管理和使用；在合伙企业存续期间，除非有合伙人退伙等法定事由，合伙人不得请求分割合伙企业的财产。

此财产具有共有性质，对合伙财产的占有、使用、收益和处分，均应当依据全体合伙人的共同一致进行。

合伙企业财产的转让

限制性规定：



- 1、存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部财产份额时，须经其他合伙人一致同意；
- 2、合伙人之间转让在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当通知其他合伙人；
- 3、合伙人依法转让其财产份额时，在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。
- 4、有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额，但应当提前三十日通知其他合伙人。

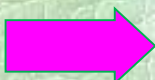
合伙企业的债务

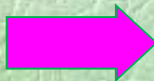
合伙企业的财产是合伙企业对外承担债务的基础，合伙企业首先以合伙财产偿还企业债务，在合伙企业的财产不足以清还合伙企业债务的情况下，因合伙人对合伙企业债务负有无限连带责任，合伙人应当以其在合伙财产份额以外的个人财产清偿合伙企业的债务。

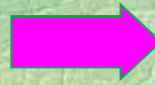
合伙企业的债权人有权向合伙人全体或者任意一名合伙人提出偿还全部债务的请求，合伙人不得以合伙协议约定的合伙人之间的债务承担份额抗辩，但是合伙人有权向其他合伙人追偿由于其承担连带责任，所清偿的数额为超过其应当承担的数额的部分。

五、合伙企业的事务执行

(一) 合伙事务执行的形式 

(二) 合伙人在执行合伙事务中的权利和义务 

(三) 合伙事务执行的决议办法 

(四) 合伙企业的损益分配 

合伙事务执行的形式

- 1、全体合伙人共同执行合伙企业事务-----是最基本形式
- 2、委托一名或数名合伙人共同执行合伙企业事务，对外代表合伙企业。未经委托执行合伙企业事务的其他合伙人，不再执行合伙企业的其他事务。



但企业的下列事务必须经全体合伙人一致同意：

- A：处分合伙企业的不动产；
- B：改变合伙企业的名称；
- C：转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
- D：向企业登记机关申请办理变更登记手续；
- E：以合伙企业名义为他人提供担保；
- F：聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员；
- G：依照合伙协议约定的有关事项。

1、权利：

- (1) 合伙人对执行合伙事务向享有同等的权利；
- (2) 执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业；
- (3) 不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况；
- (4) 各合伙人有权查阅合伙企业的帐簿和其他有关文件；
- (5) 合伙人提出异议权和撤销委托事务权。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

2、义务：

- (1) 合伙事务执行人向不参加执行事务的合伙人报告企业经营状况和财务状况。
- (2) 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。
- (3) 合伙人不得同本合伙企业进行交易。《合伙企业法》规定，除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。
- (4) 合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

合伙事务执行的决议办法

合伙企业法另有规定或者合伙协议中另有约定外，经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。

合伙企业的损益分配

- 1、合伙损益内容：一是合伙利润。二是合伙亏损。合伙企业利润包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。
- 2、合伙损益分配原则：依照合伙协议约定的比例分配和负担。未约定或约定不明的，由合伙人协商解决；协商不成，按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由各合伙人平均分配、分担。合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

六、入伙与退伙

(一) 入伙

是指合伙关系存续期间，现有合伙人以外的人加入而成为新的合伙人。

入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任，但是入伙协议另有约定的，从其约定。新入伙的合伙人一旦入伙就应当对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。



连带责任，是指依照法律规定或者当事人的约定，两个或者两个以上当事人对其共同债务全部承担或部分承担，并能因此引起其内部债务关系的一种民事责任，它属于共同责任中的一种。

（二）退伙

☁ 是指合伙关系存续期间，部分合伙人退出合伙企业，解除其合伙身份；如果全体合伙人宣布退出合伙，应构成合伙的解散，而不应当是做退伙。

☁ 退伙分为三种情况：

- 法定退伙
- 约定退伙
- 除名退伙

七、合伙企业的解散与清算

（一）解散的情形

合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

- 1、合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
- 2、合伙协议约定的解散事由出现；
- 3、全体合伙人决定解散；
- 4、合伙人已不具备法定人数满30天；
- 5、合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
- 6、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- 7、法律、行政法规规定的其他原因。

（二）合伙企业财产清偿顺序：

1、确定清算人

2、清算人责任

3、通知和公告债权人

4、财产清偿顺序

（1）支付清算费用；

（2）合伙企业所欠招用职工的工资和社会保险费用；

（3）法定补偿金；

（4）合伙企业所欠税款；

（5）合伙企业债务；

（6）返还合伙人的出资。

5、注销登记

6、合伙企业不能清偿到期债务的处理

合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人们法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对企业债务仍应承担无限连带责任。

■ 案例分析：某A、某B和某C为新锐之光普通合伙企业的合伙人。三人各出资10万元，并约定按出资比例承担盈亏。由于经营不善，合伙企业严重亏损，欠债权人45万元货款无法偿还，债权人向某A、某C主张债权时，他们以企业已破产解散拒绝偿还；债权人向某B主张全部债权时，某B以合伙协议约定按出资比例承担盈亏为由，只偿还了自己应承担的份额，即15万元。请问：

- 1、上述合伙人的理由是否合法？为什么？
- 2、合伙企业的债务应如何承担？
- （请见书本分析）

第四章 公司法

本课件配套教材：《经济法理论与实务》浙大出版社2018年11月第一版 周黎明著，2019年第二次印刷新形态教材版。2021版出版中。

第一节 概述

一、公司与公司法

1、公司的概念

2、公司的特征（企业法人、依法设立、具有法定数额的股东、有限责任）

3、公司法（1993年12月29日颁布建国以来第一个公司法，94年7月1日实施。99年12月29日作了修订。2005年10月27日修订，2006年1月1日施行。2013.12.28修订2014.3.1实施）

二、公司的分类（多种分类，最常见的是按照财产责任形式分类，分为无限公司、有限责任公司、两合公司、股份有限公司、股份两合公司。其他分类略）

- 公司法于**2013年12月28日**第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，**2014年**施行。**2018年10月26日**第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正
- 特别值得一提的是**2013年**修订，**2014年**实施的公司法，共修改了**12个**条款，涉及三个方面：一是将注册资本实缴登记制改为认缴登记制；二是取消公司注册资本最低限额，放宽了注册资本登记条件；三是简化了公司注册的登记事项和登记文件。
- 公司法的修改进一步降低了公司设立门槛，减轻了投资者负担，便利了公司准入，对于激励社会投资热情，鼓励创新创业，增强经济发展的内生动力。有助于鼓励个人创业，刺激个体经济的发展，也为工商部门推进注册资本登记制度改革提供了法制基础和保障，也将更进一步建立健全我国我国信用体系。

- **2014年修订的公司法将注册资本实缴登记制改为认缴登记制，**即新公司施行后，公司股东可以自主约定认缴出资额、出资方式、出资期限等，并记载于公司的章程。实缴制是指企业营业执照上的注册资本是多少，该公司的银行验资账户上就必须有相应数额的资金。认缴制则是工商部门只登记公司认缴的注册资本总额，无须登记实收资本，不再收取验资证明文件。除了另有规定的情况之外，取消了关于公司股东应当在公司成立之后两年内缴足出资，投资公司可以在五年内缴足出资的规定，取消了一人有限责任公司的股东应当一次足额缴纳出资的规定，公司股东可以自主约定认缴出资额、出资方式、出资期限等，并记载于公司的章程
- **公司法放宽了注册资本登记条件，除了法律行政法规以及国务院决定对公司注册资本最低限额另有规定的情况之外，取消了有限责任公司最低注册资本限制。不再限制公司设立时股东的首次出资比例，也不再限制股东的货币出资比例。尤其是删除了提交验资证明的规定，简化了公司登记程序。**

第二节 有限责任公司

一、**概念和特征**（股东以出资额为限、股东人数限制、封闭型、股份不得自由流通等）

二、设立

第二十三条 设立有限责任公司，应当具备下列条件：

股东符合法定人数；

有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；

股东共同制定公司章程；

有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；

有公司住所。

■ 公司法第二十五条

有限责任公司章程应当载明下列事项：

- （一）公司名称和住所；
- （二）公司经营范围；
- （三）公司注册资本；
- （四）股东的姓名或者名称；
- （五）股东的出资方式、出资额和出资时间；
- （六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；
- （七）公司法定代表人；
- （八）股东会会议认为需要规定的其他事项。

股东应当在公司章程上签名、盖章。

（原公司法有十一个事项，取消了三项，分别是股东的权利义务；股东转让出资的条件；公司解散事由与清算办法。）

■ 公司法第八十二条

股份有限公司章程应当载明下列事项：

- （一）公司名称和住所；
- （二）公司经营范围；
- （三）公司设立方式；
- （四）公司股份总数、每股金额和注册资本；
- （五）发起人的姓名或者名称、认购的股份数；
- （六）**股东的权利和义务（取消）**；
- （七）董事会的组成、职权、任期和议事规则；
- （八）公司法定代表人；
- （九）监事会的组成、职权、任期和议事规则；
- （十）公司利润分配办法；
- （十一）公司的解散事由与清算办法；
- （十二）公司的通知和公告办法；
- （十三）股东大会认为需要规定的其他事项。

■ 公司章程的变更程序

- (1)** 由董事会提出修改章程的议案。
- (2)** 将提议修改的内容提前通知股东。
- (3)** 提交股东大会表决，须特别决议通过。
- (4)** 及时申请变更登记。
- (5)** 予以通知或公告。

三、有限公司的出资

第二十六条 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。

公司的出资方式

公司法规定由原先的五种改为四种，但实际上增多了：

1、货币；

2、实物

3、知识产权

4、土地使用权 等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。因此，债权、股权、采矿权、探矿权等他物权均可作为出资财产。此举将会鼓励成千上万的投资者拿出闲置多年的资本进行投资创业。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

货币：是最基本的构成。用货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立公司在银行并设的临时帐户。

实物：包括建筑物、厂房、机器设备或其他物料。股东必须对出资实物拥有所有权，应对实物进行评估作价，并向公司转移占有，必要时须办理登记和过户手续。

无形资产：包括知识产权和专有技术。（取消了“不得超过公司注册资本的**20%**”的规定。

土地使用权等

采用认缴资本制之后，注册时实缴资本的要求取消了，验资也取消了，年检取消了，公司注册“立等可取”，一方面程序大大便利了，另一方面，认缴制的风险陡然增大了。另，请考虑：公司是谁的？

2014年取消了“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”详见新公司法第二十七条：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

（注意比较：抽逃出资、出资不足、资金不到位）
出资不足、抽逃出资等.ppt

- 第二十八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
- 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
- 第三十条 有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

有限责任公司的股权转让（研究法条）

- 第七十二条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求意见，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

- 【案例分析】 公司为他人提供担保问题
- （一）a为A公司的董事长兼总经理，为公司的法定代表人。
- B公司为A公司的长期合作伙伴。2008年7月，B因为一项贷款业务，需要A公司提供担保。a考虑到两者的友好关系，二话不说，立即作为A公司的法定代表人在担保书上签字，同意为B公司提供担保。
- 讨论A担保的效力。
- （二）现在A公司的老总a自己要贷款，需要担保人，a特地召开股东会，全体股东均隆重出席，a也为公司股东，所占股份达到67%。股东会以2/3以上的多数表决权表决通过了公司为a提供担保的决议。
- 在A公司的担保下，a取得了贷款。
- 试分析本案。
- （请见书本分析）

- 案例：股东优先购买权与非股东善意受让权的冲突
（案例及分析内容见书本）

■ **三个问题：公司不分红怎么办？公司解散不了怎么办？公司不给查阅会计帐簿怎么办？**

■ **第一个问题：**第七十五条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

- **评论：**现实生活中，有些有限责任公司的大股东利用其对公司的控制权，长期不向股东分配利润，也不允许中小股东查阅公司财务状况，致使中小股东的利益受到严重损害。针对这一情况，新公司法规定，公司连续**5**年不向股东分配利润，而该公司**5**年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。

- **第二个问题：**目前，有的公司经营严重困难，财务状况恶化，虽未达到破产界限，但继续维持会使股东利益受到更大损失；而因股东之间分歧严重，股东会、董事会又不能作出公司解散清算的决议，往往处于僵局状态。
- 新公司法对此困局作出规定：通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权**10%以上**的股东，可以请求人民法院解散公司。

■ **第三个问题：股东的查阅权、分红权、认购权：**

■ **第三十四条** 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法权益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

第三十五条 股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

四、有限公司的组织机构

1、股东会

第三十八条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第三十九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。

- 召集和主持股东会的新变化：
- 第四十一条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；**董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。**
有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。



对赌协议、隐名股东（股权代持协议）的相关风险

好的对赌协议会让企业腾飞；

坏的对赌协议会成为企业的一把枷锁，让企业管理人疲于奔命！

对赌一词听来刺激，其实和赌博无甚关系。对赌协议（**Valuation Adjustment Mechanism, VAM**）最初被翻译为“对赌协议”，或因符合国有文化很形象，一直沿用至今。但其直译意思是“估值调整机制”却更能体现其本质含义。



所以我们日常听到的对赌协议，所涉及问题其实和赌博无关。实际上就是期权的一种形式。通过条款的设计，对赌协议可以有效保护投资人利益。

对赌条款是企业融资中风险投资人经常使用的一种交易条件，全称叫“基于业绩的调整条款”或“估值调整机制”，是一种基于标的公司业绩而在投资人和创始股东之间进行股权调整的约定。

对赌协议是投资方与融资方在达成协议时，双方对于未来不确定情况的一种约定。如果约定的条件出现，融资方可以行使一种权利；如果约定的条件不出现，则投资方行使一种权利，或融资方转让一部分权利（比如溢价回收投资人股权）。所以，对赌协议**实际上就是期权的一种形式**。

若被投资企业完成了约定的业绩指标，则被投资企业及其老股东有权行使某些权利（如以相对低价购买被投资企业股权）；反之，投资人有权行使某些权利（如要求现金补偿、回购股权等）。由于被投资企业未来业绩不确定，在中国被形象地成为~。

对赌协议是投资人解决信息不对称的一种制度安排，也是风险投资人保障自己投资利益的重要手段！在如今的资本时代，不了解对赌协议，不了解对赌协议的制度安排与风险，那就真**OUT**了！

- 对赌协议通过条款的设计，可以有效保护投资人利益，近些年对赌协议在我国资本市场越来越多地被经常采用。
- 在创业型企业投资、成熟型企业投资中，都有对赌协议成功应用的案例，最终企业也取得了不错的业绩。
- 对赌协议是很专业的投资条款，通常包括三类条款（见书本）
- 一旦对赌失败（公司达不到业绩承诺或未能按时上市），对投资人的补偿，在实务中主要有三种形式：
 - （见书本）
- 对投资人而言，对赌协议就好像上了一个保险；但对企业和创始股东来说，则风险与压力山大。往往面临要么全赢、要么全输的考验：要么对赌成功——痛享资本盛宴，要么对赌失败——江山尽失！

成功的：案例若干分析

失败的：尤其要关注失败的。

摩根士丹利等机构投资蒙牛，是对赌协议在创业型企业中应用的典型案例。

1999年1月，牛根生创立了“蒙牛乳业有限公司”，公司注册资本100万元。后更名为“内蒙古蒙牛乳业股份有限公司”（以下简称“蒙牛乳业”）。2001年底摩根士丹利等机构与其接触的时候，蒙牛乳业公司成立尚不足三年，是一个比较典型的创业型企业。

2002年6月，摩根士丹利等机构投资者在开曼群岛注册了开曼公司。2002年9月，蒙牛乳业的发起人在英属维尔京群岛注册成立了金牛公司。同日，蒙牛乳业的投资人、业务联系人和雇员注册成立了银牛公司。金牛和银牛各以1美元的价格收购了开曼群岛公司50%的股权，其后设立了开曼公司的全资子公司——毛里求斯公司。同年10月，摩根士丹利等三家国际投资机构以认股方式向开曼公司注入约2597万美元（折合人民币约2.1亿元），取得该公司90.6%的股权和49%的投票权，所投资金经毛里求斯最终换取了大陆蒙牛乳业66.7%的股权，蒙牛乳业也变更为合资企业。

2003年，摩根士丹利等投资机构与蒙牛乳业签署了类似于国内证券市场可转债的“可换股文据”，未来换股价格仅为0.74港元/股。通过“可换股文据”向蒙牛乳业注资3523万美元，折合人民币2.9亿元。“可换股文据”实际上是股票的看涨期权。不过，这种期权价值的高低最终取决于蒙牛乳业未来的业绩。如果蒙牛乳业未来业绩好，“可换股文据”的高期权价值就可以兑现；反之，则成为废纸一张。

为了使预期增值的目标能够兑现，摩根士丹利等投资者与蒙牛管理层签署了其

注意四个问题：

第一，对赌协议有效性的争议：

我们的建议：（见书本）

第二，切莫贪心，盲目追求高估值；

第三、谨慎承诺业绩指标或上市时间。

第四，最最重要的问题：补救（见书本）

■ 现实生活中的隐名股东问题

股权代持 / 隐名股东与对赌协议

- 例：2006年3月，王斌与某专利人张冬成立公司注册资金100万元，并约定今后若公司需增资扩股，如张冬累计分红达不到认缴所需资金，不足部分由王斌垫付。

- 王斌将自己的哥哥王凭安排进公司，并将自己85%的股权中的45%登记在其哥哥王凭名下（王斌与其妻感情不和，觉得还是兄弟靠得牢），由其哥哥代持。

股权结构为：王斌40%、王凭45%，张冬15%。

- 2008年8月公司效益好扩股，注册资本增值至2000万元，为防止白白给张冬垫资，王斌不占股份，由其哥哥王凭私下代持，出资情况变更为：王凭 85%，张冬15%。（这样王斌就无需为张冬垫资了）

2015年10月，公司股东会决议（王凭85%股权），注册资本减少到100万；半年后再次股东会决议，增资到5000万，王凭认缴绝大部分资本，张冬虽然是创始股东，但股权已经被稀释到0.3%。

- 随着公司越做越大，王氏兄弟俩矛盾开始激化，王斌决定要回自己99.7%的股权，但其哥哥不同意。引发诉讼。

- 法院认为：

- （隐名投资人虽不是公司名义上的股东，但由于公司的成立起因于隐名投资人的出资，故隐名投资人不得抽回资金。
- 当公司与第三人发生争议时，不能以隐名股东与显名股东之间的协议的约定对抗善意第三人。）

■ 现实生活中的隐名股东问题

■ **2004年3月**，原告吴讯与被告吴宜新、吴亚平、张建华及陆一伟、徐佳春六人协商约定共同设立三协公司；原告分三次共计出资人民币**170万元**，吴讯的股份挂名在吴宜新名下。

■ **2004年8月10日**，六位出资人签字确认了各自认缴的出资额；**2004年8月23日**，由吴宜新召集其余五名股东召开首次股东会议，确认了各股东的投资额，制定了公司章程，明确了各股东的职责分工等，同时约定，以吴宜新、吴亚平、张建华三名股东名义进行公司登记；

■ **2004年10月10日**，三协公司经核准领取企业法人营业执照，载明股东为吴宜新、吴亚平、张建华，法定代表人为吴宜新；自**2004年8月23日**起至**2006年5月21日**止，三协公司共召开**9次**股东会议，原告都参加股东会议并参与公司议事。

■ 原告诉称，其投入了入股款但却未被登记为公司股东，未享有股东权利，故诉至法院，请求法院判令四被告连带退还原告**1700000元**入股款。

■ 四被告共同辩称，原告具有股东资格，不同意返还其出资款**1700000元**。

三个问题：

- 1、能否返还吴讯的 “出资额” 170万元？
- 2、若吴讯要求分配利润，能否支持？
（即隐名股东的权利被承认否？）
- 3、若公司未经其同意，向第三人转让了股份，吴讯不同意转让，并以其与显名股东之间的协议向该第三人主张权利，能否获得法律支持？

- （隐名投资人虽不是公司名义上的股东，但由于公司的成立起因于隐名投资人的出资，故隐名投资人不得抽回资金。
- 当公司与第三人发生争议时，不能以隐名股东与显名股东之间的协议的约定对抗善意第三人。）
- （隐名股东的精髓概况为四句话：详见书本）

■ 2、董事会

■ 董事会成员的产生方式有三种：

第一，股东会选举方式。

第二，股东单方委派。

第三，职工民主选举方式。

■ 有限责任公司会其成员3-13人。股份有限公司的董事会由5-19名董事组成。国有独资公司3-9人。

■ 董事长是公司的法定代表人。

■ 规模小的，可不设董事会。

■ 职权 第四十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。

- 第四十八条 董事会会议由董事长召集和主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第四十九条 董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

■ 董事表决责任：

- 第一百一十三条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

公司领导机关成员的资格限制和竞业禁止

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

2) 竞业禁止 **例：**某公司在讨论决定本公司的监事人选名单，在名单中有这样一些人，请公司法的规定，判断下列哪些人可以担任公司的监事（ ）**A、**公司董事长王某 **B、**公司总经理李某 **C、**公司聘用的临时工沈某 **D、**本市总工会主席赵某

例：某纺织品有限责任公司在审核本公司董事人选时，公司的法律顾问指出，人选中有些人不能担任公司的董事，他们是：（ ）**A、**王某，某大学经济学教授，年近80，现退休；**B、**吴某，企业管理专家，为本地区某针织厂经理；**C、**张某，曾任某国有工厂的厂长，2年前因经营不善企业破产而被免职，现为某工厂工人 **D、**宋某，某高校工商管理学博士，最近因家庭问题负债20万元

（上述两个案例请见书本分析）

■ 董事、高级管理人员的责任：

- 第一百五十五条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
- 第一百五十一条 股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
董事、高级管理人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况 and 资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

案例：有限责任问题

- 例：a于2008年2月成立了公司A，a为公司法定代表人。3月，a成立了公司B，B公司的人员基本上为A公司的原班人马，实为一套人马，两块牌子。在B公司运营过程中，所有的费用均由A公司支付，最终掏空了A公司。2008年7月，A公司拖欠C公司债务达3000万元人民币，被诉至法院。诉讼中，a声称A公司资不抵债，无力还款。因A为独立法人，a声称其本人与B公司并无连带责任。C陷入困境。讨论之。（见书本）

■ 累积投票制，一个令人欣喜的变化：

- 累积投票制是一种与普通的直接投票制相对应的公司董（监）事选举制度。在累积投票制下，每一有表决权的股份享有与拟选出的董（监）事人数相同的表决权，股东可以自由地在各候选人间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，然后根据各候选人得票多少的顺序决定董（监）事人选。
- 累积投票制在一定程度上为中小股东的代言人进入董（监）事会提供了保障。
- 公司法第105条：本法所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

试举一个例子：某上市公司股东大会准备选举**9**名董事，某股东持有该公司股票**1**股，则该股东在参加股东大会时的表决权票数是**9**票而不再是**1**票。第二，表决权的使用方法。股东可以将他持有的投票权票数集中投给一名候选人，也可以将分散投给多人。还用刚才的例子，该股东可以给**9**名董事候选人每人投上**1**票，则**9**名董事候选人每人得**1**票；该股东也可以将**9**票全部投给**1**个候选人，则该董事候选人得**9**票。

- 累积投票权制度的独特作用在于：
- 一方面，它通过投票数的累积计算，扩大了股东的表决权的数量；另一方面，它通过限制表决权的重复使用，限制了大股东对董事、监事选举过程的绝对控制力。换句话说，关键是在累积投票时，股东的表决权只能使用一次，而不能多次重复使用，这就给中小股东“集中优势兵力”，选出自己的董事、监事创造了可能。
- 继续用上面的例子，假如有1个大股东持有公司股票8股，需选举9名董事，则它的累计投票权票数就是72票，如果它将72票分散投给9名董事候选人，则每名候选人得8票。而刚才的小股东虽然只持有1股，但由于票数累积，他得到了9个投票权票数，如果他将9票累计投票权全部投给1名董事候选人的话，则该名董事候选人就得到了9票，9票多于8票，小股东投票的候选人一定能够当选。

- 累积投票制最早起源于**1870**年美国伊利诺伊州《宪法》。美国证券市场发展早期到处充斥着大股东损害中小股东、管理层损害公司股东的现象，在总结大量案例的基础上，该州于**1870**年在州宪法第**3**章第**11**条规定，任何股东在法人公司选举董事或经理人的任何场合，均得亲自或通过代理人行使累积投票权，而且此类董事或经理不得以任何其他方式选举。随后，该州《公司法》第**28**条也规定了累积投票制度。
- 至**1955**年，美国有**20**个州在其宪法或制定法中规定了累积投票制度。由于累积投票制在维护中小股东利益、防止控股股东全面操纵董事会、降低集中决策风险和实现“公司民主”等方面的重要价值。
- 之后，该制度在世界各地得到推广运用，日本等亚洲国家和地区公司法也相继采纳了累积投票制。

- 我国最早引入累积投票制度是在**2002年1月7日**中国证监会**[2002]1号文件**《上市公司治理准则》之中，其第**31**条规定：“在董事选举的过程中，应充分反映中小股东的意见，股东大会在选举过程中应积极推行累积投票制度，控股股东持股比例在**30%**以上的上市公司，应当采用累积投票制”。

■ 3、经理

- 第五十条 有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。

公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。
经理列席董事会会议。

4、监事会

第五十二条 有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五十三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

一人公司问题：

- **一人有限责任公司**，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。
- 第五十八条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。
- 第五十九条 一人有限责任公司应当**在公司登记中注明自然人独资或者法人独资**，并在公司营业执照中载明。

- 第六十条 一人有限责任公司章程由股东制定。
- 第六十一条 一人有限责任公司不设股东会。股东作出本法第三十八条第一款所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。
- 第六十二条 一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。
- 第六十三条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

新年伊始，中国第一家一人有限责任公司在素有"中国个体私营经济发祥地"的温州成立。

今天是新的《中华人民共和国公司法》实施第一天。上午9点半，温州人王毅诚从温州市工商局领取了他期待已久的"温州市温信电脑租赁有限公司"营业执照。与众不同的是，这家公司只有一个人。在其《企业法人营业执照》上，这样注明了公司的性质：有限责任公司（自然人独资）。公司注册资本为10万元。

据介绍，这家一人公司是新《公司法》突破有限责任公司至少有两人的限定后，我国成立的首家一人公司。

温州市温信电脑租赁有限公司法人王毅诚告诉记者，以前曾与人合伙成立过一家电脑租赁公司，后因合伙人之间出现矛盾而散伙了。他说，一人公司在名声上比个体经营户好听，在经营上也要更加灵活。

温州市工商行政管理局注册处张大兴处长说，中国第一家一人公司在温州诞生具有特别的意义。一人公司在经营上具有不可比拟的灵活性，对于以个体私营经济闻名的温州来说无疑是一次极好的机遇。

据介绍，1979年11月30日，中国第一家个体工商户也同样诞生在温州。

■ 国有独资公司的新规定（变化不大）：

■ **第七十条** 国有独资公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员，未经国有资产监督管理机构同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。

第七十一条 国有独资公司监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。

监事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是，监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。

第一百五十二条 董事、高级管理人员有本法第一百五十一条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼；监事有本法第一百五十一条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。

监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第一百五十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

几个概念的辨析：

- （一）高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
- （二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- （三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
- （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第三节 股份有限公司

一、概念和特征

二、设立 （设立股份公司的新变化）

第七十六条 设立股份有限公司，应当具备下列条件：

发起人符合法定人数；

有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；

股份发行、筹办事项符合法律规定；

发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；

有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；

有公司住所。

- 第七十七条 股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。
- 发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
- 募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
- 第七十八条 设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
- 第七十九条 股份有限公司发起人承担公司筹办事务。
- 发起人应当签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务。
- 第八十条 股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。
- 股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。

3、股份的概念、种类等问题

4、股份转让的限制性规定：

第一百四十一条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

公司并购、对赌协议的经典阐述及案例分析，请消化课堂上的案例及分析，而不是简单听故事。

- 第一百四十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
- 减少公司注册资本；
- 与持有本公司股份的其他公司合并；
- 将股份奖励给本公司职工；
- 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
- 公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。
- 公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。
- 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

上市公司设立独立董事，
具体办法由国务院规定。

补充： 独立董事
(Independent director)

独立董事也称外部董事，非执行董事，其概念和制度来自英美国家，兴起于20世纪50~60年代，80年代得到普遍地推广采用。在美国、法国、德国等国家，甚至要求独立董事的比例高于股东董事。在某种程度上，独立董事制度被当作了完善公司治理结构的一剂良方。

究独立董事之产生，原因主要可概括为两点：

第一，股东在追求利益最大化的情况下，常常会损害其他人的利益，大小股东的利益会发生冲突。中小股东的利益不能得到很好保护。如果对大股东没有任何约束，而最终会导致社会规则的破坏、社会利益的损害。

第二，在股权分散化的条件下，会出现内部人控制问题。控制企业的主体，包括董事长、董事，还有企业中的经理人员这些控制企业的内部人的报酬，按照正常情况应该由董事会来定。但是董事会的成员往往是控制企业的主体，而导致最终是自己给自己定报酬，这样会出现很多黑幕交易。

鉴于以上原因，各国引入独立董事制度的初衷，无非有以下三种：
一是为了强化对大股东的监督力度；二是为了改善“内部人控制”问题；三是为了维护上市公司中小股东的利益。中国引入该制度，目的也在于此。

中国引入独立董事制度可以追溯到1988年。该年我国H股公司率先按香港联交所的要求设立独立董事。1997年12月，中国证监会发布的《上市公司章程指引》中专列了“公司根据需要，可以设立独立董事”的条文。1999年2月，国家经贸委和中国证监会联合发布了《关于进一步促进境外上市公司规范化运作和深化改革的意见》。基于该《意见》是我国第一次正式用成文的形式对独立董事制度作出了规定，也有一部分学者因此认为中国真正开始从境外上市的公司引入独立董事制度应该是在1999年。2001年8月16日，《关于在上市公司中设立独立董事制度的指导意见》正式由证监会发布，该《意见》要求，在2003年6月30日之前，中国上市公司董事会中独立董事的比例必须达到1/3以上。

第五章 企业破产法

（本课件配套教材《经济法理论与实务》浙大出版社2018年版周黎明 著）

第一节 破产法概述

一、破产与破产法的概念

破产是指丧失清偿能力的债务人，经法院审理，强制清算其全部财产，公平清偿全体债权人的法律制度。

破产法是规定在债务人丧失清偿能力时，法院强制对其全部财产进行清算分配，公平清偿债权人，或通过债务人与债权人会议达成的和解协议清偿债务，或进行企业重整，避免债务人破产的法律规范的总称。

二、我国的破产法

2006年8月27日，第十届全国人大常委会通过了《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》），自2007年6月1日起实施。

■ **【例5-1】**

- A企业由于不能清偿到期债务，资不抵债，其债权人B企业向法院提出申请A破产。在本案中，A企业提出抗辩，认为自己虽然不能清偿到期债务，但在该项债务中存在一个连带责任保证人C企业，且C企业具有清偿能力，债权人应当先向保证人C企业要求清偿，只有在保证人也不能清偿债务的情况下，法院才可以受理破产申请。
- 请问A企业的抗辩是否具有法律依据？
- （案例及分析请见书本）

■ 第二节 破产申请与受理

■ 一、破产原因

■ 根据《破产法》第二条的规定，企业法人的破产原因是不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力。2011年最高法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》（以下简称《破产法司法解释（一）》）第一条规定：“债务人不能清偿到期债务并且具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具备破产原因：（一）资产不足以清偿全部债务；（二）明显缺乏清偿能力。相关当事人以对债务人的债务负有连带责任的人未丧失清偿能力为由，主张债务人不具备破产原因的，人民法院应不予支持。”据此规定，破产原因可以分为两种情况：第一，债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，主要适用于债务人提出破产申请且其资不抵债情况通过对相关证据的形式审查即可判断的案件；第二，债务人不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，主要适用于债权人提出破产申请和债务人提出破产申请但其资不抵债通过形式审查不易判断的案件。

■ 二、破产申请的提出

■ （一）申请

■ （二）受理

■ 第三节 破产管理人

- 《破产法》用管理人制度取代了旧法中以政府官员为主导的清算组制度，这是我国破产法走向规范化、市场化、国际化的重要一步。

■ 一、管理人的概念

- 管理人，是指破产案件受理后成立的，全面接管破产企业并负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配等破产清算事务的专门机构或人员。
- 管理人由人民法院指定。债权人会议认为管理人不能依法、公正执行职务或者有其他不能胜任职务情形的，可以申请人民法院予以更换。

■ 二、管理人的任职资格

■ 三、管理人的职责

■ 第四节 破产债务人

■ 一、债务人财产

■ 破产申请受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产，为债务人财产。

■ 《破产法》第三十一条规定，人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销并予以追回：

■ （1）无偿转让财产的；

■ （2）以明显不合理的价格进行交易的；

■ （3）对没有财产担保的债务提供财产担保的；

■ （4）对未到期的债务提前清偿的；

■ （5）放弃债权的。

■ 二、破产撤销权与无效行为

■ 三、取回权

■ 四、抵销权

■ 第五节 破产费用

■ 一、破产费用的概念

■ 破产费用，是在破产程序中为全体债权人共同利益，因程序进行而支付的各项费用的总称。

■ 二、破产费用的内容

■ 《破产法》第四十一条规定，“人民法院受理破产申请后发生的下列费用，为破产费用：（1）破产案件的诉讼费用；（2）管理、变价和分配债务人财产的费用；（3）管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。”

■ 第六节 破产债权

■ 一、破产债权的概念

■ 破产债权是依破产程序启动前原因成立的，经依法申报确认，并可由破产财产中获得清偿的可强制执行的财产请求权。但法律另有明文规定者除外。《破产法》第一百零七条第二款规定，“人民法院受理破产申请时对债务人享有的债权成为破产债权”。

■ 二、破产债权的申报

■ 《破产法》第四十五条规定，“人民法院受理破产申请后，应当确定债权人申报债权的期限。债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最短不得少于三十日，最长不得超过三个月。”

第七节 债权人会议

- 一、一般规定
- 二、债权人会议
- 三、债权人委员会

第八节 重整制度

- 一、重整的概念
- 二、重整申请和重整期间
- 三、重整计划的制定和批准
- 四、重整计划的执行

第九节 和解制度

第十节 破产清算制度

- 一、破产宣告
- 二、别除权
- 三、变价和分配
- 四、破产程序的终结

■ 【例5-2】

- 甲企业因经营管理不善，不能清偿到期债务，依法被宣告破产。经查，甲企业财产状况如下：现有现金、实物共100万元。房地产500万元，其中，有一处价值200万元的房地产抵押给A银行贷款150万元；另一处房地产100万元抵押给B银行130万元。有两企业分别欠该企业70万元、30万元。

- **（接上个案例）** 负债情况如下：除上述两笔贷款外，尚分别欠乙100万元、欠丙企业200万元；欠丁企业300万元；欠国家税收250万元，欠职工工资、劳动保险费50万元。破产费用共计20万元。
- 另外，在财产的清理过程中，还发现甲企业借用戊企业工程车辆一台，价值120万元。
- 请问：该如何进行破产清偿？（计算破产债权，破产财产，并说明清偿顺序）
- （案例及解答分析见书本）

第七章 知识产权法

（本课件内容亦受本法保护，未经许可，转载必究。本课件内容来自《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年11月第一版 周黎明著）

第一节 概述

（先考虑：知识产权、工业产权、专利权、商标权、著作权、版权这几个概念之间是什么关系？）

1、知识产权的概念和特征

（1）概念（可简单理解为：对智力成果和标记所拥有的权利的总称）

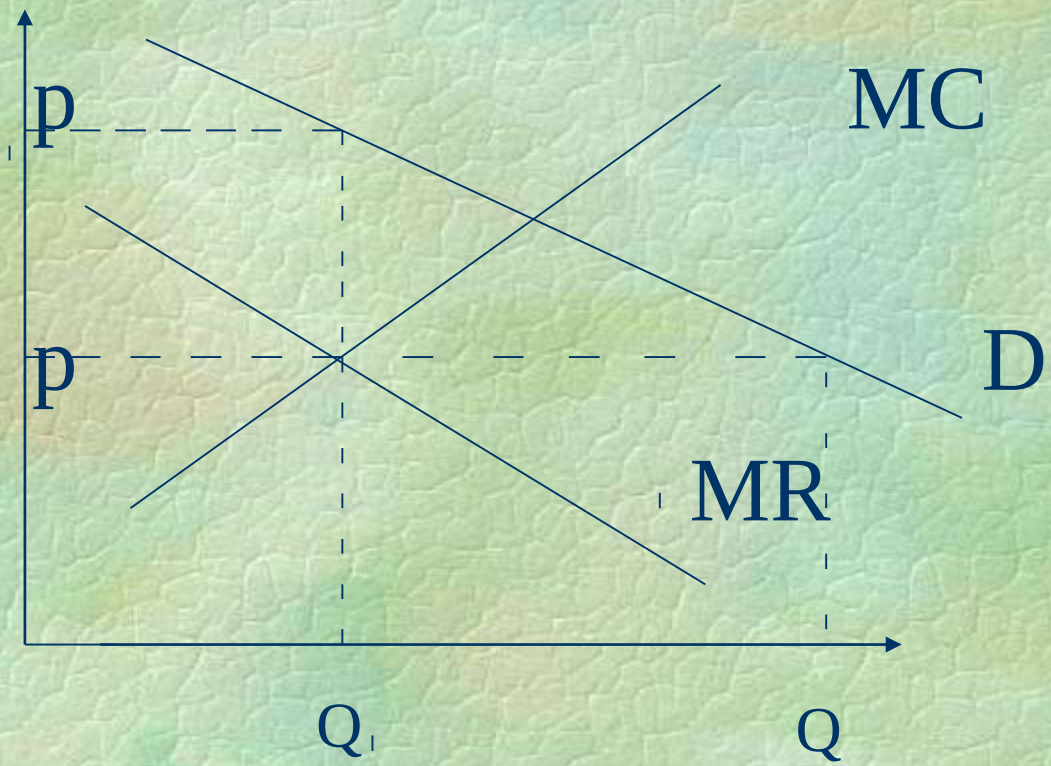
（2）特征（**无形性、专有性、地域性、时间性**）

2、我国的知识产权法

我国没有专门制定统一的知识产权法，而是制定了单项法。如专利法、商标法、著作权法等。

另外，我国还加入了一系列国际公约。

- ◆ 思考一个问题：
- ◆ 为什么要保护知识产权？或者说保护知识产权是保护谁的利益？
- ◆ 但是要记住，保护知识产权的目的是鼓励知识的创造，让大家能够以合理的价格享用知识。否则，如果我们实施了保护，但大多数人却因此而享受不到知识；或者价格奇高，使消费者吃了亏，我们就没有保护的义务。
- ◆ 更为严重的问题是知识的使用价格不合理。知识是一种垄断性产品，因而容易被卖方任意提高价格，这就有可能损害全社会的总体福利。目前知识产品却没有这种政府的管理，反而还通过知识产权保护来强化其垄断
- ◆ 许多垄断性产品获得暴利，这是极不公平的。
- ◆ 而根据经济学的原理，垄断行业的定价是要有政府或其他部门管理的，否则供应方会按照边际收入等于边际成本的交点来定产量。这样的产量将低于竞争价格等于边际成本点的产量，而价格则高于竞争价格等于边际成本点的价格。消费者将不得不花高价买垄断性商品，损害了消费者的利益。



垄断抬高了价格

- ◆ 正因为如此各国政府都规定垄断性产品的价格需要由政府或其他公众机构审核决定，不可以让企业自己定价。可是在国际贸易中并没有一个世界政府来管这些事，于是垄断企业自己给产品定价。受害最大的就是缺乏知识的发展中国家。
- ◆ 一个例子：艾滋病药品。药品的知识产权保护直接引发了知识产权和人权的冲突。发达国家发明了对付艾滋病的药，可是要价非常高。艾滋病在发展中国家很流行，可是为了活命又不得不买，这就极大地损害了消费者的利益。知识产权的保护事实上是助桀为虐，帮助敲诈勒索的一方，让他们做了坏事还理直气壮。
- ◆ 结论：知识产权不是不要保护，而是说它的定价机制需要有所限定。关于知识产权的侵犯问题应该转换为它的定价问题。双方可以在价格上讨价还价，有一个商量的余地。按照现在的做法，侵犯了知识产权是要受处罚的，不是讨价还价的问题。世界贸易组织应该认识到保护知识产权是保护垄断，是违反经济学原理的事。
- ◆ 要维护公正的国际经济秩序，必须正视这个问题。

第二节 商标法

- ◆ 现行的《商标法》是1982年通过的，当时全国只有商标3万多个，而目前我国商标的总数:据统计，截至2013年，我国商标累计申请量、累计注册量分别为1136万件、765.6万件，有效注册商标已达640万件，均位居世界第一。但与此同时，有专家指出，在这些“世界第一”的背后，其实与近年来商标被大肆恶意抢注的现象不无关系。2013年8月30日，《全国人民代表大会常务委员会关于<修改中华人民共和国商标法>的决定》在第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上表决通过，该决定于2014年5月1日起施行。

- ◆ 【商标法发展历程】

中华人民共和国商标法(1982) [1982.08.23]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第一次修正) [1993.02.22]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第二次修正) [2001.10.27]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第三次修正) [2013.08.30]

新法具体修改如下：

第二节 商标法

- ◆ 现行的《商标法》是1982年通过的，当时全国只有商标3万多个，而目前我国商标的总数:据统计，截至2016年底，商标有效注册量达到1237.6万件，每万户市场主体商标拥有量达1422件，完成了“商标累计请求量、商标累计注册量、有效商标注册量”三个超千万。2017年，国内申请量最多的前5个省（市）分别为：广东（1095053件）、浙江（546987件）、北京（490086件）、江苏（352736件）、上海（343879件）。2018年1月数据显示我国商标注册申请量突破500万。但与此同时，有专家指出，在这些“世界第一”的背后，其实与近年来商标被大肆恶意抢注的现象不无关系。

- ◆ 我国商标注册申请量突破500万大关
- ◆ 2018年1月18日，工商总局新闻发布，2017年我国商标注册申请量突破500万大关，达到574.8万件，比上年增长55.7%，申请量和增速均创历史新高。
- ◆ 截至2017年年底，我国商标累计申请量2784.2万件，累计注册量1730.1万件，有效注册商标量1492万件，连续17年位居世界第一。我国每万户市场主体的平均有效商标拥有量为1520件，与2011年的1074件相比显著增加。
- ◆ 我国商标品牌的世界影响力也同步增强。世界品牌实验室发布的2017年度《世界品牌500强》排行榜显示，中国入选品牌为37个，与2013年相比增长了1.5倍。中国商标品牌“走出去”步伐正不断加快。去年，我国申请人提交马德里商标国际注册申请4810件，比上年增长59.6%，在马德里联盟中排名第三。
- ◆ 商标知识产权保护力度进一步加大。2017年工商和市场监管部门以驰名商标、地理标志、涉外商标、老字号商标等为重点，强化商标专用权保护。全系统共查处商标违法案件3万件，比上年下降5.1%。其中，商标侵权假冒案件2.7万件，比上年下降4.3%。

2017年1-11月每月商标申请量统计表

月份	2017年	去年同期	增长数	同比增长
1	279,722	272,826	6,896	2.53%
2	230,325	152,157	78,168	51.37%
3	375,451	339,450	36,001	10.61%
4	517,101	333,713	183,388	54.95%
5	530,552	344,508	186,044	54.00%
6	558,871	353,682	205,189	58.02%
7	523,658	335,571	188,087	56.05%
8	571,416	360,865	210,551	58.35%
9	573,355	324,131	249,224	76.89%
10	451,612	281,350	170,262	60.52%
11	505,303	363,207	142,096	39.12%
合计	5,117,366	3,461,460	1,655,906	47.84%

◆ **【商标法发展历程】** **中华人民共和国**
商标法(1982) [1982.08.23]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第一次修正) [1993.02.22]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第二次修正) [2001.10.27]

《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》(第三次修正) [2013.08.30]于2014年5月1日起施行。

具体修改如下：

◆ 1、增加**诚实信用**原则条款

- ◆ 修改要点：新《商标法》第七条规定了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。
- ◆ 影响：将民事活动应遵循的基本原则明确写入《商标法》，目的在于倡导市场主体从事有关商标的活动时应诚实守信，同时对当前日益猖獗的商标抢注行为予以规制。可以预见的是，该条款将在日后的商标确权以及维权案件中作为兜底性条款被大量适用。

◆ 2、**禁止抢注**因业务往来等关系明知他人已经在先使用的商标

- ◆ 修改要点：新《商标法》第十五条增加第二款：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”
- ◆ 影响：增加此条款的目的主要在于防止将他人已经在先使用的商标抢先进行注册，此修改在原有规定基础之上进一步加大了对已使用但未注册商标的保护力度，能够在一定程度上更加有效的遏制频发的商标抢注现象。

◆ 3、增加**惩罚性赔偿**的规定，**提高**侵权赔偿额

- ◆ 修改要点：新《商标法》引入了惩罚性赔偿制度，规定对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的**1到3倍**的范围内确定赔偿数额。同时，新《商标法》还将在上述三种依据都无法查清的情况下法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从**50万元提高到300万元**。

- ◆ 影响：上述修改主要针对实践中权利人维权成本过高、进行维权往往得不偿失的现象。此次修改将对商标权利人维护合法权益、打击商标侵权行为起到积极作用。

◆ 4、增加**侵权人举证责任**

- ◆ 修改要点：新《商标法》规定在商标侵权诉讼中，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料，侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。

- ◆ 影响：此举大大减轻了商标权利人在主张侵权赔偿时的举证负担，使人民法院在确定赔偿数额时更有法可依，对打击商标侵权行为具有积极意义。

◆ 5、增加关于商标注册**审查和案件审理时限**的规定

- ◆ 修改要点：新《商标法》规定，“对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起**九个月内审查**完毕”。而针对涉及**单方**当事人的商标确权案件，新《商标法》增加了**9个月的审理**时限，针对涉及**双方**当事人的确权案件，增加了**12个月**的审理时限。有特殊情况需要延长的，“经国务院工商行政管理部门批准”，可以延长3个月或者6个月。

- ◆ 影响：上述新增内容对商标注册审查和案件审理时限进行了限制，有利于大大改善当前商标注册周期过长，影响当事人权利的情况，同时增强了商标获权时间的可预期性。

◆ 6、加强对**商标代理组织**的规范

- ◆ 修改要点：新《商标法》增加了商标代理组织从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则的内容，商标代理行业组织对违反行业自律规范的会员可实行**惩戒并记入信用档案**。另外，新《商标法》还规定了对于商标代理组织或者商标代理人违反诚实信用原则，侵害委托人合法利益的，应当依法**承担民事责任**。

- ◆ 影响：近年来商标代理市场乱象丛生，饱受诟病，《商标法》增加上述规定将有助于商标代理组织行业的自我规范和良性发展。日后当事人一旦发现商标代理组织或者代理人有任何不诚信、不正当手段时，均可向工商行政部门或者商标代理行业组织进行投诉和反映，若给当事人造成损失的，还有权依据新《商标法》要求代理组织赔偿。

◆ 7、增加声音商标

- ◆ 修改要点：新《商标法》第八条规定了声音可作为商标注册。
- ◆ 影响：日后，广大消费者熟知的QQ消息声、诺基亚、英特尔等常见的声音标识将可以作为商标申请注册。

◆ 8、一标多类

- ◆ 修改要点：新《商标法》第二十二条第二款规定，“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。”
- ◆ 影响：“一标多类”是我国商标申请制度与国际接轨的一次重大变革。设置这一制度的出发点在于方便申请人针对同一商标在多个类别的注册申请，设置这一制度的出发点在于方便申请人针对同一商标在多个类别的注册申请，这对规模较大、跨类经营较多以及注重保护性商标注册的企业无疑是个好消息。

◆ 9、修改**异议复审**制度

- ◆ 修改要点：新《商标法》规定商标局对商标异议进行审理后，对异议不成立、准予注册的商标，将直接发给注册证，异议人不服的只能向商评委请求宣告该注册商标无效，而对商标局裁定异议成立、不予注册的，被异议人可以向商评委申请复审。
- ◆ 影响：上述修改对原有的异议复审制度进行了部分调整，对于被异议人而言减少了商标确权过程的障碍，有利于被异议商标及时获权；而对于异议人来说，如果异议不成立将不再具有提出异议复审的权利。

10、**限定异议主体**和理由

- ◆ 修改要点：新《商标法》第三十三条将有权依据相对理由提出异议的主体，由原来的“**任何人**”改为“**认为这一商标注册申请侵犯了其在先权利的在先权利人或者利害关系人**”。但针对违反禁用和禁注条款的商标，新《商标法》继续保留了“任何人”可以提起异议的规定。
- ◆ 影响：该条款的修改能够在一定程度上**杜绝部分恶意的异议申请，避免他人利用异议制度故意拖延商标注册的时间**。但由于继续保留了“任何人”可以依据绝对理由提起异议的制度，上述修改的实际效果如何，还需要时间的检验。

11、增加禁止宣传和使用“驰名商标”的规定

- ◆ 修改要点：新《商标法》第十四条第五款规定，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”违反此规定的，根据第五十三条，“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。”
- ◆ 影响：“驰名商标”原本是加强对较高知名度商标保护的一种法律概念，但长期以来，市场经营者将“驰名商标”作为一种荣誉使用在产品上或宣传活动中。市场对驰名商标这种广告效应的旺盛需求，在一定程度上助长了饱受诟病的驰名商标制度异化问题。此次新《商标法》增加对“驰名商标”宣传和使用行为的禁止性规定，旨在将“驰名商标”回归为一种法律符号。
- ◆ 对广大驰名商标企业来说，如果涉及将驰名商标作为广告宣传等情况，需在新《商标法》实施前尽快调整并停止宣传使用“驰名商标”

◆ 12、商标侵权判定中引入“容易导致混淆”要件

◆ 修改要点：新《商标法》第五十七条将原《商标法》第五十二条中“在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标”的侵权情形进行了细分，对于不属于在“同一种商品上使用相同商标”情形的侵权判定增加了“容易导致混淆”的判定要件。

◆ 影响：该条款的修改明确了对于“在同一种商品上使用与注册商标近似的商标”、“在类似商品上使用与注册商标相同的商标”以及“在类似商品上使用与注册商标近似的商标”三种商标使用行为是否构成侵权的判定，需要考虑是否满足“容易导致混淆”这一适用要件。

◆ 建议：作为商标权利人，在今后的维权案件中，对于他人不属于在“同一种商品上使用相同商标”的商标使用行为，如果要想获得最终的侵权认定，需要注意在理由阐述及证据材料的组织上不要忽视对涉案商标的使用满足“容易导致混淆”这一要件的论述及证明

- ◆ 2014年5月的新商标法设定了商标审查时限，商标申请的过程更加透明清晰
- ◆ 由于原商标法对商标审查时限未作规定，导致企业商标注册的时间不确定，现行商标法实施十年来，商标审查的周期有较大的波动，商标注册审查一度需要四至五年，在2010年，商标局突击审查积压的商标申请，目前商标注册申请的审查周期已经能达到新商标的要求，新法规定商标局自收到商标申请文件9个月内完成审查，加上等候公告的时间，以及商标公告的3个月时间，一件顺利的商标申请能够在12-15个月内获得注册。
- ◆ 另外，商标异议的审查时限自公告期满之日起12个月，经工商总局批准可以延长6个月；驳回复审的审查时限是复审申请之日起9个月，经工商总局批准可以延长3个月；
- ◆ 异议复审的审查时限、无效宣告审查时限均作了规定。
- ◆ 长期以来，商标异议、评审的周期较长，一件完整履行商标法所规定的四级审查的商标注册申请，常有十年都不能获得注册的案例，而根据相关规定，公告期满三个月超过十年的商标，即使未核准注册还在确权案件中也应当办理续展申请，而多数企业认为只有获得注册证的商标才需要续展，这种时限超长导致申请人疏忽续展而丧失商标权的案例时有发生。

◆ 异议救济程序的变化

- ◆ 现行商标法中，商标注册异议首先由商标局审查作出裁定，对商标局的裁定不服可以申请商标评审委员会复审，对复审决定不服可以提起诉讼，这种程序使商标申请面临商标局、商评委、北京一中院、北京高院四级审查，商标注册时间长，商标申请人由此支付的法律服务费用也较高，新法针对这一引起较多企业反应的程序做了一定调整。
- ◆ 新法取消了异议人的复审权，只保留了注册申请人的异议复审权利（异议人只能申请宣告无效，不能申请复审），此种调整有利于商标申请人尽快获得注册（因为原先经常发生恶意以提异议及复审作为要挟要钱手段进行讨价还价的条件，比较恶劣）。
- ◆ 但异议程序是相对的，如果异议人是维护商标权利的驰名商标、著名商标权利人，那么涉嫌傍名牌的商标较早注册，则容易误导消费者，加大知名企业保护商标的难度，消费者的利益在一定程度上也容易受到损害。在现行异议实践中，商标局裁定异议不成立予以注册的商标，异议人通过复审及诉讼程序最终使傍名牌商标不予注册的案例是大量存在的。如果商标局不能严格规范异议审查，对知名商标进行较为合理的保护，新法的这一调整可能给一些傍名牌的企业可乘之机。

《中华人民共和国商标法实施条例》，自2014年5月1日起施行

第二章 商标注册的申请

第十三条 申请商标注册，应当按照公布的商品和服务分类表填报。每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1份、商标图样1份；以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样，并提交黑白稿1份；不指定颜色的，应当提交黑白图样。

商标图样应当清晰，便于粘贴，用光洁耐用的纸张印制或者用照片代替，长和宽应当不大于10厘米，不小于5厘米。

以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，并提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图。

以颜色组合申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式。

以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。

一、概述：

1、概念：商标是工商企业用以标明自己所生产的或经营的商品，并使其与他人制造或销售的商品有所区别的一种标记。简言之，商标就是区别商品的标记。通俗地说，就是商品的牌子。

不同种类的商品，不论有无商标，都很容易识别；但是同样或同种类的商品，有时候，没有商标就很难把他们区分开来。

2、商标的历史发展

商标是商品经济的产物，是随着商品生产的发展而发展起来的。

在自然经济初期；

春秋战国时期（“国有六职、市有百工”）

到了唐朝（有了行铺、作坊）；认牌购货；

到了宋朝，公元960——1279年，“刘家功夫针铺”

到了清光绪29年（1903年），（《商标注册试办章程》）中国历史上第一个商标法规

以后的国民党政府，沿袭了清政府的传统，所颁布的商标法规，都是向外国抄袭（尤其是日本）。

在旧中国，一些民族资本家通过自己的努力，也出了不少名商标，如：“大前门”卷烟、“六必居”酱菜、“盛锡福”帽子、“张小泉”剪刀、“同仁堂”中药等等。

但是，另一方面，资本家为了牟取暴利，也常常乱用商标，最常见的是仿冒。如：“美丽牌”卷烟（华成烟厂）

美丽牌卷烟.jpg

当时的许多烟草制品均不约而同用“美女”作商标

哈德门商标.jpg 哈德门2.jpg 哈德门3.jpg 哈德门4.jpg 民国时期的国军特供香烟.jpg

中华人民共和国成立后，1950年政务院颁布《商标注册暂行条例》，这是中华人民共和国的第一个商标法规。1963年颁布《商标管理条例》；商标管理开始趋向规范化。

但这部法颁布还不到三年，就遭受了极大的冲击。

1966年——1976年，十年动乱，商标管理机构被撤销，干部全部下放劳动，一大批的传统名牌商标被砸烂。

结果商标设计上出现了具有中国特色的“标准化”、“通用化”，弄得市场上到处是“红旗”、“东风”、“跃进”、“工农兵”。即使这样，这些商标也不能乱用。

商标专用权的概念更淡化了，仿冒现象见怪不怪。中国的商标法制名存实亡。

1982年8月23日，五届人大常委会第24次会议颁布了《中华人民共和国商标法》，1993年2月22日进行了修订，2001年10月27日和2013年8月30日进行了第二次和第三次修行，2014年5月1日实施，形成了现在的商标法体系。

◆ 资料4：你知道我们生活中有哪些种类的商标吗？

商标的分类：我国一般把商标分为四种，即文字商标、图形商标、立体商标和组合商标。2014商标法第八条：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

文字商标是只用文字构成的商标，如张小泉、同仁堂、白玉、黑妹等；

图形商标是只用图形构成的商标，如永久自行车的商标。图形商标的优点是不受各国语言文字的限制，但缺点也很明显一不便于呼叫。

立体商标是2001年商标法修订之后才开始允许注册的一种新类型商标，但国外早就存在，如许多著名品牌的酒瓶、香水瓶、甚至汽车的外形等。如浙江省第一个申请的立体商标。

组合商标则是文字、图形等内容的组合，这是我国目前最多的商标，如娃哈哈、西湖、红塔山、大红鹰等。

另外，还有非形象商标，如声音商标（中国2013年修订后2014年将实施）、气味商标等。

此外，还有其他的一些分类。

- ◆ 特别重要的一个变化：商标被抢注商标侵权与赔偿
- ◆ 针对目前抢注商标不当获利较为突出的现状，**新商标法设置了一项前所未有的条款：**
- ◆ 商标法第五十九条规定： 商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，**注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用其商标，但可以要求其附加适当区别标识。** 此项条款新增了一种注册商标权利人不能制止他人使用相同相似商标的情形，对于商标被抢注的企业来讲，此条是有利的，但对于商标注册人来讲，此条会加大商标维权的难度。
- ◆ **实践中**，很多企业，特别是中小企业是在生产经营达到一定规模后才申请注册商标，商标申请的时间大大晚于使用的时间，甚至商标具有一定知名度之后才开始申请，在新法的环境下，这些申请人能够从容应对商标抢注，但是由于你申请比较晚，在你申请前，其他人已经开始使用与你相同的商标了，以后即使你取得了注册，也可能不能制止他人使用相同和相似商标，就不能完全享有注册商标的专用权利。
- ◆ **解决此种困局**，一些商标申请人需要改变申请观念，即在商标设计好还未使用时即提出注册申请，以获得更早的申请日，有助于注册后的维权工作

二、商标权的取得——商标注册申请

1、注册商标的概念（我国实行商标注册原则，未经注册的商标不受法律保护。）

第六十三条 使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。

注册标记包括®和®。使用注册标记，应当标注在商标的右上角或者右下角。

2、商标注册原则

3、怎么注册

虽然商标局隶属于工商总局，但注册商标不在工商局注册，两个途径：一，去北京的国家商标局注册；二，委托代理公司注册，费用一千多元。基本流程是：

- （1）查询确定下来的商标名称，主要目的是看是否与在先权利人所注册的商标冲突，相同或近似（非必经程序，但建议要做，以免白花钱）
 - （2）准备材料，图样10张，长宽不大于10cm，不小于5cm。准备公司营业执照副本复印件+盖公章（个体户：营业执照复印件，身份证复印件+签名、申请书）
 - （3）按商品和服务分类表确定使用商标的类别，开始申请
 - （4）从递交申请到收到受理通知书需要1个月周左右的时间，
 - （5）初审公告，是否提出异议；核准公告，
- 最后发给商标注册证，现在整个过程需要时间大约在一年半左右的时间！

- ◆ 以**三维标志**申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，并提交**能够确定三维形状的图样**，提交的商标图样应当**至少包含三面视图**。
- ◆ 以**颜色组合**申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，**说明商标的使用方式**。
- ◆ 以**声音标志**申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的**声音样本**，对申请注册的声音商标进行**描述**，说明商标的使用方式。对声音商标进行**描述**，**应当以五线谱或者简谱**对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；**无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述**；商标描述与声音样本应当一致。
- ◆ 申请注册集体商标、证明商标的，应当在申请书中予以声明，并提交主体资格证明文件和使用管理规则。
- ◆ 商标为外文或者包含外文的，应当说明含义

- ◆ **商标法第十条规定不得作为商标使用的标志有：**
- ◆ （一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；
- ◆ （二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外；
- ◆ （三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；
- ◆ （四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；
- ◆ （五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；
- ◆ （六）带有民族歧视性的；
- ◆ （七）夸大宣传并带有欺骗性的；
- ◆ （八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。地名第二含义：如凤凰，既可以作为地名使用，同是又是传说中的一种神鸟，所以可以作

- ◆ 下列标志不得作为商标注册：
- ◆ (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
- ◆ (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
- ◆ (三)其他缺乏显著特征的。

- ◆ 但是，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。
- ◆ 三维标志商标也称立体商标，有三项限制条件（见书本）

◆ “太和” 商标异议案

- ◆ 1992年5月5日，西安市新城区卫生工作者协会姚树峰中医内科诊所向国家工商行政管理局商标局申请在第25类保健鞋垫、保健袜垫商品上注册“太和”商标。经商标局审查，初步审定“太和”商标，并在第422期《商标公告》上发布初步审定公告。在该商标异议期间，异议人陆某对该“太和”商标提出了异议，被异议人按期进行了答辩。

异议人理由：被异议商标“太和”为安徽省一县名，故不能作为商标注册。

被异议人答辩理由：“太和医室”为河北武安县县城三街姚氏于咸丰末年所创。“太和”意为愿普天下的人平和安舒、健康长寿。自初创后，历代传人秉承家技，宏扬发展，成就斐然。“太和医室”在西安等地颇有影响，并有专题报导，其“太和”的含义已大于作为行政区划的“太和”县名，故请求给予该商标核准注册。

- ◆ 异议裁定：根据当事人陈述的事实和理由以及提供的证据，商标局进行了裁定。商标局认为，“太和”一词在辞海中有多种解释，其中第一解释为“中国哲学术语”，原出《易·乾·象辞》：“保合太和，及利贞”，即愿普天下之人平和安舒，被异议商标“太和”正是取自于此意。“太和”商标的上述含义已强于作为行政区划的“太和”县名。根据商标法第8条第2款中“地名具有其他含义的除外”的规定，故异议不能成立，根据《商标法》第19条的规定，经初步审定的第676984号“太和”商标予以核准注册。

例：依照我国商标法的规定，下列商标中不违反法律禁止性规定的是（ ）。

- A、“风帆”牌蓄电池 B、“红牛”牌汽油 C、“防潮”牌油毡
D、“耐用”牌防盗门 E、“明亮”牌灯泡 F、“暖和”牌棉裤
G、“粮食”牌白酒 H、“甜蜜”牌衬衣 I、“温暖”牌毛衣

4、取得商标权的原则

a注册在先原则； b使用在先原则； c注册不损害在先权利原则； d注册优先权原则（详见下节专利法）。

- ◆ 商标价值的影响因素
- ◆ 法律人关心的是商标的法律状态，商人最关心的应该是商标的价值了。
IPAD商标让苹果公司付出了6000万美金的代价，一个可口可乐商标价值几百上千个亿，1994年，美国《金融世界》杂志发布的世界最有价值品牌排名通过新华社报道，首次传播到了我国。当时可口可乐品牌价值359.5亿美元，万宝路品牌价值330.45亿美元，使中国人为之震惊！到底商标的价值是由哪些因素所影响的呢？
- ◆ 决定商标价值的因素绝对不是商标文字的多少，而是有三个层次。
- ◆ 第一个层次：商品质量、售后服务质量，最后归结为商誉。这个层次是决定商标价值的最基础的层次。如果这个层次的因素出现问题，其他的因素就发挥不了作用了。海尔商标有价值，最根本的在于海尔电器商标质量过关和售后服务态度好。三鹿奶粉的质量出现问题，商标价值从几十个亿化为乌有。
- ◆ 第二个层次：知名度。决定商标的最表面因素是知名度，一般意义上，知名度越高的商标价值越大。当然，有的商标留下的是恶名，只能降低商标的价值，而非提高商标的价值。只有在良好的商誉基础上提高知名度，才能提高商标的价值。
- ◆ 第三个层次：商标标志的文字选择、图案设计。商标标志的设计非常重要，一个好的商标能够迅速给人留下良好的印象，一个没有特点的商标即使出现若干次可能给人留下的印象也不深。另外商标标志的选择、设计应符合商品、行业特点，比如“海飞丝”洗头水，体现那种飘逸。

优先权原则

第二十四条

商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

依照前款要求优先权的，应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的，视为未要求优先权。

在先权原则

第三十一条

申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

◆资料： 驰名商标

◆ 驰名商标的概念

- ◆ 驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。

◆ 驰名商标的认定

◆ 第十四条

认定驰名商标应当考虑下列因素：

- （一）相关公众对该商标的知晓程度；
- （二）该商标使用的持续时间；
- （三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
- （四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
- （五）该商标驰名的其他因素。

注意认定途径：一个是行政认定，一个是司法认定（驰名商标的司法认定问题.doc）。

驰名商标的司法认定问题的几个细节问题（见书本P）

◆ 驰名商标的保护

◆ 第十三条

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

案例见《经济法教程》浙江大学出版社2015年版
周黎明著

三、商标注册的一般程序见下页

四、商标权人的权利和义务

权利：1、商标专用权 2、商标转让权 3、使用许可权 4、商标投资权

义务：1、依法使用注册商标的义务。连续三年停止使用，可依法撤销其注册商标。

2、保证商品质量的义务；3、标明注册标记的义务；4、交纳各项费用的义务

例子：某企业1996年6月注册了“荣能”商标，但该企业除了偶尔在电视上作广告之外，一直未使用它。2000年1月，商标局以该商标连续三年未使用为由，撤销了该商标。请问：商标局的作法能否得到法律支持？

五、注册商标的期限和续展

（有效期10年，到期前一年内可申请续展，到期后有六个月的宽展期。每次续展注册的有效期限也为10年）

◆ 审查与核准的程序

- ◆ 形式审查
- ◆ 实质审查
- ◆ 初步审定和公告异议
- ◆ 核准注册和公告
- ◆ 复审

(转上页)

◆ 两“蒙牛”顶牛——（商标商号冲突） 见书本P218

- ◆ 同城之内，竟有两家叫做“蒙牛”的企业，而且老板都姓牛，不知就里的人们很自然就将两家企业想到了一起。

蒙牛乳业是内蒙古的风云企业，1999年1月注册成立并向国家工商总局商标局申请注册“蒙牛”商标，2000年5月28日被核准注册。2000年8月6日，“蒙牛”商标被内蒙古自治区工商局认定为自治区第一批著名商标。短短几年，蒙牛乳业经过了令人咋舌的高速增长，1999年销售收入在全国行业排名第119位，2004年则已经排在了第二位。

2002年2月，“蒙牛”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，并先后在内陆及港澳台地区的1至45类产品与服务上全部注册，同时在上世界上60多个国家与地区进行了注册。

◆ 而就在这期间，内蒙古的另一家企业——蒙牛酒业也悄然面市。据该公司资料显示，这家创建于2001年7月的民营企业，集开发、科研、生产、营销为一体，2003年二期工程投产后，年产奶酒6万吨，是中国乃至亚洲目前最大的奶酒生产基地。

蒙牛酒业是在内蒙古呼和浩特一个经济开发区工商分局注册的，蒙牛乳业公司事先并不知情，2002年才知道有这么一个公司。随后，他们向当地工商行政管理部门反映，要求撤销蒙牛酒业公司的“蒙牛”商号，但没有结果。

蒙牛乳业的商标是2000年获得注册，2002年被评为中国驰名商标（此前只是著名商标）。普通商标只在同一类别中享受保护，国家驰名商标才享受跨类别的所有类别保护。而蒙牛酒业2001年注册成立，是在蒙牛乳业评为全国驰名商标以前，因此不能按国家驰名商标保护规定来处理。

◆ 当时的合作方及不少股东都提出了蒙牛酒业对蒙牛乳业这个知名品牌潜在的威胁。但2004年以前，蒙牛乳业公司开始准备香港上市事宜，这一问题被暂时搁置下来。

问题再次被提起源自一起投诉。2004年8月，浙江义乌一位叫项羽忠的经销商打电话向蒙牛乳业公司投诉，说蒙牛酒业昂格丽玛江浙沪销售总公司在招商中存在欺骗行为，他说他交了10万元保证金，并一次性购买了30万元的产品，花十来万元租了店面，结果该公司在中央台投入8000万元广告等承诺却没有兑现，致使产品无法销售。

项羽忠的投诉让蒙牛乳业大吃一惊。因为项羽忠在解释他为什么找蒙牛乳业投诉时说，他当时就是冲着蒙牛乳业这个全国知名企业去的，而蒙牛酒业昂格丽玛江浙沪销售中心的有关人员也解释说蒙牛酒业就是蒙牛乳业下属的公司。随之而来的上海、江苏等地的投诉也证明了项羽忠的说法。

- ◆ 根据投诉，2005年年初，呼市工商局专门到江浙沪地区进行了调查。通过走访经销商，发现反映上当受骗的经销商大多是冲着蒙牛乳业这个国家知名品牌而来，反映上当受骗的理由也大致相同，涉及的金额少的几万元多的几百万元。
- ◆ **分析：**我国工商管理制度中，国家商标局是授予注册商标证的惟一机构，各地工商局下属的商标管理部门承担的任务是对商标的正常使用秩序进行管理，无权批准或授予商标。而各地工商行政管理部门根据法律法规的规定，却可以对本辖区内的企业名称进行登记和管理，即企业名称在县级以上工商局登记后即可取得一定地域范围内的企业名称权。在这种情况下我们不能仅仅指责企业不法，还应该回过头来审视法律制度，包括一系列工商行政管理规范。 案例见《经济法教程》浙江大学出版社2015年版 周黎明著

◆ **例：**某市水果罐头甲厂生产菠萝罐头，使用“常乐”牌未注册商标。没过多久，本市的另一家水果罐头乙厂派人找到甲厂领导，指责甲厂使用的“常乐”商标与他们厂使用的“长乐”商标发音相同，要求甲厂立即停止使用，否则就构成侵权，要到法院起诉。后经了解，乙厂使用的“长乐”商标也是未经注册的商标的，但是使用在先。请问：

- 1) 未注册商标是否具有商标专用权？
- 2) 乙厂对甲厂提出的要求是否合法？
- 3) 作为甲厂的法律顾问，应对此采取何种措施，保护自己厂的“常乐”商标的使用权。

六、商标侵权及其保护 （了解商标侵权行为见下页）

例：《妈呀，妈》小品案。（见书本）

例：狗不理包子商标侵权纠纷案（见书本）

商标侵权经典案例_狗不理.pptx

- ◆ 商标侵权行为
- ◆ 第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
 - ◆ (一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；
 - ◆ (二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
 - ◆ (三)销售侵犯注册商标专用权的商品的；
 - ◆ (四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
 - ◆ (五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
 - ◆ (六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；
 - ◆ (七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
- ◆ 第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

- ◆ 第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
- ◆ 三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
- ◆ 商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

- ◆ 第六十三条 侵犯商标专用权的**赔偿数额**，按照权利人因被侵权所受到的**实际损失确定**；**实际损失难以确定的**，可以按照侵权人**因侵权所获得的利益确定**；**权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的**，参照该商标许可使用费的**倍数合理确定**。**对恶意侵犯商标专用权，情节严重的**，可以在按照**上述方法确定数额的一倍以上三倍以下**确定赔偿数额。赔偿数额**应当包括**权利人为**制止侵权行为所支付的合理开支**。
- ◆ 人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
- ◆ 权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费**难以确定的**，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予**三百万元以下的赔偿**。**精神损**

例：“大白兔”奶糖案。上海生产的“大白兔”奶糖可说是家喻户晓，味道香，口感好，故产品供不应求，有一段时间甚至脱销。而湖南省某市一家糖果厂生产的奶糖滞销，质量不好。后来该糖果厂用“小白鼠”作为奶糖的商标。图象一样。包装、颜色、布局也一样。争相购买。答辩：

- ◆ 1) 兔和鼠是截然两种不同的动物，不属于同一产品，正常人均不会混淆；
- ◆ 2) 兔和鼠不论从字形上还是读音上都不同，不能定为近似商标，购不成侵权行为。

问：湖南省该糖果厂的行为是否构成商标侵权？

◆例：中国首例域名争议案

- ◆ 1999年3月10日北京市海淀区人民法院开庭审理了广东科龙（容声）集团有限公司诉吴永安（永安制衣厂负责人，个体工商户）域名争议案。原告为“科龙”注册商标的商标权人，并自1992年起将商标用于其所生产销售的家电产品上。1997年下半年，原告开始申请注册kelon.com.cn域名，但发现被告已于1997年9月以“永安制衣厂”的名义在中国互联网信息中心（CNNIC）申请注册了该域名，但未经其同意。被告的行为使原告无法使用其商标KELON注册同一域名。开庭审理前，被告向CNNIC申请注销其域名，科龙公司以被告吴永安自动停止了侵权行为为由，向一审法院提出撤诉申请。

（类似的案例还有宜家（www.ikea.com.cn）、舒肤佳（www.safeguard.com.cn）等域名争议，结果类似）

◆例：“乡巴佬”案

- ◆ 湖南常德市慧天科技服务有限公司乡巴佬酒业分公司在第33类酒商品上申请注册“乡巴佬”商标，被商标局驳回不服，申请复审。

商标局驳回的主要理由：该商标有贬低人的含义，用作商标具有不良影响。

申请复审的主要理由：“乡巴佬”没有贬低人的含义，使用于酒，有返朴归真之感，该商标出自农民自谦之词，是申请人公司共同心愿。该词是对农民善意称颂，没有不良影响，且来自民间传说。

处理结果：经复审，商标评审委员会认为：商标一旦进入市场，将面对广大消费者，而消费者并不了解“乡巴佬”一词是申请人集体的心愿。客观上，“乡巴佬”是对农民的鄙称，反映出对农民群众的不尊重，用其作商标易产生不良影响。依据《商标法》第8条规定，商标评审委员会终局决定，湖南常德市慧天科技服务有限公司乡巴佬酒业分公司在第33类酒商品上申请注册“乡巴佬”商标予以驳回。

◆ 宣告商标无效问题：

- ◆ 根据商标法44条规定：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
- ◆ 商标局做出宣告注册商标无效的决定，应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起**九个月内**做出决定，并书面通知当事人。有**特殊情况**需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以**延长三个月**。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

◆ 许多好商标成了无人认领的“孤儿”

- ◆ 最近，杭州钱塘商标事务所在整理文件资料时，“发掘”出上千份已经泛黄的商标注册证，绝大多数商标的注册时间已超过了八年，其中不乏一些知名企业。比如“好乐多”、“兴合”，都成了无人认领的“孤儿”。考虑原因有哪些？
- ◆ 一些孤儿商标其实很有创意
- ◆ 在尘封已久的老商标中，许多都是极富商业价值的。钱塘商标事务所商标代理人陈文钧说，像“乡下老鼠”、“黑鸭子”，形象生动、很有画面感，但注册这2个商标的中璟实业有限公司和杭州铁路天云商场不知道为什么最后没有前来认领。
- ◆ 另外如“贤内助”酱菜、“爱妻”漱口水.....这些商标的创意非常好，如果当时企业能够好好做一番推销，很有可能成为老百姓熟知的知名品牌。
- ◆ 更好的一个是“屈原”牌粽子，巧妙地利用了历史典故，可惜的是，这个商标现在依然孤独地躺在纸堆里。

◆ 老商标折射出上世纪末的杭州经济

- ◆ 商标是经济发展的先锋，一个地区的商标注册情况，往往反映了当地的经济特色。从闲置的商标中，很能反映出当地经济的起伏。
- ◆ 在这些闲置商标中，数量最多的就是服装类（第24类和第25类），大约占了四分之一以上，而当时的历史的确也是那样：上世纪80、90年代，余杭、临安一带丝绸被面兴旺发达，仅余杭一地，就注册了上百件丝绸被面的商标，可以看出，那时服装产业已是杭州经济的重要组成部分了。
- ◆ 90年代保健品尤其是营养液曾经火爆过一阵。这些老商标里，不乏当年的繁荣。杭州百灵花海洋补剂公司申请了“神龟”儿童营养液，还有海润、天灵、健翔、凤丽婷等十几个营养液商标陆续被国家商标局批准，不过遗憾的是，这些公司还没来得及推出这些商标，就在商海中湮没了。

- ◆ **企业寿命不长，“树木”变“树桩”**
- ◆ 造成商标权闲置的主要原因是比起其他知识产权，商标申请周期过于漫长。版权是自作品形成之日就能够确权；专利时间虽长短不一，但是其中与商标性质最为相近的外观设计，一般从申请到授权，也只需要8个多月。
- ◆ 但申请注册一个商标，目前最快的大约需要18个月，在所有商标申请中，只有10%的企业能够享受到这一“加急服务”；
- ◆ 普通的办理速度大约26个月，两年多一点，这类在商标申请中占了大头；
- ◆ 最慢的，企业要等上30个月——两年半的漫长等待使得“树木变树桩”的情况很普遍。
- ◆ 而中国企业的平均寿命只有7—8年，小企业的平均寿命更是不到3年，每年有近100万家企业倒闭，所以在两年多的申请时间里，商标还在、企业不在的情况并不鲜见，最后申请成功的商标因此成了“孤儿”。

第三节 专利法

- ◆ 美国专利局的大门上，刻着一行字：
- ◆ **The patent system added the fuel of interest to the fire of genius. ----- Lincoln**
- ◆ 专利制度16世纪的英国就已经开始，但美国是第一个把专利权写入宪法的国家——用国家的根本大法来保护人们的专利权，极大地激发了人们发明创造的动力。
- ◆ 日本对发明创新的鼓励是多方面的。早在1885年4月18日，日本就制定并颁布了《专利法》。为了纪念这一天，从1955年起日本就将每年的4月18日确定为“发明日”。每年的这一天，日本全国很多地方都要举办形式多样的发明展览会，并向发明创造者颁发奖状，媒体也花大力气宣传鼓励人们去开动脑筋，创造发明。从1960年开始，又将每年的4月16日至22日确立为“科学技术周”，以促进科学技术的发展。日本人的模仿和深化能力惊人。

一、专利权的概念及相关立法

是指由国家专利机关授予发明人、设计人或所属单位等专利权人，在一定期限内对其发明创造享有的专有权利。

“专利”一词，通常有三种意思：一是指专利局授予申请人的专利权；二是指受专利法保护的专利技术；三是指专利局颁发的专利证书。我们在法律上，一般是指专利权，即专利机关依法授予专利申请人在法定期限内对其发明创造享有的专有权。

我国于1984年3月12日第六届人大常委会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》，1985年4月1日施行。1985年1月19日国务院批准国家专利局发布了《中华人民共和国专利法实施细则》。1992年9月4日进行了修订。2000年8月25日九届人大常委会第十七次第二次修订，2001年7月1日施行。最近一次修订于2008年12月27日通过，现予公布，自2009年10月1日起施行。

都市快报报道：你热它会凉，你冷它会热

——浙大学生研制出神奇衣服

浙大材化学院三位研究生研制出一种能自动调节温度的衣服，你感觉热时它会吸收一些热量，你感觉冷时它又能补充一些热量。在刚刚结束的第九届“挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛”上，该作品获得一等奖。三位研究生在衣服面料中“粘”进了一种烷烃类特殊材料，它很容易从石油中提取，但一般情况下会当做废料处理。在33摄氏度左右，它会“变性”：高于这个温度可以吸收热量，从固态转变为液态，低于这个温度则释放热量，从液态凝结为固态。而研究表明，皮肤温度在33.4摄氏度时，人最舒适。

研究者之一顾鸿艳说，他们把这种材料灌进肉眼看不见的“纳米胶囊”中（如果把一根棉丝直径放大到5厘米，“纳米胶囊”相当于上面的一粒灰尘），然后制成半透明的乳液，可以把衣服或面料放在里面浸一浸，也可用喷嘴喷在衣物上，一件衣服的材料成本大概是两元钱。胶囊内层坚硬，所以搓洗也没关系。

另一位研究者卢福军说：“这种衣服很适合小孩和爱运动的人，人体运动时会产生大量热量，穿这样的衣服能舒服点，少出些汗，要经常进出空调房的人也特别适用，气温突然变化会感冒，这种衣服有缓冲作用。”

三人研制出这种材料后，兴致勃勃做了三件衣服亲身试验。一件短袖T恤送给导师罗英武教授穿，他习惯晚上跑步，说穿着很舒服。

这次挑战杯大赛上展出的，是件嫩黄色长袖运动T恤，引来很多专家和企业的关注。目前他们正和上海一家面料厂讨论技术转让，“转让费少说也要几十万吧”，顾鸿艳说。

◆ 问题:

该设计可否申请专利?

若不可以, 说明理由。

若可以申请专利, 属于什么类型的专利?

二、专利权法律关系

1、主体（注意职务发明问题 见下页）

2、客体（即专利的种类）

- ◆ 专利权的客体是指专利法保护的对象，即依法可以取得专利权的发明创造。我国专利法所称的发明创造，是指发明、实用新型和外观设计。
- ◆ 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。分为产品发明和方法发明。
- ◆ 实用新型，是指对产品的形状、构造或者二者的结合所提出的、适于实用的新的技术方案。在一些国家被称为小发明。
- ◆ 外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

不授予专利权的情况：

- 1、违反国家法律、社会公德或者侵害公共利益的发明创造；
- 2、科学发现；
- 3、智力活动的规则和方法；
- 4、疾病的诊断和治疗方法；
- 5、动物和植物品种；
- 6、用原子核变换方法获得的物质。

注：动物和植物品种的生产方法，可以授予专利权。

了解职务发明:

◆ 第六条

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

- ◆ 令人欣喜的是，近些年，中国的专利申请进程呈明显上升态势。
- ◆ 2014.10.30汤森路透旗下的知识产权与科技事业部发布报告，指出中国在2013年的发明专利申请量超过60万件，已超日本与美国成为全球专利产出总量最多的国家。中国内地的发明专利申请总量已经从2003年的40万件增长到2013年的62.9万件，超过美国20多万件，领跑全球。
- ◆ 其中，华为、阿里巴巴、联想集团等企业在海外专利申请量位居前列；
- ◆ 中国制药领域专利数量增速最快，但该领域知识产权质量有待提高。报告显示，在生物碱/植物提取物领域的专利中，中国约占80%的全球份额；在药物活性的一般专利领域，中国约占60%的全球份额。但是，这些专利申请并非像美国那样来自于高等院校或企业，而是主要来自众多个体发明人。因此，其知识产权的质量很可能并不稳定。

三、专利权人的权利和义务 权利：

- 1、独占权；
- 2、转让权（必须书面形式，经专利局登记和公告后生效）；
- 3、许可权（必须书面形式）；
- 4、投资权；
- 5、阻止权；
- 6、标记权；
- 7、请求处理和诉讼权；
- 8、放弃权。

义务：

- 1、实施专利发明；
- 2、缴纳专利费（专利相关费用详见下页）
- 3、职务发明单位给予发明人或设计人报酬奖励；

资料2： 申请一项专利到底要花多少费用？

四、授予专利权的条件

（授予专利权的发明和实用新型应具备新颖性、创造性和实用性）

新颖性是发明或者实用新型能否授予专利权的首要实质性条件，判断新颖性要满足下列条件：

- (1)在专利申请提交前，没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过。这里的出版物不但包括书籍、报刊、杂志等纸件，也包括录音带、录像带及唱片等音像件；
- (2)专利申请提交前，在国内没有公开使用过，或者以其他方式为公众所知。所谓公开使用过，是指以商品形式销售、或用技术交流等方式进行传播、应用，以至通过电视和广播为公众所知；
- (3)在该申请提交前，没有同样的发明创造由他人向专利局提出过专利申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

我国专利法规定，发明专利的创造性指同申请日以前的已有技术相比有突出的实质性特点和显著的进步。一项发明具备了新颖性，不一定就有创造性。因为创造性侧重判断的是技术水平的问题，而且判断创造性所确定的已有技术的范围比判断新颖性所确定的已有技术范围窄。突出的实质性特点是指发明与已有技术相比具有明显的本质区别，即该发明不是所属技术领域的普通技术人员能直接从已有技术中得出构成该发明创造的全部必要的技术特征。显著的进步指该发明与最接近的已有技术相比具有长足的进步，或者表现在发明创造克服了已有技术中存在的缺点和不足，或者表现在该发明所代表的某种新技术趋势上，或者反映在该发明所具有的优良或意外效果之中。我国专利法规定，实用新型的创造性，是指同申请日以前已有技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。这里可见发明创造的“突出的”和“显著的”就是判断发明和实用新型创造性的区别所在。

我国专利法规定，实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。能够制造或者使用，是指发明创造能够在工农业及其它行业的生产中大量制造，并且应用在工农业生产上和人民生活中，同时产生积极效果。这里并不要求其发明或者实用新型在申请专利前已经过生产实践，而是分析和推断在工农业及其它行业的生产中可以实现。

五、专利申请和审批

1、先申请原则；

申请的审批；对发明专利，我国采取“早期公开，延迟审查制”，包括形式审查和实质审查（自申请日起满18个月，即行公布，专利局也可以应申请人的请求，早日公布。实质审查是应申请人的要求进行的，申请人从申请日起三年内，要求实质审查。无正当理由逾期不要求实质审查的，该申请即被视为撤回）；对实用新型和外观设计专利，只有形式审查。

2、单一性原则（一发明一申请原则）

3、优先权原则

六、专利实施的强制许可

- ◆ 三种情况下，专利局可以给予该专利的强制许可。
- ◆ 1、具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时，国务院专利行政部门根据该单位的申请，可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。
- ◆ 2、在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。
- ◆ 3、一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

- ◆ 但是，要注意两点：第一，强制许可不是免费的；第二，获得许可的单位或个人不具有独占的实施权。
 - ◆ 例： 某甲曾获一汽车节油装置的专利权，后某乙对此种装置作了改进并获得国家专利，但某乙该专利的实施又必须借助于某甲专利的实施，此种情况属于（ ）。
- A、可以申请强制许可的范围 B、交叉强制许可
C、甲可以申请强制实施乙的专利 D、乙也可以强制事实甲的专利
- （请见书本分析）

七、专利权的期限和终止

- ◆ 期限：发明专利权为20年，实用新型和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日开始计算。
- ◆ 终止：专利权在期限届满时终止为正常终止，在期限届满前终止为提前终止。提前终止的情况有两种：一是没有按照规定缴纳专利年费；二是专利权人以书面形式声明放弃其专利权。

八、专利侵权与处理

注意：五种情况不视为侵犯专利权。

◆ 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。

（五）为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

◆ 第三节 著作权法.ppt

◆ 一、著作权的定义

◆ 狭义：包括著作人身权和财产权

◆ 广义：还包括了著作邻接权

◆ 我国还把图书、报刊出版者的权利也纳入了著作权。

◆ 二、著作权法的保护对象

◆ 著作权法第三条规定了八个内容。

◆ 不适用（三个内容）：1）法律法规及官方文件；2）时事新闻；3）立法、通用数表表格及公式。

◆ 三、著作权的主体：一般主体（可以包括国家）

◆ 四、著作权的内容：人身权、财产权

◆ 著作权法第十条规定了17项内容。（具体内容及案例详见《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年版 周黎明著）

第九章 市场管理法

第一节 反不正当竞争法

一、新修订的反不正当竞争法相关问题解析

相关立法：1993年年9月2日八届人大常委会第三次会议通过了《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反法）。

- **2017年11月4日**，该法由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，这是反不正当竞争法自1993年施行以来，第一次迎来重大修订。修订后的反法自**2018年1月1日**起施行。
- 修订原因：1、旧法已实施二十多年，随着经济高速发展，新问题、新矛盾不断出现。**有些是新的竞争行为，如刷单炒信、删除差评等；有些则是老的竞争行为又有了新的表现**，如过去的仿冒产品主要从商标、包装装潢上进行仿冒，但是**现在却出现权利冲突**的情形，比如将别人的**商标**注册为自己企业的**字号**，或是将别人的**包装装潢申请一个外观专利**。这些新问题新情况的出现，迫切需要新的条款予以整规、界定和明确。
- 2、另一方面，随着市场经济发展，我国法律体系不断完善，而继“旧反法”之后颁布的《反垄断法》就是其中之一。“旧反法”中一些涉及反垄断的条款跟《反垄断法》有交叉重叠，需要把“旧反法”中涉及反垄断的条款删除。

一、新修订的反不正当竞争法相关问题解析

（一）概念（著名的“反法第二条”）

修订后的反法第二条： 本法所称的**不正当竞争行为**，是指**经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为**。

本法所称的**经营者**，是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。

分析：这一条是著名的“反法第二条”，在反不正当竞争诉讼中发挥着“一般条款”的作用。在实践中，**当所涉及的不正当竞争行为并非反法具体条款能够评判但又确实严重危害市场竞争秩序时，往往可以通过对第二条的解释来进行规制**。反法修订后仍然保留这一条款，说明其确实具有不可替代的价值。值得注意的是，**为了防止在实践中“反法第二条”被滥用**，最高人民法院在相关判决中指出，虽然该条款可用于维护市场公平竞争，但同时**应当注意严格把握适用条件**：

- 同时应当注意严格把握适用条件：
- 一是法律对某种竞争行为**未作出特别规定**；
- 二是其他经营者的合法权益**确因**该竞争行为而受到了**实际损害**；
- 三是该种竞争行为因**确属违反诚实信用原则和公认的商业道德**而具有不正当性或者可责性。

（二）不正当竞争行为的种类（尤其关注新旧变化）

1、混淆行为

新反法对“山寨行为”的规制更加明确，有利于企业更好地保护其知识产权以外的标识类权益。

（修订后的第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系（见后图对比）：

- （一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
- （二）擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)；
- （三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
- （四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。）

（见后图对比）

第五条 ~~经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：~~

~~（一）假冒他人的注册商标；~~

~~（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；~~

~~（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；~~

~~（四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。~~

第六条 经营者不得**实施**下列**混淆**行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

（一）擅自使用**与他人有一定影响的商品**名称、包装、装潢等**相同或者近似的标识**；

（二）擅自使用他人**有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）**；

（三）擅自使用他人**有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等**；

（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的**混淆行为**。

- 其核心判断标准为“引人误认”
- “引人误认”除了包括引人误认为是他人商品，还包括误认为与他人存在特定联系。
具体而言就是，以前的“旧反法”强调的是商品仿冒，即消费者错把与A商品极端相似的B商品当成是A商品而购买来了；而新反法的“混淆”概念更加广义，它还包括没有把B商品当成A商品，但可能认为B商品是A商品这个厂家的二线商品，或者让消费者认为B商品和A商品这种大牌有合作，进而认定它的品质。这些，“新反法”都将予以打击并严惩。

- 一个好的产品经常遇到的问题就是层出不穷的各种“山寨”行为！“山寨”企业除了直接抄袭市场上的知名商品的商标或外观专利以外，更多地是将市场上有一定知名度的商品名称、企业名称、包装、装潢等用于自己的产品或服务，或者是将别人有一定知名度的商标注册为企业名称，等等。根据原反法第五条规定，权利人需要证明自己的商品是“知名”商品，其名称、包装、装潢为“特有”，而且要导致消费者“混淆”或者“误认”。
- 新反法的规定相对而言更为简单明确，只要相关权利“有一定影响”，就应受到保护；只要相关行为“引人误认为是他人商品”或者“与他人存在特定联系”，就应受到规制。

- 另外，实践中，演艺界已经发生了围绕**艺人艺名**的法律纠纷。但是，**在以往实践中，一般仍通过姓名权来进行维权。**事实上，艺名虽然是姓名权的一种，但通过传统的姓名权来维权，并不能使得**艺名后面蕴含的巨大商业利益获得充分保护。**
与姓名权不同，艺名具有明显的商标属性。名人的艺名承载着巨大的形象价值和精神感召力，当这一代号一旦用于商业活动时，该姓名所承载的符号含义马上会转化为最直接的广告效应和购买号召力（即眼球经济或注意力经济）。

删除了两条

~~第六条 公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者，不得限定他人购买其指定的经营者的商品，以排挤其他经营者的公平竞争。~~

—

~~第七条 政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定他人购买其指定的经营者的商品，限制其他经营者正当的经营活动。政府及其所属部门不得滥用行政权力，限制外地商品进入本地市场，或者本地商品流向外地市场。~~

—

2、商业贿赂行为

变化：新反法对于“商业贿赂”行为的界定更加明确，有利于企业更加清楚商业贿赂和正常的商业促销行为之间的界限，减少日常运营中的法律风险。

原反法第八条将交易对方单位纳入商业贿赂受贿对象予以规制，导致很多企业因向经销商、超市、医院等交易对方支付促销费用、提供折扣、免费商品或者器材等行为而被地方工商行政管理部门按照商业贿赂进行查处。

新反法则明确将商业贿赂的受贿对象规定为以下三类：见下页图。从而将商业贿赂的受贿对象限定于对交易对象负有职责和义务的个人或中间人（相当于交易对象的“代理人”）。比如，超市向供应商收取的“入门费”、医院向医药企业收取的各类赞助（包括常见的赠送医疗器械以促销医疗耗材的营销模式）、轮胎行业给付销售奖励的营销模式等等，这些行为过去在很多地方是被工商部门按照商业贿赂查处的，今后不宜再按商业贿赂查处。

根据此规定，交易对象本身被排除在商业贿赂对象之外，从而回到了商业贿赂应以对交易对象负有义务的代理人为对象的基本逻辑，有助于厘清商业贿赂与正常的市场竞争行为之间的界限。新法实施后，工商部门不能再以企业向交易对象提供折扣、支付费用等为由进行

第八条 经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。~~在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。~~

经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，~~必须~~如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。

第七条 经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：

- （一）交易相对方的工作人员；
- （二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；
- （三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入帐。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入帐。

经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。

3、虚假宣传行为

新反法关于虚假宣传规定的变与不变

新反法对于商业宣传行为进行了更加清晰严格的界定，**实际上扩大了反法在针对广告宣传行为的审查和违规惩处力度**，有助于行业知名企业打击行业内的“傍名牌”、“搭便车”等不正当竞争行为。

新旧对比明显：新法将原来作为前提条件的“引人误解”改为与“虚假宣传”相并列的情形（**旧法实际上造成对不正当竞争中宣传行为的缩小**），同时对可能的“虚假”或者“引人误解”的情形作了更为详细地列举，并将网络购物平台普遍存在的组织进行虚假评价和虚假交易等行为纳入管辖范围。

第九条 经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。 广告经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。	第八条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。 经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。
--	---

新增**虚假宣传的帮助行为**！新法第八条第二款规定：“经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引入误解的商业宣传。”该款规定是**虚假宣传的帮助行为**，即以组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引入误解的商业宣传。该规定有利于制止当前多发的线上“刷单”、线下雇“托”等虚假宣传行为。今后除了经营者对自己产品进行虚假宣传外，帮助他人刷单炒信、删除差评、虚构交易等行为，也将受到查处，网络水军、职业差评师等不法经营者将受到处罚。

（刷单炒信最高处罚大大提高！）

加大了对虚假宣传行为的处罚力度

（**刷单炒信最高可罚200万元！**）。

虚假宣传的法律责任由**旧法**“可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款”，调整为**新法**“处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。”

处罚力度明显加大，与广告法虚假广告的罚则基本保持了一致（发布违法虚假广告，旧广告法根据广告费用罚款1到5倍，现在最高可以处罚200万元），也可避免因为罚则不同导致执法人员在广告法和反不正当竞争法之间选择性执法。另外，新法第二十条第二款明确规定“经营者违反本法第八条规定，属于发布虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚”，明确了广告法优先适用的法律原则。

较高的起罚点，可以增强法律的威慑力，不过也可能带来操作性不强的问题，食品安全法、广告法等所谓史上最严的一批法规都面临着类似的执行难问题。

(4) 侵犯商业秘密行为

(商业秘密既包括技术信息，也包括经营信息。修订后的反不正当竞争法第九条规定：

- 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；
- (二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；
- (三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。
- 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

第十条 经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：

（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

第九条 经营者不得**实施**下列侵犯商业秘密**的行为**：

（一）以盗窃、**贿赂、欺诈、胁迫**或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知**商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为**，仍获取、披露、使用或者**允许**他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、**具有商业**价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

分析：相比现行法，将“商业秘密”的定义从原来的“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息”修改为“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息”。这一修改，将商业秘密的构成要件从原来的秘密性、保密性、价值性和实用性缩减为秘密性、保密性和价值性三个构成要件，显然，这一修改非常科学。

这是因为，商业秘密原有的“实用性”导致一些有“消极价值”但没有“积极价值”的商业秘密难以得到法律保护。商业秘密的价值性要求使用该商业秘密可以为权利人带来经济利益，提升竞争优势。这种利益包括现实的经济利益，也包括潜在的经济价值，具体表现为能够改进技术、提高劳动生产率或产品质量，能够有助于改善企业经营管理绩效、降低成本和费用。一般而言，具有价值性的商业信息同时也具有实用性，但是，在某些情形中，一些表面上不能直接实施应用的方案和技术，却同样耗费了研发人员大量的时间和财力，具有潜在的、“消极的”价值，例如，失败的研究数据、失败的经营方式和经营模式等，虽然不能带来积极的经济利益，但是能降低研发成本，减少研发的曲折和弯路，同样具有值得保护的经济价值，应当受到反不正当竞争法的保护。

删（5）倾销行为（低于成本价销售行为）（指的是经营者以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品。

删（6）搭售行为（指的是经营者违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。）（**反垄断法第17条有相关规定**）

第十一条 经营者不得以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品。 有下列情形之一的，不属于不正当竞争行为： （一）销售鲜活商品； （二）处理有效期限即将到期的商品或者其他积压的商品； （三）季节性降价； （四）因清偿债务、转产、歇业降价销售商品。	
第十二条 经营者销售商品，不得违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。	

(7) 不正当的有奖销售行为 (**原规定**三种情况：第一，采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；第二，利用有奖销售推销质次价高商品；第三，抽奖式的有奖销售，最高奖超过**5000元**。) 修订后 经营者进行有奖销售不得存在下列情形：

(一)所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖；

(二)采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；

(三)抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过**五万元**。

移动公司预存话费送礼品 是否违反反不正当竞争法？

(8) 商业诽谤行为 (又称诋毁商誉行为, 指以捏造、散布虚假事实的方式, 损害竞争对手的商业信誉或商品声誉的行为。)

第十四条 经营者不得捏造、散布虚伪事实, 损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。	第十一条 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息, 损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
--	---

新增了编造、传播误导性信息的情节。第二十三条: 处十万元以上五十万元以下的罚款; 情节严重的, 处五十万元以上三百万元以下的罚款。改变了旧法商业诋毁行为没有罚则的尴尬局面。

删 (9) 串通投标行为 (指投保者之间或者投标者与招标者之间相互串通、勾结, 以损害他人利益、排挤竞争对手的行为。)

删 (10) 公用事业或其他依法具有独占地位的经营者, 以胁迫或其他手段, 限定、排挤其他经营者公平竞争的行为; (反垄断法第6条, 第17条有相关规定) 删 (11) 政府及其所属部门滥用行政权力的行为。 (反垄断法

- 增加了：第十二条 经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规定。
- 经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：
 - （一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；
 - （二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；
 - （三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；
 - （四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

- 分析：显然，随着技术发展和网络成熟，竞争技术化、市场网络化已经成为反法必须面对的现实图景，而修订后的第十二条，正是立法者对这一现状的积极回应。
- 从条文内容看，第十二条列举的四种情形主要涵盖了此类干扰网络市场秩序行为的特征：第一，恶意排除其他经营者公平竞争机会；第二，恶意搭乘、利用其他经营者商誉；第三，干扰、剥夺网络用户的“自由选择权”。
- 个人认为，第十二条的出现，能够有效的解决网络市场竞争执法中存在的诸多争议和难题。值得注意的是，本条款中的第（四）项为概括性的一般条款，即本条采取的是“具体列举+兜底概括”的半封闭立法模式，这显然是考虑到未来网络技术的发展不能为立法者现在所预见，所以参照世界通行的立法模式进行处理，这也为将来可能发生的相关新型案件留下了解释的空间。

- 原十一种行为，减五加一后变成了其中。对新《反不正当竞争法》删除的五种限制竞争和垄断行为将如何规制？
- 本次修订的新《反不正当竞争法》的一个重要目的，就是实现与《中华人民共和国反垄断法》有机衔接。为此，删除了公用企业限制竞争行为、搭售行为、低于成本价销售行为、行政性垄断行为的规定。对于这四种限制竞争和垄断行为将通过《中华人民共和国反垄断法》进行规制。另外，还删除了串通招标投标行为的规定，对此种不正当竞争行为将通过《中华人民共和国招标投标法》进行规制。

处罚：第十七条 经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。

经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。

因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

经营者违反本法第六条（混淆行为）、第九条（侵犯商业秘密）规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人**三百万元**以下的赔偿。

■ 第十八条 经营者违反本法**第六条规定实施混淆行为的**，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，**可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。**情节严重的，吊销营业执照。

■ （原规定：责令停止违法行为，没收违法所得，~~可以根据情节处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，可以吊销营业执照；销售伪劣商品，构成犯罪的，依法追究刑事责任。~~）

■ 经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。

- 第十九条 经营者违反本法第七条规定**贿赂**他人的，由监督检查部门没收违法所得，**处十万元以上三百万元以下的罚款**。情节严重的，吊销营业执照。
（原规定：~~一万元以上十万元以下的罚款。~~）
- 第二十条 经营者违反本法第八条规定**对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传**，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处**二十万元以上一百万元以下的罚款**；情节严重的，处**一百万元以上二百万元以下的罚款**，可以吊销营业执照。
- 经营者违反本法第八条规定，属于发布虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。
（原规定：~~一万元以上十万元以下的罚款。~~）

- 第二十一条 经营者违反本法第九条规定**侵犯商业秘密**的，由监督检查部门责令停止违法行为，**处五十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。**

- （原规定：~~一万元以上十万元以下的罚款。~~）

- 第二十二条 经营者**违反本法第十条规定进行有奖销售**的，由监督检查部门责令停止违法行为，**处五十万元以上五十万元以下的罚款。**

- （原规定：~~一万元以上十万元以下的罚款。~~）

- 第二十四条 经营者违反本法第十二条规定妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。

■ 第二节 反垄断法律制度

■ 一、垄断的概念和形式

■ （一）垄断的概念

■ 二、我国反垄断立法的状况

■ 三、反垄断法的适用范围

■ 四、垄断协议

■ 五、滥用市场支配地位

■ 六、经营者集中

■ 七、滥用行政权力排除、限制竞争

■ 八、法律责任

纪末的审判：美国政府诉微软垄断案

- 见书本

北京首起反垄断诉讼案：“人人诉百度”案

广西部分地区米粉串通涨价案

可口可乐收购汇源几个经典时刻

第三节 产品质量法

一、产品质量法概述

（一）产品的概念

■ （二）产品质量的概念

■ （三）《产品质量法》的概念

■ 1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过了《产品质量法》，该法自1993年9月1日开始实施。2000年7月8日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《产品质量法》修正案，对产品质量法进行了全面修改。2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《关于修改部分法律的决定》，对《产品质量法》进行了第二次修正。

■ （四）产品质量法律制度体系

产品责任

- 产品责任：由于产品有缺陷，造成产品的消费者、使用者或其他第三者的人身伤害或财产损失，依法应由生产者或者销售者承担赔偿责任的一种法律责任。
- 产品责任是侵权责任。对生产者适用无过错责任（严格责任）；对销售者适用过错责任。
- 产品缺陷：是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险。产品有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，是指不符合该标准。（与瑕疵不同）看下页
- 缺陷包括：设计、原材料、制造装配、指示上的缺陷。
- 赔偿责任：实际损失，无惩罚性赔偿金。

- 生产者的免责：1.未将产品投入流通的；2.产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的；3.将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的。
- （可减轻责任或者免除责任的抗辩：担保的排除、非正常使用产品或者改装产品）

赔偿范围：

造成人身伤害的，侵害人应赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入（误工费）；

造成残疾的，还应当支付残疾者生活自助用具费、生活补助费、残疾赔偿金以及由其扶养的人所必须的生活费；

造成受害人死亡的，应当支付丧葬费、死亡赔偿金、以及由死者生前扶养的人所必须的生活费。

第四节 消费者权益保护法

一、了解消费者的含义。

消费者权益保护法所称的消费者，是指为了满足个人生活消费的需要而购买、使用商品或者接受服务的居民。简单地说，是指生活资料的消费者。

二、了解消费者的九大权利和经营者的八大义务。

消费者权利：1、安全保障权；2、真情知悉权；（知情权）3、自主选择权；4、公平交易权；5、依法索赔权；6、依法结社权；7、获得知识权；8、维护尊严权；9、监督批评权。

经营者义务：1、依法定或者约定履行义务；2、听取意见接受监督；3、保证商品或服务安全；4、不作虚假宣传；5、出具凭证和单据；6、保证质量；7、保证公平交易；8、维护消费者人身权。

消费者权益保护法立法

1993年10月31日八届全国人大常委会第4次会议通过，自1994年1月1日起施行。2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的规定》进行第一次修正。2013年10月25日十二届全国人大常委会第5次会议《关于修改的决定》第2次修正。

2014年3月15日，由全国人大修订的新版《消费者权益保护法》正式实施。

三、争议的解决途径

- 1、协商和解；
- 2、请求消费者协会调解；
- 3、向有关行政部门申诉；
- 4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁；
- 5、向人民法院起诉。

四、在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，消费者合法权益遭受损害，可以向销售者或者服务者要求赔偿；展销会结束或者柜台租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后，可以向销售者或者服务者追偿。

五、因侵犯消费者人身权引起的民事责任，同产品质量法，此处略。

六、因侵害消费者人格尊严或者人身自由的责任：1、停止侵害；2、恢复名誉、3、消除影响、4、赔礼道歉、5、赔偿损失。

七、消费者购买了三包产品，经过两次修理仍不能正常使用的，有权要求销售者承担退货、换货的责任。

八、经营者提供商品或者服务有欺诈行为的赔偿制度。
退一赔三制度及案例 见书本案例分析

第八章 金融法

（本课件配套教材《经济法教程》浙江大学出版社2015年版 周黎明著）

银行法内容课堂上将介绍银行法律实务，经济法通识课考试不做要求。课堂上将专门做一个银行法律风险防范的一个实务讲座。

第一节 证券法

一、证券与证券法

（一）证券的概念

证券具有以下法律特征：

1. 证券是资本性权利凭证

2. 证券具有要式性

3. 证券是占有性权利凭证

4. 证券是流通性的权利凭证

5. 证券是收益性权利凭证

- （二）证券的种类

- 我国《证券法》所涉及的证券包括股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券。

- 1、股票

- 股票是指股份有限公司依法发行的，表明股东按所持股份数额并依此享有权益和承担义务的一种有价证券。

- 2、债券

- 债券是指政府、金融机构以及公司或企业依法定程序向投资者发行的，约在一定期限内按约定的条件履行还本付息义务的一种有价证券。它的特点在于：

- （三）证券法的概念与原则

上述证券法的基本原则中，公开、公平、公正原则（即“三公原则”）是公认的最重要的原则。

- 二、证券市场主体
- （一）证券监督管理机构
- （二）证券交易所
- （三）证券公司
- （四）证券登记结算机构
- （五）证券交易服务机构

- 三、证券发行
- （一）证券发行的概念
- （二）股票的发行
- （三）债券的发行

- 四、证券交易
- （一）证券交易的程序
- （二）证券交易的种类

■ 五、证券上市

■ （一）证券上市的概念

■ （二）股票的上市条件

- 申请股票、可转换为股票的公司债券或者法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券上市交易，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

■ （三）股票上市的程序

■ （四）上市辅导

■ （五）股票上市的暂停和终止

■ （六）公司债券的上市

■ 六、禁止的交易行为

- （一）禁止内幕交易
- （二）禁止操纵证券交易价格
- （三）禁止欺诈行为
- （四）禁止编造和传播虚假信息

■ 七、上市公司收购

- （一）上市公司收购的概念
- 上市公司收购是指投资者公开收购股份有限公司已经依法发行、上市的股份，已达到对该股份有限公司控股或者兼并目的的行为。
- （二）上市公司收购程序
- 案例及分析若干（见配套教材书本P268--P270）

- 2010年4月，甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）经过必要的内部批准程序，决定公开发行公司债券，并向国务院授权的部门报送有关文件，报送文件中涉及有关公开发行公司债券并上市的方案要点如下：（1）截止到2009年12月31日，甲公司经过审计后的财务会计资料显示：注册资本为5000万元，资产总额为26000万元，负债总额为8000万元；在负债总额中，没有既往发行债券的记录；2007年度至2009年度的可分配利润分别为1200万元、1600万元和2000万元。（2）甲公司拟发行公司债券8000万元，募集资金中的1000万元用于修建职工文体活动中心，其余部分用于生产经营；公司债券年利率为4%，期限为3年。（3）公司债券拟由丁承销商包销。根据甲公司与丁承销商签订的公司债券包销意向书，公司债券的承销期限为120天，丁承销商在所包销的公司债券中，可以预先购入并留存公司债券2000万元，其余部分向公众发行。根据上述内容和证券法律制度的规定，分别回答下列问题：（1）甲公司的净资产和可分配利润是否符合公司债券发行的条件？并分别说明理由。（2）甲公司发行的公司债券数额和募集资金用途是否符合有关规定？并分别说明理由。如果公司债券发行后上市交易，公司债券的期限是否符合规定？并说明理由。（3）甲公司拟发行的公司债券由丁承销商包销是否符合规定？并说明理由。公司债券的承销期限和包销方式是否符合规定？并分别说明理由。
- （请见书本《经济法教程》浙江大学出版社2015年版 周黎明著 P268分析）

■ 第二节 票据法

■ 一、票据概述

- (一) 票据的概念与特征
- (二) 票据关系和非票据关系
- (三) 票据行为
- (四) 票据的更改、伪造和变造
- (五) 票据的丧失与票据时效
- (六) 利益偿还请求权
- (七) 票据的抗辩

■ 二、汇票

- (一) 汇票概述
- (二) 汇票的出票
- (三) 汇票的背书
- (四) 承兑
- (五) 汇票的保证

- (六) 付款
 - (七) 追索权
 - (八) 拒绝证书
-
- 分析并讨论书中的六个案例

- 三、本票

- （一）本票的概念
- （二）本票的格式
- （三）本票的见票

- 四、支票

- （一）支票的概念与特征
- （二）支票的种类
- （三）空头支票
- （四）支票的格式
- （五）支票出票的效力
- （六）支票付款的提示
- （七）支票的付款
- （八）支票适用汇票的有关规定

银行法

- 银行法及不良资产的清收处置等内容，课堂上将介绍本人担任多家银行法律顾问以来积累的办案过程中的银行法律实务，以实际案例作为分析基础，作一个专题讲座。（详见：《经济法理论与实务》浙大出版社2018年版 周黎明著）

第九章 税法

（具体内容及案例详见《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年11月第一版2019年印刷的新形态教材版本 周黎明著 注意2018个税法修正后的调整内容）

- 第一节 税法概述
- 第二节 流转税法律制度
- 第三节 所得税法律制度
- 第四节 其他税类法律制度
- 第五节 税收征收管理法

第一节 概述

一、概念和特点

国家财政收入的最主要来源。

是指国家为了实现其职能，凭借政治权力，按照法定标准，无偿地、强制地取得财政收入的一种特定分配关系。

特征：

- 1) 固定性；
- 2) 强制性；
- 3) 无偿性；

二、税法的构成要素

首先要求搞清楚几个概念：①征税主体、②纳税主体、③征税客体、④征税对象、⑤税种、⑥税目、⑦税率、⑧纳税环节、⑨纳税期限、⑩减税免税。

征税主体：国家的征税机关；（国税局、地税局、海关）

纳税主体：纳税人；税法规定的直接负有纳税义务的社会组织和个人；

征税客体：也即征税对象，指的是征纳税主体权利义务所指向的对象。通俗地讲，是指：“**对什么征税**”。

税种：税收的种类，通俗地讲，是指：“**征的是什么税**”。

税目：具体的征税项目。

税率：应纳税额与征税对象之间的比例。我国税法中的税率有三种：**比例税率**；**累进税率**、**固定税率**。

纳税环节：税法规定应该缴纳税款的环节。

纳税期限：缴纳税款的具体期限，分：**按期纳税**和**按次纳税**。

我国的累进税率

全额累进税率：按课税对象数额的大小划分若干等级，并按其达到的等级不同规定不同等级的税率。课税对象的金额达到哪一个等级，即全部按照相应的税率征税。目前，我国已经不采用该种税率。

超额累进税率：将课税对象划分为不同的部分，不同的部分规定不同的税率，对每个等级分别计算税额。

超率累进税率：按课税对象的某种比例来划分不同的部分，并规定相应的税率。我国土地增值税就是采用这种税率。

(注：我国没有超倍累进税率！)

税收的减免，涉及三个方面的内容：1) 起征点；
2) 免征额；3) 减免税；

起征点：税法规定一个开始征税的界限，征税对象的数额低于该界限的，不征税；

免征额：按一定标准从征税对象中扣除的部分，对剩余部分征税；

减免税：对应纳税额少征一部分税款、或者全部免征。

三、税收原则

在现代税收理论中，关于税收体系设计的最重要的原则，一是效率原则；而是公平原则。

1、效率原则

包括两层含义：一是税收要保持中立性，避免影响和干扰纳税人的生产经营和投资决策、储蓄和消费选择；二是国家征税除了使纳税人因纳税而损失或牺牲这笔资金外，最好不要再导致纳税人的其他经济损失，不应再产生额外负担。

2、公平原则

指征税应根据经济能力或纳税能力平等分配负担
经济能力（纳税能力）不同的人应负担不同的税收。

四、税种的分类

国际上对税收的分类有多种方法，如按照经济性质分类、按课税对象性质分类等。

我国的税种分类方式有：

（一）按课税对象的性质分类

- 1、**流转税**；包括：**增值税**、**消费税**、**营业税**、**关税**）我国税制体系的主体；
- 2、**所得税**；包括：**企业所得税**、**个人所得税**等；
- 3、**资源税**；包括：**资源税**、**城镇土地使用税**、**土地增值税**、**耕地占用税**、**农（牧）业税**；
- 4、**财产税**；包括：**房产税**、**城市房地产税**、**契税**；
- 5、**行为税**；包括：**印花税**、**车船使用税**、**车船使用牌照税**；**屠宰税**、**筵席税**、**船舶吨税**；

(二) 按管理和使用权限分类

- 1、**中央税**。属于中央财政固定收入的税种，包括：关税和消费税，海关代征增值税、消费税及对储蓄存款利息征收的个人所得税；
- 2、**地方税**。属于地方财政固定收入的税种，包括：个人所得税（不含储蓄存款利息税）、城镇土地使用税、房产税、城市房地产税、车船使用牌照税、屠宰税、筵席税、耕地占用税、契税、土地增值税、农牧业税等；
- 3、**中央地方共享税**。

（三） 按计税依据分类

可分为：从价税和从量税。

（四） 按税负能否转嫁分类

可分为：直接税和间接税。如：所得税属于直接税；消费税属于间接税。

第二节 流转税法律制度

流转税是以商品生产、交换过程中发生的流转额为课税对象的一种税。是我国的主体税种。

流转额包括：（1）**商品流转额**，指商品交换的金额（对销售方来说，是销售收入额；对购买方来说，是商品的采购额）；

（2）**非商品流转额**，指各种劳务收入或者服务性业务收入的金额。

我国现行税制中属于流转税的税种主要有：增值税、消费税、营业税、关税四个税种。

一、增值税

增值税1954年起源于法国，它克服了重复征税的弊端。

目前已经成为一个国际性的重要税种，有100多个国家
和地区采用之。

增值税，是指对销售货物或者提供加工、修理修配劳务
过程中的增值额征收的一种流转税。

1、纳税人和征收范围

纳税人：在中国境内销售货物或者提供加工、修理修配
劳务，以及进口货物的单位和个人。

由于增值税实行凭增值税专用发票抵扣税款的制度，对
于增值税纳税人会计核算的要求比较高。因此，我国参
照国际惯例，将纳税人按照其经营规模及其会计核算健
全与否，划分为一般纳税人和小规模纳税人。

2、**增值税的税率**

3、**免税项目和起征点**

4、**增值税的计算**

应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额

当期销项税额 = 销售额 × **税率** (注：销售额为不含税～)

进口货物：应纳税额 = 组成计税价格 × **税率**

组成计税价格 = 关税完税价格 + 关税 + 消费税

- * 两个计算题请见书本《经济法教程》(浙江大学出版社2018年版 周黎明著 分析)
- * 另外，2018年个税修改后，其中，将工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、**特许权使用费所得**合并，按照统一的综合累进税率征收个人所得税，并将**3500元**免征额提高到**5000元**。

* 税的问题是在当今的企业界非常普遍也非常严重的问题。税的问题风险很大，但最可怕的不是法律风险，而是不知道这是法律风险。

* （一）偷税的问题

偷税 改 逃税

2009年2月28日，第十一届全国人大常委会第七次会议审议通过了《刑法修正案（七）》。该修正案对刑法第二百零一条偷税罪作了重大修改。

例1：某公司9月份购进一批货物，对方单位开具一张标明增值税额为15万元的增值税专用发票。该公司当月全部将这批货物销售出去，销售额为234万元。假设该单位为增值税一般纳税人。请计算该公司9月份销售该批货物应缴纳的增值税额。

例2：某进出口公司8月份进口冰箱100台，关税完税价格为每台1000元，关税税率为10%；进口摩托车200辆，每辆关税完税价为1200元，关税税率为8%，消费税税率为10%。请计算应纳增值税。

二、消费税

1、概念和特点。消费税是国家为了体现消费政策，有选择地对生产、委托加工和进口的应税消费品和消费行为的流转额征收的一种税。

消费税是建立在增值税普遍征收的基础上，发挥特殊调节作用的税种。除了能作为财政收入外，更重要的目的是弥补市场调节的局限性，限制消费，促进收入公平分配。其特点：

- 1) 征收范围具有选择性；
- 2) 税率具有差别性；
- 3) 纳税环节具有单一性。（不是在生产、流通、消费所有环节征收，其纳税环节主要在生产经营过程中的某一特点环节。）

2、纳税人 3、征税范围 4、税率 5、纳税环节 6、计税依据

7、计算

应纳税额 = 销售额 × 税率

应纳税额 = 销售数量 × 单位税额

自产自用应税消费品，凡是用于连续生产应税消费品的，不纳税；用于其他方面的，应纳税，计算公式：

组成计税价格 = (成本 + 利润) ÷ (1 - 消费税税率)

应纳税额 = 组成计税价格 × 消费税税率

进口应税消费品的，按照组成计税价格计算纳税，公式为：

进口消费税应纳税额 = 组成计算价格 × 税率

组成计税价格 = (关税完税价格 + 关税) ÷ (1 - 消费税税率)

例3：甲公司生产烟丝6000箱，其中3000箱用于连续生产卷烟，其余送给某部门个人。烟丝成本为800元/箱，成本利润率为5%。计算消费税和增值税的销项税额。

第三节 所得税法律制度

所得税是指以纳税人的所得额为课税对象的一种税。所谓所得额，是指纳税人在一定期间内由于生产、经营等取得的可用货币计量的收入，扣除为取得这些收入所需各种耗费后的净额。我国现行所得税主要包括企业所得税(2007年3月通过《企业所得税法》，将内外资企业所得税率统一为25%)和个人所得税两种。

一、企业所得税

了解：纳税人、征税范围、税率、应纳税所得额的确定、应纳税额的计算以及税收优惠。

再投资减免优惠：外商投资企业的外国投资者，将从企业取得的利润再投资于该企业，增加注册资本，或者作为资本投资开办其他外商投资企业，经营期不少于5年的，经投资者申请，税务机关批准，退还其再投资部分已缴纳税款的40%，再投资不满5年撤出的，应当缴回已退的税款。

年度补亏优惠：外商投资企业和外国企业在中国境内设立的从事生产经营的机构、场所发生年度亏损，可以用下一年度的所得弥补；下一纳税年度的所得不足以弥补的，可以逐年延续弥补，最长不得超过5年。

二、个人所得税

个人所得税是指对自然人取得的各项应税所得所征收的一种税。

了解纳税人（居民和非居民纳税人）、征税对象、税率、减免规定。

重点掌握个人所得税的计算：

- (1) 工资、薪金所得；
- (2) 劳务所得；
- (3) 稿酬所得；
- (4) 特许权使用费所得
- (5) 其他项目

捐赠的问题。

税率

2018年这次修正，综合所得税率以现行工资、薪金所得税率（3%至45%的7级超额累进税率）为基础，将按月计算应纳税所得额调整为按年计算，并优化调整部分税率的级距。具体是：扩大3%、10%、20%三档低税率的级距，3%税率的级距扩大一倍，现行税率为10%的部分所得的税率降为3%；大幅扩大10%税率的级距，现行税率为20%的所得，以及现行税率为25%的部分所得的税率降为10%；现行税率为25%的部分所得的税率降为20%；相应缩小25%税率的级距，30%、35%、45%这三档较高税率的级距保持不变。

此外，经营所得税率。以现行个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得税率为基础，保持5%至35%的5级税率不变，适当调整各档税率的级距，其中最高档税率级距下限从10万元提高至50万元
修订之后的税率表如下：

个人所得税税率表一

（综合所得适用）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）
1	不超过36000元的	3
2	超过36000元至144000元的部分	10
3	超过144000元至300000元的部分	20
4	超过300000元至420000元的部分	25
5	超过420000元至660000元的部分	30
6	超过660000元至960000元的部分	35
7	超过960000元的部分	45

个人所得税税率表二

（经营所得适用）

级数	全年应纳税所得额	税率（%）
1	不超过30000元的	5
2	超过30000元至90000元的部分	10
3	超过90000元至300000元的部分	20
4	超过300000元至500000元的部分	30
5	超过500000元的部分	35

例8：

2019年1月，徐老师取得工资1万元，劳务报酬所得2000元，稿酬所得5000元，个人负担“三险一金”4000元，专项附加扣除3000元，请计算徐老师需要缴纳的个人所得税。

首先，计算出应纳税所得额为： 10000 （工资）
 $+2000 \times 80\%$ （劳务报酬） $+5000 \times 80\% \times 70\%$
（稿酬） -4000 （三险一金） -5000 （免征额） $-$
 3000 （专项附加扣除） $=2400$ （元）

其次，再计算应纳税额为： $2400 \times 3\% = 72$ （元）

例：某教师购彩票两张，所选6个相同号码均中了特等奖，所得奖金3000万元。该教师通过民政局捐给灾区和希望工程1800万元。请计算个人所得税。

*** 偶然所得**

*** 案例：偶然所得引发的纠纷**

第十章 劳动法

（本章内容来自配套教材《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年版2019年第二次印刷新形态教材版 周黎明著）

第一节 劳动法概述

一、劳动法的历史

二、劳动法的相关概念

第二节 劳动法主体

劳动法所涉及的两种主体为劳动者和用人单位。本节主要对这两者主体加以介绍。

一、劳动者的定义

二、劳动者的劳动权利和义务

§ 【案例10-1】

- § 甲是某高校的大学生，在08年10月31日在班级组织去某自闭症儿童教育机构做志愿者时从凳子上摔下来造成牙齿受伤，花费医药费用5000元左右，后续治疗费用还需25000元左右。
- § 请问在这情况之下，甲能否以工伤为由向此教育机构提请赔偿？
- § （请见书本分析）

§ 大学毕业生"三方协议"究竟是个啥东东？

§ 一、何谓“三方协议”？三方协议的性质是什么？

三方协议，只是一种简化的叫法，其法律上的名称叫“全国普通高等学校毕业生就业协议书”，一式三份，毕业生、用人单位和学校三方各持一份，因此得名“三方协议”。

§ 这个协议书来头不小，它是1997年由教育部高校学生司统一制定的，并且在一份叫做《关于统一使用<全国普通高等学校毕业生就业协议书>的通知》中明确规定：在全国高校毕业生就业工作中统一使用《全国普通高等学校毕业生就业协议书》。

§ 2009年，教育部将三方协议修订和完善的权利下放至省级教育主管部门，规定：省级高校毕业生就业工作主管部门牵头负责，以省（自治区、直辖市）为单位，对就业协议书的内容和形式进行修订和完善。

§ 换句话说，1997年至2009年间的三方协议格式和内容是全国统一的，2009年以后的则是每个省市统一格式，且都采用了经过数据加密处理的专用条码防伪的方式，每个³毕业生有且仅有一份，一但遗失原则上不再补发

§ 三方协议的定位和作用：就业协议书是普通高等学校毕业生和用人单位在正式确立劳动人事关系前，经双向选择，在规定期限内就确立就业关系、明确双方权利和义务而达成的书面协议；是用人单位确认毕业生相关信息真实可靠以及接收毕业生的重要凭据；是高校进行毕业生就业管理、编制就业方案以及毕业生办理就业落户手续等有关事项的重要依据。

§ 一句话总结三方协议的性质，那就是——在学校的见证下，毕业生与用人单位在建立正式劳动人事关系前对将来就业意向的初步约定。

§

§ 那么，这个三方协议违约后有什么风险？如何去规避？

§ 三、用人单位的定义

§ 四、用人单位的权利与义务

§ 第三节 劳动合同

§ 一、劳动合同概念和特点

§ 二、劳动合同的种类

§ 根据不同的分类标准，对劳动合同可作不同的分类。《劳动合同法》采用的分类方式：有固定期限劳动合同又称定期劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。劳动合同期限届满，劳动关系即告终止。

§ 无固定期限劳动合同是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

§ 根据《劳动合同法》第十四条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：

- § （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；
 - § （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；
 - § （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有劳动合同法规定的用人单位可以解除劳动合同的法定情形，续订劳动合同的。
 - § 用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
 - § 此外，根据《劳动合同法》第八十二条的规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
 - § 用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。
 - § 以完成一定的工作为期限的劳动合同是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。以下是订立此类合同的情况：1、以完成单项工作任务为期限的劳动合同；2、以项目承包方式完成承包任务的劳动合同；3、因季节原因用工的劳动合同；4、其他双方约定的以完成一定工作任务为期限的劳动合同
- 分析书本中的案例10-2

§ 三、劳动合同的签订

§ 劳动合同的订立是劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利义务的法律行为。根据《劳动合同法》第十条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

§ （一）劳动合同的订立原则（注意试用期的规定）

§ （二）劳动合同的效力

§ 分析讨论书中的案例【案例10-3】

§ 四、劳动合同的履行与变更

§ 五、劳动合同的解除

§ 劳动者、用人单位只要符合法定的条件和程序，也可在劳动合同期限届满前终止劳动合同，即解除劳动合同。总的来说可以分为两种：1、协议解除；2、单方解除。

§ （一）、协议解除劳动合同。《劳动法》第24条规定：经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。而且《劳动合同法》也规定，用人单位首先提出协议解除劳动合同的，须支付经济补偿金；而劳动者首先提出协议解除的，用人单位可以不支付经济补偿金。

§ （二）、单方解除又可以分为劳动者单方解除和用人单位单方解除。

§ 1、劳动者单方解除又有两种情况：

§ （1）预告辞职

§ 劳动者应当在30日以前书面通知用人单位方可解除劳动合同。劳动者无需说明任何法定事由，只需提前预告用人单位即可解除劳动合同，超过30日，劳动者可以向用人单位提出办理解除劳动合同的手续，用人单位应予办理。此时用人单位可以不支付经济赔偿。

§ 试用期内，劳动者预告辞职的预告期为三天，并且可以采取口头通知。

§ （2）即时辞职

§ 即劳动者不需提前预告用人单位，只要具备法律规定的正当理由，劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同，还应对因用人单位的违约行为和侵权行为造成的损失要求用人单位予以赔偿，并有权提请有关机关追究用人单位的行政责任、刑事责任。

§ 根据《劳动合同法》第三十八条，用人单位有下列六种情形之一的，劳动者可以解除合同：

§ 此处所说的经济补偿金数额由《劳动合同法》第四十七条规定。

§ 2、用人单位单方解除

§ (1) 即时解除

§ 用人单位无需以任何形式提前告之劳动者。可随时通知劳动者解除劳动合同。根据《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；3、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的；5、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成工作任务造成严重影响，或者经由用人单位提出，拒不改正。此时用人单位可不支付经济补偿。

§ (2) 需预告的解除

§ 用人单位应当提前30日以书面形式通知劳动者本人方可解除劳动合同。根据《劳动法》第二十六条的规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：1、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

§ (3) 裁员。

§ 分析讨论书中【案例10-4】 【案例10-5】

试用期解除劳动合同有哪些限制？

- § 有的餐饮业单位好像永远在招聘，永远在试用劳动者，招聘的人员竟有90%以上，甚至是100%都不合格。这是用人单位热衷于约定试用期的一个重要原因。
- § 劳动合同法第二十一条规定：在试用期中，除有证据证明劳动者不符合录用条件外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。
- § 劳动合同法第四十八规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金；用人单位支付赔偿金后，劳动合同解除或者终止。¹²

试用期是否包含在劳动合同期限内？

- § 试用期包含在劳动合同期限内。
- § 劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。
- § 现实生活中，有些用人单位往往对于试用期内的劳动者不签订正式的劳动合同，而经常会等到劳动者“转正”以后，再签订劳动合同。
- § 首先，用人单位的这种做法是错误的；其次，即使在试用期内不签订劳动合同，试用期的期限仍然是计入劳动合同期限内的。

试用期期间单位应该给职工缴纳社会保险吗？

- § 单位应当为试用期内的劳动者缴纳社会保险。根据《劳动合同法》规定，试用期包含在劳动合同期限内。既然试用期属于劳动合同期限的范围，员工就有权享受各项社会保险，即养老保险、工伤保险、医疗保险等等。
- § 如果单位没有在职工试用期期间缴纳社会保险，可以在正式签订劳动合同之后为职工补缴。

用人单位要求劳动者签订“竞业限制”的相关协议，必须给予补偿吗？

- § 单位与劳动者签订“竞业限制”协议以后，赋予了劳动者在“竞业限制”方面的义务，因此，单位应对签订了“竞业限制”条款的劳动者给予一定的补偿。
- § 根据《劳动合同法》第23条第二款规定：单位与劳动者签订“竞业限制”条款的同时，要约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。
- § 补偿金的数额由双方约定。用人单位未按照约定在劳动合同解除后向劳动者支付竞业限制经济补偿的，竞业限制条款失效。
- § 当事人在劳动合同或者保密协议中约定了竞业限制，但未约定解除或者终止劳动合同后给予劳动者经济补偿，劳动者履行了竞业限制义务，可以要求用人单位按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿，月平均工资的30%低于劳动合同履行地最低工资标准的，按照劳动合同履行地最低工资标准支付。

劳动者违反“竞业限制”约定要支付违约金吗？

- § 劳动者一旦违反“竞业限制”约定，应当按照约定向用人单位支付违约金。
- § 《劳动合同法》第23条第二款规定，用人单位要与劳动者约定，在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。
- § 同时，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

什么人可以签订“竞业限制”协议？

- § 根据《劳动合同法》规定，竞业限制的义务主体只能是用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员，用人单位不得与上述人员以外的其他劳动者约定竞业限制，否则该约定就是无效的。
- § 在“竞业限制”协议中，竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。

“竞业限制”的期限最长几年？

§ 按照《劳动合同法》规定，在解除或者终止劳动合同后，符合签订竞业限制条件的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，最长不得超过**两**年。而且该期限应是连续计算的。

劳动者在哪些情况下需要承担违约责任？

- § 违约金作为承担违约责任的主要形式，一向是用人单位绑住劳动者的“紧箍咒”。
- § 但按照《劳动合同法》的规定，在用人单位和劳动者的劳动合同约定中，严格限定了违约金的约定条件，规定单位只有在“培训服务期”和“竞业限制”这两种情形下，才能设定违约金。
- § 也就是说，除非劳动者在约定的培训服务期满前离职，或违反了保密协议、竞业限制的约定，**否则劳动者无需向单位支付任何违约金。**
- § 因此，如果在不属于《劳动合同法》规定的需承担违约责任的两种情况下，劳动者提出辞职，是无需向用人单位支付违约金的，想炒老板鱿鱼的劳动者尽可以“挥一挥衣袖不留下一分血汗钱了”。

什么样的劳动合同无效？

- § 劳动合同法规定，下列劳动合同无效或者部分无效：
 1. 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
 2. 用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；
 3. 违反法律、行政法规强制性规定的。
- § 劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

单位能强迫劳动者加班吗？

- § 《劳动合同法》第31条规定：用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。
- § 此外，《劳动法》第41条规定：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时。
- § 因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
- § 《劳动法》第38条规定：用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。
- § 对企业违反法律、法规强迫劳动者延长工作时间的，劳动者有权拒绝。

加班费怎么计算？

- § 《劳动合同法》第31条规定：用人单位安排加班的，应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。
- § 用人单位依法安排劳动者在标准工作时间以外工作的，应当按照下列标准支付劳动者**加班工资**：
 - § 1. 在日标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于小时工资基数的150%支付加班工资；
 - § 2. 在休息日工作的，应当安排其同等时间的补休，不能安排补休的，按照不低于日或者小时工资基数的200%支付加班工资；
 - § 3. 在法定休假日工作的，应当按照不低于日或者小时工资基数的300%支付加班工资。

劳动者不能胜任工作被辞退，单位给补偿吗？

§ 根据《劳动合同法》规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。但应该支付经济补偿金。标准为工作1年支付1个月工资。如果未提前30天书面通知，还应该多支付1个月工资。

§ 单位以不能胜任为由解除劳动合同需要满足3个条件：
1. 劳动者被证明不能胜任工作；2. 在劳动者不能胜任工作后，单位要为其进行培训或者调整工作岗位；3. 之后仍然不能胜任工作。

员工不能完成工作定额，单位炒人要给经济补偿吗？

- § 如果员工不能完成月定额任务量，那企业要给他换岗、培训，换岗后仍然不能完成规定工作量的，才能解除劳动合同，**而且还要支付经济补偿金**。需要注意的是，这里的“调整工作岗位”是不需劳动者同意的，而在实践中很多企业往往会滥用该条。现在的关键问题是，企业规定的定额标准是否合理，有的企业把最娴熟工人的速度规定为所有人要达到的标准，大部分员工都完不成；一旦完不成任务，企业就会以此理由与之解除劳动合同。
- § 根据《劳动合同法》规定，用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班；此外，企业制定劳动定额的有关规章制度必须经过职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，通过以上法定程序制定的涉及劳动定额标准的规章制度，才是具有法律效力的规章制度。

协商一致解除劳动合同，单位还支付经济补偿金吗？

- § 根据《劳动合同法》规定，用人单位与劳动者协商一致，由用人单位向劳动者提出解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金。
- § 可见，即使在协商一致的情况下，由用人单位提出解除劳动合同的，单位应当支付经济补偿金；而由劳动者提出解除劳动合同的，单位则可以不支付经济补偿金。
- § 但是，在其他情况下，如果系由用人单位的过错原因，由劳动者被迫提出解除劳动合同的，用人单位仍应支付经济补偿金。²⁵

单位不为劳动者转移档案怎么办？

- § 实践中，有的单位为了限制劳动者跳槽，拒绝为劳动者出具解除或终止劳动合同的证明、不为劳动者转移档案、不为劳动者转移社会保险关系等等，给劳动者带来不小损害。
- § 对于单位的这些做法，《劳动合同法》规定：用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在15日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
- § 劳动者在离职后，因社会保险或档案关系等移转手续办理与原单位产生争议的，可以作为劳动争议申请劳动仲裁，如对仲裁结果不服，还可以到人民法院起诉。

劳动合同法对试用期期限有哪些规定？

- § 劳动合同法第十九条 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。
- § 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。
- § 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。
- § 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。劳动合同仅约定试用期或者劳动合同期限与试用期相同的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

劳动合同法对试用期劳动者工资有什么规定

?

- § 用人单位滥用试用期的另一个表现方面是试用期间付给劳动者的薪金待遇低。实践中，试用期劳动者薪金待遇低的现象非常普遍，很多用人单位视试用人员为廉价劳动力，任意压低基本薪水，甚至不给工资。还有一些单位，硬性规定在试用期间一切意外伤害不列入工作范围。这也是用人单位热衷于约定试用期的重要原因之一。对试用期内工资待遇较低的问题，社会反响非常强烈。
- § 对试用期间劳动者待遇过低或得不到保障突出的问题，劳动合同法第二十条做出了有针对性的规定，劳动者在试用期的工资**不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准**。这是劳动者在试用期间工资待遇的法定最低标准。

用人单位未与劳动者订立书面劳动合同 怎么处理？

- § 对于已经建立劳动关系，但没有同时订立书面劳动合同的情况，要求用人单位与劳动者应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
- § 根据本法规定，用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬应当按照企业的或者行业的集体合同规定的标准执行；没有集体合同或者集体合同未作规定的，用人单位应当对劳动者实行同工同酬。用人单位自用工之日起超过一个月但不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者支付二倍的月工资。

用人单位违法解除或者终止劳动合同的 怎么处理？

§ 根据《劳动合同法》第四十八条、第八十七条的规定，用人单位违法解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照经济补偿标准的两倍向劳动者支付赔偿金。

劳动合同法对经济补偿金有哪些规定？

- § 一是劳动者工作不满六个月的，按半个月的工资标准支付经济补偿金；
- § 二是除后一种情形之外，劳动者每工作一年按一个月的工资标准支付经济补偿金，没有最高年限的限制；
- § 三是对高收入者的经济补偿金作了限制，即劳动者月工资高于本地区上年度职工月平均工资三倍的，按职工月平均工资三倍的标准支付经济补偿金，并且支付的年限最高不超过十二年。

发生工伤时合同到期，企业能终止合同吗？

- § 在工伤鉴定结果没有出来之前，企业不得终止合同，即使合同期满，企业也应续约合同期限，续约到鉴定结果出来。
- § 如果职工工伤是一到四级，劳动合同就不能终止，要延续到职工达到法定退休年龄。如果是五到六级，属于大部分丧失劳动能力的，职工要求续订劳动合同，企业必须续订。是七到十级的，如果第一个固定合同期限满了，企业和职工有一方不同意续订合同，可以终止合同；如果第二个固定合同期限满了，职工要求续订合同，企业必须续订合同。

工伤问题

§ 工伤问题请注意我上课讲的八个案例。详见书本案例

§ 六、劳动合同的终止

§

§ 根据《劳动合同法》第四十四条的规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：

§ （一）劳动合同期满的；

§ （二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

§ （三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

§ （四）用人单位被依法宣告破产的；

§ （五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

§ （六）法律、行政法规规定的其他情形。

§ 劳动合同期满，有《劳动合同法》第四十二条规定的用人单位不得解除劳动合同的情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是，在本单位患职业病或因工负伤规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。

§ 关于经济补偿的问题，根据劳动合同法第四十六条的规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿

- § 关于经济补偿的标准，根据《劳动合同法》第四十七条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
- § 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
- § 上文所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
- § 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第八十七条规定，按照规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
- § 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

§ 七、违反劳动法的责任

§ 八、集体合同

§ 分析书本案

§ 九、劳务派遣

§ （一）劳务派遣概念

§ 劳务派遣又称劳动力租赁、雇员租赁，是指由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，并支付报酬，把劳动者派向其他用工单位，再由其用工单位向派遣机构支付一笔服务费用的一种用工形式。

§ 劳务派遣和一般劳动关系的区别在于招收和使用劳动者的单位是否同一，劳务派遣中用工单位是通过派遣单位招收劳动者，这也使得劳动者的招收和使用发生了分离。

§ 在这样一种劳动关系中，存在着三个主体：劳动者、用工单位、劳务派遣单位。其中用工单位是实际使用劳动力的单位，派遣单位则是按照用工单位或者劳动力市场需要招收劳动者并与之订立劳动合同的组织。

§ （二）劳务派遣的岗位限制

§ 《劳动合同法》第66条规定：劳务派遣一般是在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。这条法律的出台背景是当时劳务派遣相当泛滥，派遣单位与实际用工单位的互相推诿、对被派遣劳动者合法权益造成侵害等负面问题屡见不鲜。

§ （三）劳务派遣关系的内容

§ （四）劳动合同的解除

§ 劳务派遣的劳动合同解除具有特殊性。就劳动者单方面辞职而言，根据《劳动合同法》第六十五条规定，被派遣劳动者可以协议解除和即时辞职。这并不意味着被派遣劳动者不可以预告辞职，只不过被派遣劳动者因为与派遣单位存在着劳动关系，因此被派遣劳动者预告辞职的对象应该是派遣单位。派遣单位在收到被派遣劳动者的预告辞职通知时，应将该辞职预告及时转告用工单位。

§ 对被派遣劳动者进行辞退需要有辞退程序，当被派遣劳动者存在法定可辞退情形时，用工单位只能将劳动者退回派遣单位，并不能自行辞退劳动者。其原因在于，劳动关系的双方是派遣单位和被派遣劳动者。用工单位只是购买劳务服务的单位，并非用人单位，自然也就没有权利终止劳动关系。

§

§ 分析书本案例

§ 第四节 工时、工资规定

§ 一、工作时间

§ （一）工作时间的概念和最高工时标准

§ 工作时间，又称法定工作时间，是指劳动者为履行劳动义务，在法定期限内应当从事劳动或工作的时间。但在实际生活中，很多用人单位都会要求劳动者进行加班，最高工时标准的出台就是为了防止用人单位对劳动者的无限制剥削。

§ 最高工时标准，是指法律规定的在一定自然时间内工作时间的最长限度。根据我国现行立法规定，日最长工时为8小时，周最长工时为40小时

§ （二）休假的概念和种类

§ 休假是指劳动者可以免于上班劳动并且有工资保障的休息时间。其主要包括法定节假日、年休假、探亲假和其他假期四种。

§ （三）加班加点的主要法律规定

§ （三）加班加点的工资标准

§ 《劳动法》对加班加点的工资标准规定如下：

§ 1.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；

§ 2.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；

§ 3.法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

§

§ 分析书中案例

§ 二、工资

§

§ （一）工资的概念和特征

§ 工资是指用人单位依据国家有关规定和集体合同、劳动合同的约定的标准，根据劳动者提供劳动的数量和质量，以法定方式支付给劳动者的劳动报酬。

§ 工资的特征为：（1）工资是基于劳动关系支付给劳动者的劳动报酬；（2）工资是对付出的劳动所给予的物质补偿；（3）工资依据工资法规、工资政策、集体合同、劳动合同的规定确定；（4）工资以法定方式支付。

§ （二）工资构成与形式

§ （三）工资的支付保障

§ （四）最低工资

§ 第五节 劳动法保障

§ 一、社会保险的概念和特征

§ 社会保险是指具有一定劳动关系的劳动者在暂时或永久性丧失劳动能力及失业时，获得国家、社会经济补偿和物质帮助的一种社会保障制度。

《劳动法》规定：“国家发展社会保险事业，建立社会保险制度，设立社会保险基金，使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等情况下获得帮助和补偿。”在我国目前，社会保险仅限于职工社会保险，也即劳动保险，尚未包括农民社会保险和其他劳动者保险。我国的社会保险项目有：养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险和生育保险。

§ 二、我国社会保险的结构

§ 我国目前的社会保险由基本养老保险、单位补充保险、个人储蓄保险三个层次组成。

§ （一）基本养老保险

§ 是由国家统一建立并强制实行的为劳动者平等地提供基本生活保障的社会保险。它是法定的强制保险，覆盖广，在各个险种的结构中，属于基本组成部分，是第一层次的社会保险。保险基金由用人单位负担。保险基金一般由国家、用人单位、劳动者三方合理负担。

§ （二）用人单位补充保险

§ 三、各项社会保险制度

§ （一）养老保险

§ 养老保险，又称年金保险，是指劳动者在因年老或病残而丧失劳动能力的情况下，退出劳动领域，定期领取生活费用的一种社会保险制度。我国的养老保险实行国家、企业和个人三方共同负担，职工个人也交纳一定费用的保险制度。其中，基本养老保险费用由企业和个人共同负担。它为实现劳动者老有所养提供物质保障。我国职工养老保险有三种形式：

§ 1、退休，即职工因年老或病残而完全丧失劳动能力，退出生产或工作岗位养老休息时获得一定物质帮助的制度；

§ 2、离休，即建国前参加革命工作的老干部到达一定年龄后离职休养的制度。

§ 3、退职，即职工不符合退休条件但完全丧失劳动能力而退出职务或工作岗位进行休养的制度。

§ 现行的养老保险待遇的基本内容主要包括基本养老金（含离休金、退休金和退职生活费）、医疗待遇（含离休干部的公费医疗和保健医疗）、死亡待遇、异地安置费和其他待遇等。

§ （二）失业保险

§ （三）工伤保险

§ （四）疾病、生育、死亡保险

§ 分析书中案例

§

§ 四、女职工特殊劳动保护

§

§ 女职工特殊劳动保护是指根据女职工生理特点和抚育子女的需要，对其在劳动过程中的安全健康所采取的有别于男子的特殊保护。主要包括禁止或限制女职工从事某些作业的规定、女职工“四期”保护等。

§ （一）女职工禁忌劳动范围

§ （二）女职工“四期”保护

§ 五、未成年工特殊劳动保护

§

§

§

第六节 劳动争议处理

讨论书中的案例

第十一章 仲裁与诉讼

本课件配套教材：《经济法理论与实务》浙江大学出版社2018年11月版 周黎明编著

一、仲裁

1.仲裁的概念

2.仲裁的范围 平等主体之间发生的合同纠纷和财产权益纠纷.

3.仲裁委员会

4.仲裁的重要原则\制度

自愿原则 或裁或审 一裁终局制度 法院监督制度

(注意理解自愿原则与或裁或审制)

5.仲裁协议内容、形式（仲裁条款、提交仲裁的协议）\作用\无效

内容:请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会.缺后二项无效

作用:仲裁委员会取得管辖权、排除法院管辖权、申请强制执行的必要证据。但一方起诉,另一方在答辩期内未提出管辖异议,视为放弃仲裁协议.

6.仲裁庭的组成: 当事人自己选定、或由仲裁委员会主任代为指定

7.仲裁裁决的执行 在执行期限内, 向被执行人住所地或者被执行人财产所在地人民法院申请强制执行。

8.仲裁裁决的不予执行和撤销 依法向法院申请

9、我国的涉外仲裁机构

(案例见 书本)

原告：江苏省物资集团轻工纺织总公司——

见书中P346-347

被告：（香港）裕亿集团有限公司

96.5.5，轻纺公司与裕亿公司签订销售合同，约定由裕亿公司销售普通旧电机5000吨给轻纺公司，每吨348.9美元。合同第8条明确约定：

“凡因执行本合约所发生的或与本合约有关的一切争议，双方可以通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交中国国际经济仲裁委员会，根据该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。”货物到港后，经商检查明：“本批货物主要为各类废结构件、废钢管、废齿轮箱、废元钢等”。轻纺公司遂以裕亿公司和太子公司侵权给其造成损失为由提起诉讼。裕亿公司在答辩期内提出管辖权异议称，本案当事人之间对合同纠纷已自愿达成仲裁协议，人民法院依法不应受理。

§ 江苏省高级人民法院认为：本案是因欺诈引起的侵权损害赔偿纠纷。虽然原告轻纺公司和被告裕亿公司、太子公司之间的买卖合同中订有仲裁条款，但由于被告是利用合同进行欺诈，已超出履行合同的范围，构成了侵权。双方当事人的纠纷已非合同权利义务的争议，而是侵权损害赔偿纠纷。轻纺公司有权向法院提起侵权之诉，而不受双方所订立的仲裁条款的约束。裁定：驳回裕亿公司对本案管辖权提出的异议。问：

- 1、对裁定能否上诉？
- 2、法院能否受理？请说明理由。
- 3、最高法院如何判决？

二、经济诉讼

§ 审判机构

§ 管辖 级别管辖（） 地域管辖（一般地域管辖和特殊地域管辖）

§ 注意目前司法实践中法院对一般地域管辖的补充规定，注意我上课的案例。

财产保全 1.向财产所在地法院提出申请并提供担保;2.限于诉讼请求范围;3.保全措施：查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法。

§ 审判程序

第一审普通\简易程序(起诉)：起诉条件

第二审程序(上诉)；（注意二审法院对二审案件的处理！见书本）

上诉期限

审判监督程序(申诉)

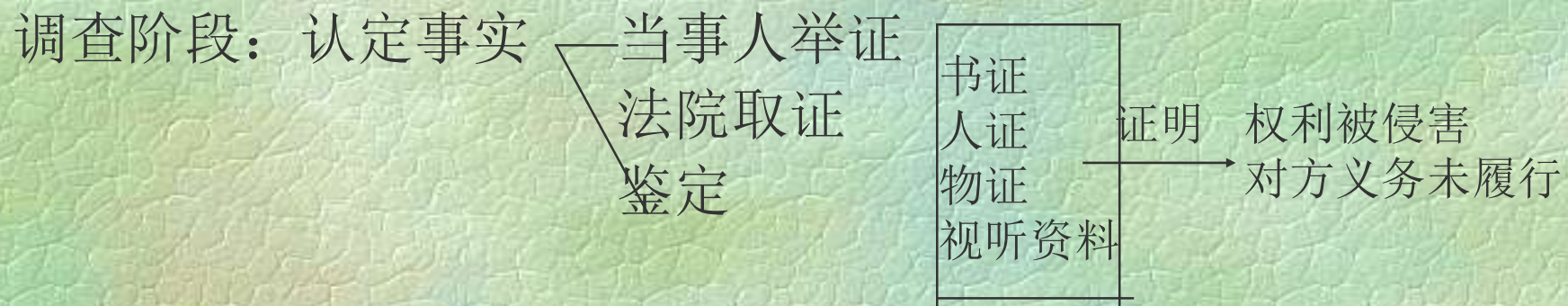
执行程序（在执行期限 单位6个月，双方公民1年内提出强制执行申请）

§ 督促程序、企业法人破产还债程序、公示催告程序

§ 特别程序：选民资格案件、宣告失踪\宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力\限制民事行为能力案件、认定财产无主案件。

诉讼一般程序

申请——受理——答辩——庭审——评议——宣判——执行
(管辖\条件) 被告 调查\辩论\调解



辩论阶段：适用法律

——双方提出对自己有利的法律依据、观点、理由

援引法律、行政法规、规章、行业规则（交易习惯）专家观点等进行辩论希望法庭能接受、采纳

民事起诉状

原告：苏××，女，1972年7月8日出生，身份证号码：住址：邮政编码：电话： 8602××××

代理人：浙江楷立律师事务所 周黎明律师 电话：13605807119

被告：杭州市大清谷有限责任公司 法定代表人：李元儿 地址：邮政编码：电话：

诉讼请求：（1）被告支付原告共计175452.87元； （2）被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

2002年5月5日，原告到被告经营的大清谷游玩，参加高空蹦极活动。在按照被告的工作人员要求办理报名、申请和其他事项之后，于11时左右，原告在教练的指导下按照操作要求跳下，随即发现左脸大量出血。事故发生后，原告被送往浙二医院治疗和缝合。因脸部伤口较深，之后，原告遵医嘱继续进行治疗和护理。从缝合至基本愈合，前后历时70天。

关于赔偿问题，在几次交涉中，被告只同意赔付原告15000元。这个费用远远低于原告的实际损失。

因被告所提出的赔付金额过低，双方无法达成协议。原告特向贵院提起诉讼，请求法院依法判令被告支付原告共计17452.87元（其中：医疗费125206.20元，后继治疗费35000元、误工费8166.67元、护理费2480元、交通费600元、营养费2000元，精神损失费2000元），并判令被告承担本案的诉讼费用。

此致

杭州市西湖区人民法院

具状人：

附：本诉状副本一份；证据清单一份。

§ 本课件所有内容（含案例分析）均来自于指定教材《经济法理论与实务》浙江大学2018年11月第一版 周黎明 编著，版权所有，未经作者许可，不得转载使用）